

《【문제1】 대여금청구소송에서 당사자 간에 금전대여사실에 대하여 다툼이 있고 이에 관하여는 증거조사의 결과와 변론에서 나타난 각종 자료가 있다. 이를 기초로 법관이 위 금전대여사실주장이 진실한지 아닌지를 판단함에 있어서 적용되는 원칙에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 대여금청구소송에서 금전대여사실의 존부 판단에 적용되는 자유심증주의의 원칙

I. 문제의 제기

- 사안에서 대여금청구소송에서 금전대여사실에 다툼이 있어 증거조사 결과와 변론에서 나타난 여러 자료를 기초로 법관이 그 사실의 존부를 판단하여야 하는 상황이다. 쟁점으로 <증거조사 결과와 변론 전체의 취지를 종합하여 사실을 인정하는 자유심증주의의 의의와 한계 및 사실인정의 기준>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 법관의 사실인정에 적용되는 자유심증주의의 내용과 한계 및 그 판단기준을 논한다.

II. 자유심증주의의 의의 및 내용

1. 자유심증주의의 의의

(1) 개념

- 민사소송법 제202조는 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 주장이 사실인지 아닌지를 판단한다고 규정하고 있다. 이는 증거의 채택과 증명력에 대한 평가를 법관의 전권에 맡기는 원칙이다.

(2) 근거

- 실제적 진실을 발견하기 위해서는 법관이 개별 사건의 특수성을 고려하여 유연하게 사실을 확정할 수 있어야 한다. 법정증거주의를 배제함으로써 법관의 양심과 전문성을 바탕으로 한 정의로운 판결을 도모한다.

2. 심증형성의 자료

(1) 증거조사의 결과

- 증인신문, 감정, 서증조사 등 적법한 증거조사를 통해 얻어진 모든 결과를 의미한다. 증거력의 강약이나 증거의 가치 판단은 전적으로 법관의 자유로운 판단에 속한다.

(2) 변론 전체의 취지

- 증거조사 결과 외에 변론의 과정에서 나타난 당사자의 태도, 주장 제기의 시기, 상대방 주장에 대한 반응 등을 모두 포함한다. 이는 독립하여 심증형성의 기초가 될 수 있으나, 직접적인 증거가 있는 경우에는 그 보충적 수단으로 기능하는 것이 일반적이다.

III. 자유심증주의의 한계

1. 논리법칙과 경험법칙의 준수

(1) 논리법칙

- 판단 내용이 모순되지 않아야 하며 사고의 보편적 법칙에 부합해야 한다. 법관의 자의적인 추론이나 비논리적인 비약은 허용되지 않는다.

(2) 경험법칙

- 인간의 경험을 통해 축적된 일반적인 법칙을 의미한다. 대여금 소송에서 일반적으로 큰 금액을 대여할 때는 차용증을 작성한다는 식의 경험칙이 사실인정의 가이드라인이 될 수 있다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 이러한 일반적 경험칙을 배제할 수 있는 구체적 근거를 제시해야 한다.

2. 적법한 증거조사절차

- 자유심증은 적법한 절차를 거쳐 현출된 증거에 기초해야 한다. 당사자가 신청하지 않은 증거를 임의로 채택하거나, 증거능력이 없는 자료를 바탕으로 심증을 형성하는 것은 법률상 허용되지 않는다.

3. 이유설시의 의무

- 법관은 판결서에 심증을 형성하게 된 근거를 구체적으로 기재해야 한다. 사실인정의 과정을 투명하게 공개함으로써 자의적 판단을 방지하고 상급심의 검토가 가능하도록 한다.

IV. 사실인정의 구체적 운용과 보충적 원칙

1. 일응의 추정 및 간접사실

(1) 일응의 추정

- 직접적인 증거가 없더라도 경험칙상 어떤 사실이 존재할 확률이 매우 높을 때, 반증이 없는 한 그 사실을 인정하는 기법이다.

(2) 간접사실의 활용

- 금전 대여를 직접 입증할 차용증이 없더라도, 돈을 인출한 통장 내역, 이후 이자를 지급받은 사실 등 간접사실을 종합하여 주요사실인 대여 사실을 인정할 수 있다.

2. 증명책임의 원칙

- 법관이 가능한 모든 증거를 조사했음에도 불구하고 사실의 존부를 확정할 수 없는 상태(진위불명)에 빠진 경우, 그 사실이 없는 것으로 판단하여 불이익을 입게 되는 당사자의 부담을 증명책임이라 한다. 대여금 소송에서 대여 사실 자체는 원고(대주)가 증명책임을 진다.

V. 결론

- 자유심증주의는 법관의 자의를 허용하는 것이 아니라, 고도의 지적 활동을 통해 객관적 진실에 다가가려는 법적 장치이다. 법관은 대여금청구소송에서 나타난 각종 자료를 종합하여 논리적이고 합리적인 판단을 내려야 하며, 이는 현대 민사재판의 신뢰를 지탱하는 기둥이다. 특히 사실심의 전권사항으로서 자유심증은 존중되어야 하나, 상고심은 법관이 경험칙이나 논리법칙을 위반했는지 여부를 감시함으로써 그 한계를 통제한다. 이하에서 고찰한 바와 같이 자유심증주의는 증명책임 원칙과 상호 보충적인 관계를 유지하며, 사법 정의 실현을 위한 가장 유연하면서도 강력한 도구로서 기능한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2010-2-1]임의적 소송담당의 의의 및 유형, 허용 요건, 소송법적 효과

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(i) 임의적 소송담당(임의적 소송신탁) (25점)》

<문제2의 물음1> 임의적 소송담당의 의의 및 유형, 허용 요건, 소송법적 효과

I 문제의 제기

- 민사소송법상 소송수행권은 원칙적으로 권리관계의 주체인 당사자에게 귀속되나, 예외적으로 제3자가 타인의 권리관계에 관하여 소송을 수행하는 경우가 있는데 이를 소송담당이라 한다. 이 중 권리주체의 의사에 기하여 소송수행권을 부여받는 경우를 임의적 소송담당이라 하며, 이는 변호사대리 원칙 및 소송신탁의 금지와 충돌할 우려가 있어 허용 범위가 문제된다. 이하에서는 임의적 소송담당의 허용 근거와 유형 및 판례상 요건에 관하여 설명한다.

II 임의적 소송담당의 의의 및 유형

1. 의의

- 권리주체인 본인의 의사에 기초하여 제3자에게 소송수행권을 수여하는 경우를 말한다. 법률에 규정이 있는 경우뿐만 아니라, 법률에 규정이 없더라도 일정한 요건 하에 예외적으로 허용될 수 있다.

2. 유형

(1) 법률에 명문 규정이 있는 경우

- 민사소송법 제53조의 선정당사자, 추심명령을 얻은 채권자 등이 대표적인 예이다. 선정당사자는 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중 선출된 자가 전원을 위해 소송을 수행하는 제도이다.

(2) 법률에 명문 규정이 없는 경우

- 민법상 조합의 업무집행조합원이나 아파트 관리단 대표 등이 자신을 당사자로 하여 소송을 수행할 수 있는지가 문제된다. 판례는 원칙적으로 부정하나 엄격한 요건 하에 긍정하고 있다.

III 임의적 소송담당의 허용 요건

1. 원칙적 금지(소송신탁의 금지)

- 신탁법 제6조는 소송행위를 하게 하는 것을 목적으로 하는 신탁을 금지하고 있다. 이는 변호사법 위반을 방지하고 소송상의 투기 행위를 막아 사법제도의 건전성을 유지하기 위함이다.

2. 예외적 허용의 요건(판례의 태도)

(1) 합리적 필요성

- 당사자가 직접 소송을 수행하는 것보다 제3자가 수행하는 것이 소송경제적으로 유리하거나, 권리 실현을 위해 불가피한 사정이 인정되어야 한다.

(2) 변호사대리 원칙 및 소송신탁 금지의 탈법 방지

- 소송담당을 허용하더라도 변호사법이 금지하는 대리 포섭이나 부당한 이익 취득의 위험이 없어야 한다. 판례는 업무집행조합원이 조합재산에 관하여 조합원 전원을 위하여 소송을 수행하는 경우 등을 긍정한다.

(3) 명시적 권한 부여

- 본인으로부터 소송수행권 부여에 관한 명확한 의사가 있어야 하며, 이는 단순한 대리권 수여와 구별되는 당사자 지위의 부여여야 한다.

IV 소송법적 효과

1. 소송수행권의 이전

- 임의적 소송담당이 성립하면 소송담당자가 원고 또는 피고로서 당사자 지위를 갖는다. 이때 본인이 소송수행권을 잃는지 여부에 따라 병행적 소송담당과 갈음적 소송담당으로 나뉜다.

2. 판결의 효력 확장

- 민사소송법 제218조 제3항에 따라 소송담당자가 받은 판결의 효력(기판력)은 권리주체인 본인에게도 미친다. 따라서 본인이 다시 동일한 소송을 제기하는 것은 기판력에 저촉된다.

3. 소송 비용의 부담

- 실제 소송을 수행한 소송담당자가 소송비용 부담의 주체가 되나, 본인 또한 판결의 효력을 받는 자로서 일정한 경우 비용 부담의 책임을 질 수 있다.

V. 결론

- 임의적 소송담당은 당사자 적격의 예외로서 소송수행의 편의를 도모하는 유용한 제도이나, 무분별한 허용은 변호사법의 근간을 흔들 수 있다. 따라서 판례는 선정당사자처럼 법률이 정한 경우 외에는 업무집행조합원과 같이 실질적 이해관계를 같이하고 소송수행의 합리적 필요성이 인정되는 경우에만 극히 제한적으로 이를 인정하고 있다. 이는 사적 자치의 원칙과 사법 절차의 투명성 사이에서 균형을 맞추려는 사법부의 의지로 풀이된다.

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(ii) 공동소송인독립의 원칙 (25점)》

<문제2의 물음2> 통상공동소송에서의 공동소송인 독립의 원칙과 그 한계 및 예외

I. 문제의 제기

- 하나의 소송절차에 여러 명의 원고 또는 피고가 관여하는 공동소송 중 통상공동소송은 각 공동소송인이 상대방에 대하여 갖는 권리관계가 개별적이고 독립적이다. 민사소송법 제66조는 이를 공동소송인 독립의 원칙으로 규정하고 있다. 이는 소송 수행의 편의를 위해 절차만 합쳐놓은 것에 불과하므로, 각 당사자의 소송행위나 법원의 판단이 서로에게 영향을 주지 않는 것이 원칙이다. 이하에서는 공동소송인 독립의 원칙의 구체적 내용과 적용 범위 및 그 보완책에 관하여 설명한다.

II. 공동소송인 독립의 원칙의 내용

1. 소송요건의 개별성

- 공동소송인 각자에 대하여 소송요건을 개별적으로 심사해야 한다. 예를 들어 어느 한 사람에 대하여 재판권이나 관할권이 없더라도 다른 공동소송인의 소송에는 영향을 미치지 않는다.

2. 소송행위의 독립성

(1) 유리·불리한 행위의 독립

- 공동소송인 중 1인이 한 소 제기, 소 취하, 자백, 청구의 포기나 인낙 등은 다른 공동소송인에게 영향을 주지 않는다. 또한 1인에 대한 상대방의 소송행위도 그 사람에게만 효력이 있다.

(2) 소송진행의 독립

- 어느 1인에게 소송절차의 중단이나 중지 사유가 발생하더라도 다른 공동소송인의 소송진행에는 영향을 미치지 않으며, 판결의 선고도 개별적으로 이루어질 수 있다.

3. 증거조사와 사실인정의 독립

(1) 증거독립의 원칙

- 어느 1인이 제출한 증거는 원칙적으로 그 사람의 소송관계에서만 효력을 가진다. 따라서 다른 공동소송인이 그 증거를 원용하지 않는 한 법원은 이를 근거로 다른 공동소송인에 대한 사실을 인정할 수 없다.

(2) 판단의 비통일

- 동일한 사실관계에 대하여도 공동소송인마다 제출한 증거와 소송행위가 다를 경우, 법원은 각자에게 서로 모순되는 판결을 내릴 수 있다. 이는 통상공동소송의 본질적 결과이다.

III. 독립의 원칙에 대한 보완 및 한계

1. 증거공통의 원칙

- 공동소송인 중 1인이 제출한 증거에 의하여 공통된 사실을 인정할 수 있는 경우, 다른 공동소송인이 이를 원용하지 않더라도 법원이 그 사실을 공통적으로 인정할 수 있다는 원칙이다. 판례는 실질적으로 동일한 증거조사 결과를 두고 당사자마다 다르게 판단하는 것은 비합리적이라는 점에서 이를 긍정한다.

2. 주장공통의 원칙 인정 여부

(1) 학설의 대립

- 공동소송인 중 1인이 자기에게 유리한 사실을 주장했을 때, 다른 공동소송인이 주장하지 않았더라도 그 효력을 인정할 것인지가 문제된다. 이를 긍정하는 견해는 소송의 통일을 강조하고, 부정하는 견해는 변론주의 원칙을 강조한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 통상공동소송에서 주장공통의 원칙을 원칙적으로 부정한다. 따라서 어느 1인이 제기한 소멸시효 항변이나 취소권 행사의 효력은 다른 공동소송인에게 미치지 않는다고 본다.

IV. 독립의 원칙의 예외 : 필수적 공동소송

1. 의의

- 소송물인 권리관계가 공동소송인 전원에게 합일적으로 확정되어야 하는 경우이다. 이때는 민사소송법 제67조가 적용되어 공동소송인 독립의 원칙이 배제된다.

2. 특례 내용

(1) 소송행위의 유효 요건

- 공동소송인 1인의 소송행위는 모두에게 유리한 경우에만 효력이 있고, 불리한 행위(자백, 취하 등)는 전원이 함께해야 효력이 발생한다.

(2) 상소의 효력

- 공동소송인 중 1인이 상소를 제기하면 전원에게 효력이 미치며, 판결의 확정도 차단되고 사건 전체가 상소심으로 이심된다.

V. 결론

- 공동소송인 독립의 원칙은 자기책임의 원칙과 변론주의를 공동소송 절차에서 구현한 것이다. 그러나 이 원칙을 고수할 경우 발생하는 판결의 모순·저촉 문제를 해결하기 위해 증거공통의 원칙 등이 활용되고 있다. 다만 판례가 주장공통의 원칙을 부정하고 있는 만큼, 실무적으로는 각 당사자가 상대방의 유리한 주장을 적극적으로 원용하여 불이익을 방지할 필요가 있다. 통상공동소송의 독립성과 필수적 공동소송의 합일확정성 사이의 조화는 민사소송법의 효율적 운영을 위한 핵심적 과제라 할 수 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2011-1]교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부

《[문제1] 교통사고 피해자인 甲은 가해자인 乙을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료 각 1,000만 원씩 합계 3,000만 원을 청구하였다. 그런데 법원은 피고에 대하여 적극적 손해 1,500만 원, 소극적 손해 1,000만 원, 위자료 500만원 합계 3,000만 원을 이행하라는 판결을 선고하였다. 이 판결의 적법성 여부에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 교통사고 피해자인 甲이 乙을 상대로 적극적 손해, 소극적 손해 및 위자료를 합한 3,000만 원의 손해배상을 청구하였는데, 법원이 각 손해 항목의 인정액을 청구 내용과 달리 배분하면서도 총액은 청구한 3,000만 원과 동일하게 인용한 상황이다. 쟁점으로 <손해배상청구에서 적극적 손해 · 소극적 손해 · 위자료가 각각 독립한 소송물인지, 아니면 하나의 소송물에 관한 공격방어방법에 불과한지>와 <법원이 청구금액의 항목별 배분을 달리하여 판단할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 손해배상청구의 소송물과 처분권주의의 적용 범위를 중심으로 법원이 손해항목을 달리 인정한 판결의 적법성 여부를 논한다.

II. 처분권주의의 의의 및 범위

1. 의의

- 처분권주의란 소송의 개시, 심판의 대상 및 범위, 소송의 종료에 대하여 당사자에게 주도권을 주는 원칙을 의미한다. 법원은 당사자가 신청한 범위 내에서만 심판해야 하며, 이를 위반하여 청구하지 않은 사항을 판결하거나 청구 범위를 초과하여 판결하는 것은 위법하다.

2. 심판대상에 관한 처분권주의

- 법원은 원고가 신청한 소송물에 대해서만 심판해야 한다. 만약 원고가 신청한 소송물과 법원이 판단한 소송물이 다르거나, 양적으로 원고의 신청 범위를 넘어서는 경우에는 처분권주의 위반이 된다.

III. 손해배상청구의 소송물과 손해3분설

1. 소송물 이론의 대립

(1) 손해1분설(일원설)

- 불법행위로 인한 손해배상청구권은 하나이며, 적극적 · 소극적 손해 및 위자료는 그 산정 방식에 불과하다고 보는 견해이다. 이 견해에 따르면 총액이 청구 범위를 넘지 않는 한 처분권주의 위반이 아니다.

(2) 손해2분설(이원설)

- 재산상 손해와 정신상 손해(위자료)를 별개의 소송물로 보는 견해이다. 재산상 손해 내에서는 항목 간 유용이 가능하다고 본다.

(3) 손해3분설(삼원설)

- 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료를 각각 별개의 소송물로 보는 견해이다. 대법원 판례의 확고한 입장이다.

2. 판례의 태도

- 대법원은 불법행위로 인한 손해배상청구소송에 있어서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료는 그 취지를 달리하는 별개의 소송물이라고 판시하고 있다. 따라서 법원은 원고가 청구한 각 손해 항목별 금액의 한도 내에서 인용해야 하며, 각 항목의 한도를 넘어서는 판결을 할 수 없다는 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 소송물별 한도 초과 여부

(1) 적극적 손해

- 원고 甲은 적극적 손해로 1,000만 원을 청구하였으나, 법원은 이를 초과하는 1,500만 원을 인정하였다. 이는 당사자가 신청한 범위를 벗어난 판결이다.

(2) 소극적 손해

- 청구액 1,000만 원에 대하여 1,000만 원을 인정하였으므로 처분권주의에 위반되지 않는다.

(3) 위자료

- 청구액 1,000만 원에 대하여 500만 원을 인용하였으므로 신청 범위 내에 해당하여 적법하다.

2. 총액 기준의 판단 여부

- 비록 판결의 인용 총액(3,000만 원)이 원고가 청구한 총액(3,000만 원)과 일치하더라도, 판례가 따르고 있는 손해3분설에 의하면 각 손해 항목은 별개의 소송물이다. 따라서 항목 간의 금액을 유용하여 적극적 손해에서 청구 범위를 초과하여 인정한 것은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 법원이 적극적 손해 항목에서 원고의 청구액인 1,000만 원을 초과하여 1,500만 원을 인정한 부분은 민사소송법 제203조가 정한 처분권주의를 위반한 것이다. 비록 전체 인용 금액이 청구 총액을 넘지 않았으나, 별개의 소송물인 적극적 손해에 대해 신청하지 않은 금액을 판결한 것이므로 해당 판결은 그 부분에 있어 부적법하다. 법원은 적극적 손해 1,000만 원, 소극적 손해 1,000만 원, 위자료 500만 원을 합산하여 총 2,500만 원만을 이행하라는 판결을 선고하여야 한다.

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(i) 보조참가인에 대한 재판의 효력 (25점)》

<문제2의 물음1> 보조참가인에 대한 재판의 효력의 의의 및 성질과 범위

I 문제의 제기

- 보조참가란 타인 간의 소송계속 중 소송결과에 대하여 이해관계가 있는 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위하여 소송에 참여하는 형태를 말한다. 민사소송법 제77조는 보조참가인에 대하여 판결의 효력이 미친다고 규정하고 있는데, 이를 기판력과 구별하여 참가적 효력이라고 부른다. 이는 피참가인이 패소하였을 때 참가인이 피참가인에게 패소의 책임을 전가하지 못하게 함으로써 재판의 모순을 방지하는 데 목적이 있다. 이하에서는 보조참가인에 대한 재판의 효력인 참가적 효력의 성질, 발생요건, 범위 및 한계에 대하여 설명한다.

II 참가적 효력의 본질 및 성질

1. 학설의 대립

(1) 기판력설

- 보조참가인에 미치는 효력을 민사소송법 제218조 제1항의 기판력으로 보는 견해이다. 그러나 보조참가인은 당사자가 아니라는 점과 기판력은 승패와 무관하게 발생하나 참가적 효력은 패소 시에만 문제된다는 점에서 비판받는다.

(2) 특수효력설(참가적 효력설)

- 기판력과는 별개로 보조참가라는 소송제도에 특유한 정책적 효력으로 보는 견해이다. 피참가인과 참가인 사이에서만 발생하는 상대적 효력이라는 점을 강조한다.

2. 판례의 태도

- 판례는 보조참가인에게 미치는 판결의 효력은 기판력이 아니라 이른바 참가적 효력이라고 본다. 이는 피참가인이 패소한 경우에 참가인과 피참가인 사이에 한하여 발생하는 효력으로서, 참가인이 판결의 기초가 된 사실상·법률상 판단이 부당하다고 주장할 수 없는 구속력을 의미한다.

III 참가적 효력의 발생요건

1. 유효한 보조참가의 계속

- 참가인이 소송에 실제로 참여하여 공격방어방법을 제출할 수 있는 상태에 있어야 한다.

2. 피참가인의 패소 판결

- 참가적 효력은 참가인이 도운 피참가인이 패소했을 때만 발생한다. 만약 피참가인이 승소했다면 참가인에게 불이익이 없으므로 효력이 발생할 여지가 없다.

3. 판결의 확정

- 판결이 상소 등으로 확정되지 않은 상태에서는 효력이 발생하지 않으며, 확정 판결의 결론뿐만 아니라 그 전제가 된 판단에도 효력이 미친다.

IV 참가적 효력의 범위

1. 주관적 범위

- 참가적 효력은 피참가인과 보조참가인 사이에서만 발생한다. 따라서 상대방 당사자와 참가인 사이, 혹은 제3자와 참가인 사이에는 이 효력이 미치지 않는다.

2. 객관적 범위

(1) 주문 및 이유 중의 판단

- 기판력이 판결주문에만 미치는 것과 달리, 참가적 효력은 판결주문뿐만 아니라 그 전제가 된 이유 중의 사실인정 및 법률적 판단에도 미친다.

(2) 효력이 미치는 판단의 범위

- 다만, 모든 판단에 미치는 것은 아니며 판결의 결론에 도달하기 위해 필수적인 주요 사실 및 법률 판단에 한하여 미친다. 판결의 결론과 직접 관련 없는 방론이나 부수적 판단에는 미치지 않는다.

V 참가적 효력의 배제(한계)

1. 민사소송법 제77조 단서의 배제사유

(1) 참가 시 소송상태에 따른 제한

- 참가 당시 이미 소송이 진행되어 참가인이 공격방어방법을 제출할 수 없었던 경우(제77조 제1호)에는 효력이 미치지 않는다.

(2) 피참가인의 행위에 의한 제한

- 피참가인이 참가인의 소송행위와 저촉되는 행위를 하여 참가인의 활동이 방해받은 경우(제77조 제2호)에는 참가인에게 책임을 물을 수 없다.

(3) 피참가인의 고의·과실에 의한 제한

- 피참가인이 참가인에게 알리지 않고 소송을 진행하거나 고의·과실로 상대방의 공격방법에 대응하지 않은 경우(제77조 제3호)에도 효력은 배제된다.

2. 신의칙에 의한 제한

- 참가인이 소송에 참여하였더라도 피참가인의 불성실한 소송수행으로 인하여 적절한 방어를 하지 못한 특별한 사정이 있다면 신의칙상 효력을 제한할 수 있다.

VI 결론

- 보조참가인에 대한 재판의 효력인 참가적 효력은 피참가인과 참가인 사이의 공평한 책임 분담을 위한 특수한 효력이다. 이는 판결의 이유 중 판단에까지 미친다는 점에서 기판력보다 넓은 객관적 범위를 가지나, 피참가인과 참가인 사이라는 한정된 주관적 범위를 갖는다. 결국 보조참가인은 자신이 도운 당사자가 패소했을 때 그 결과에 대하여 연대책임을 지되, 민사소송법 제77조 단서가 정한 방어권 보장이 미흡했던 경우에는 그 효력에서 벗어날 수 있도록 함으로써 절차적 정의와 재판의 모순 방지를 조화시키고 있다.

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(ⅱ) 자백의 구속력 (25점)》

<문제2의 물음2> 재판상 자백의 성립요건과 그에 따른 주관적·객관적 구속력 및 철회

I. 문제의 제기

- 재판상 자백이란 소송계속 중 당사자가 자기에게 불리한 사실을 시인하는 진술을 말한다. 이는 변론주의 원칙상 법원을 구속할 뿐만 아니라 진술한 당사자 본인도 구속하는 효력을 가진다. 민사소송법 제288조는 증명이 필요 없는 사실로서 자백을 규정하고 있다. 이러한 자백의 구속력은 소송의 안정성과 신의칙을 근거로 하며, 그 허용 범위와 예외적 철회 사유가 실무상 중요하다. 이하에서는 자백의 성립요건과 구속력의 구체적 내용 및 철회 요건에 대하여 설명한다.

II. 재판상 자백의 성립요건

1. 대상의 적격성

(1) 사실에 관한 진술

- 자백의 대상은 구체적인 사실에 한정된다. 법률적용이나 권리관계에 대한 판단은 법원의 전권사항이므로 자백의 대상이 되지 않는다. 다만, 소위 권과 같이 법률적 개념이 포함된 표현이라도 일상적 용어로 사용되어 사실관계의 시인을 의미하는 경우에는 자백이 성립할 수 있다.

(2) 자기에게 불리한 사실

- 진술한 당사자가 입증책임을 지는 사실을 시인하는 것을 의미한다. 판례는 입증책임의 소재를 기준으로 불이익 여부를 판단하나, 상대방이 주장하는 사실과 일치하는 진술이라면 입증책임 유무와 관계없이 자백으로 보는 견해도 존재한다.

2. 진술의 형태와 장소

(1) 소송계속 중 수소법원에 대한 진술

- 자백은 당해 소송절차의 변론기일 또는 변론준비기일에서 이루어져야 한다. 소외 자백이나 다른 소송사건에서의 진술은 재판상 자백이 아니며 단지 증거자료가 될 뿐이다.

(2) 상대방의 주장과 일치

- 당사자 일방의 진술이 상대방의 주장과 일치해야 한다. 만약 상대방의 주장과 일치하지 않는다면 선행자백에 불과하며, 상대방이 이를 원용할 때 비로소 재판상 자백이 성립한다.

III. 자백의 구속력

1. 법원에 대한 구속력(객관적 구속력)

- 법원은 당사자 사이에 합의된 자백의 내용에 구속된다. 따라서 법원은 자백된 사실과 반대되는 사실을 인정할 수 없으며, 증거조사를 통해 자백의 진위 여부를 확인해서도 안 된다. 만약 자백에 반하는 판결을 내린다면 이는 변론주의 위반으로 상소 사유가 된다.

2. 당사자에 대한 구속력(주관적 구속력)

(1) 의의

- 자백을 한 당사자는 임의로 이를 취소하거나 철회할 수 없다. 이는 상대방의 신뢰를 보호하고 소송절차의 지연을 방지하기 위함이다.

(2) 효력의 발생 시기

- 상대방이 원용하거나 처음부터 일치하는 진술을 한 시점부터 강력한 불가변적 효력이 발생한다.

IV. 자백의 철회와 실효

1. 예외적 철회 사유

(1) 상대방의 동의

- 상대방이 자백의 철회에 동의하는 경우에는 신뢰보호의 문제가 발생하지 않으므로 언제든지 철회할 수 있다.

(2) 착오 및 진실 반의 증명

- 자백이 진실에 어긋나고(진실 반), 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 철회할 수 있다. 판례는 자백이 진실에 반한다는 사실이 증명되면 착오로 인한 책임이 사실상 추정된다고 보아 입증책임을 완화하고 있다.

(3) 형사상 처벌되는 행위

- 자백이 제3자의 사기, 강박 또는 형사상 처벌받을 타인의 행위로 인하여 이루어진 경우에는 민사소송법 제451조의 재심사유에 준하여 철회할 수 있다.

2. 자백의 실효

- 소송의 취하, 청구의 변경 등으로 인하여 자백의 기초가 된 소송상태가 소멸하면 자백의 효력도 당연히 상실된다.

V. 결론

- 자백의 구속력은 변론주의 하에서 당사자의 처분권과 법원의 판단권을 조절하는 핵심 기제이다. 법원은 자백된 사실을 기초로 판단해야 하며, 당사자는 함부로 이를 뒤집을 수 없다는 점에서 소송의 예측가능성을 부여한다. 다만, 진실에 반하는 명백한 착오가 있는 경우까지 구속력을 고집하는 것은 실체적 진실 발견이라는 민사소송의 이념에 반할 수 있다. 따라서 판례는 철회 요건인 착오의 추정 범위를 넓게 인정함으로써 절차적 안정성과 구체적 타당성 사이의 균형을 도모하고 있다. 이하에서 살펴본 바와 같이 자백은 단순한 사실의 시인을 넘어 소송의 승패를 결정짓는 강력한 효력을 가지므로 당사자는 진술에 신중을 기해야 하며, 법원은 그 성립 여부를 엄격히 판단해야 한다.

《【문제1】 A는 甲에 대하여 1년치 임금을 체불하고 있었다. A는 자신의 명의로 되어 있는 재산이 거의 없고 다만 乙에 대하여 매매대금 채권을 가지고 있을 뿐이었는데, 이 채권의 변제기가 도래하였는데도 그 지급을 청구하지 않았다. 이에 甲은 A가 乙에 대하여 갖고 있는 위 채권을 대위행사하여 乙을 피고로 하는 소를 제기하였다. 그러나 甲의 청구를 기각하는 판결이 선고되었다. 승소 가능성이 적다고 판단한 甲은 항소를 제기하지 않았고, 결국 판결이 확정되었다. 이 판결의 기판력이 A에게도 미치는지 논하시오. (50점)》

<문제1> 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우 그 기판력이 채무자에게 미치는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 체불임금채권을 보전하기 위하여 채무자 A를 대위하여 제3채무자 乙을 상대로 채권자대위소송을 제기하였으나 청구기각판결이 확정된 상황이다. 쟁점으로 <채권자대위소송에서 선고·확정된 청구기각판결의 기판력이 당사자가 아닌 채무자 A에게도 미치는지 여부와 그 법적 근거>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 채권자대위소송 확정판결의 기판력이 채무자 A에게 미치는지 여부를 중심으로 기판력의 주관적 범위를 논한다.

II. 채권자대위소송 판결의 기판력 확장

1. 문제의 소재

- 민사소송법 제218조 제1항에 따라 기판력은 원칙적으로 당사자 사이에서만 발생한다. 그러나 동조 제3항은 제3자의 소송담당의 경우 실질적 이해관계인에게도 판결의 효력을 확장하고 있다. 채권자대위소송에서 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 때에만 기판력을 인정할 것인지, 아니면 알았는지 여부와 관계없이 항상 인정할 것인지가 논란이 된다.

2. 학설의 태도

(1) 절차보장설(알았을 때 설)

- 채무자가 대위소송의 제기 사실을 알았을 때에만 채무자의 절차적 권리가 보장되었다고 보아 기판력이 미친다는 견해이다. 채무자가 소송 사실을 모르는 상태에서 판결의 효력을 강요하는 것은 헌법상 재판받을 권리를 침해한다는 논거를 가진다.

(2) 법정소송담당설(무조건설)

- 채권자대위권의 성질을 법정소송담당으로 보아, 민사소송법 제218조 제3항에 의거하여 채무자의 인지 여부와 관계없이 항상 기판력이 미친다는 견해이다. 이는 판결의 모순·저축을 방지하고 법률관계의 안정을 기하기 위함이다.

3. 판례의 태도

- 대법원은 과거 채무자가 소송 제기 사실을 알았을 때에 한하여 기판력이 미친다고 판시하여 절차보장설의 입장을 취하였다. 그러나 이후 전원합의체 판결을 통해 입장을 정리하였다. 판례에 의하면 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우, 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 때에 한하여 그 판결의 효력이 채무자에게 미친다. 이때 알았을 때란 채권자에 의한 소송고지뿐만 아니라, 채무자가 어떠한 경로로든 소송 계속 사실을 알게 된 경우를 모두 포함한다.

III. 기판력 확장의 요건과 범위

1. 채무자의 소송 계속 인지

(1) 인지의 의미

- 채무자가 자신의 권리가 대위행사되고 있다는 사실을 인지함으로써 스스로 소송에 참가하거나 권리를 행사할 기회를 가졌다면, 그 결과에 대해 책임을 지우는 것이 타당하다는 취지이다.

(2) 통지의 유무

- 채권자대위소송을 제기한 채권자는 민법 제405조 제1항에 따라 채무자에게 소송 제기 사실을 통지해야 한다. 이러한 법정 통지가 이루어졌거나 채무자가 다른 방법으로 알게 되었다면 기판력 확장의 요건을 충족한다.

2. 기판력의 범위와 한계

(1) 승소판결과 패소판결

- 채권자가 승소한 경우뿐만 아니라, 사안과 같이 청구가 기각된 패소판결의 경우에도 채무자가 소송 사실을 알았다면 기판력이 미친다. 따라서 채무자는 나중에 동일한 청구권으로 제3채무자에게 소를 제기할 수 없게 된다.

(2) 기판력의 주관적 범위

- 민사소송법 제218조 제3항의 취지에 따라 소송담당자인 채권자가 받은 판결은 피담당자인 채무자에게 미친다. 이는 채무자의 권리가 확정적으로 부정되었음을 의미하며, 채무자가 후에 별소를 제기하면 기판력에 저촉되어 청구기각 판결을 받게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 채무자 A의 소송 계속 인지 여부

- 사안에서 채권자 甲이 乙을 상대로 대위소송을 제기했을 때, 채무자 A가 이 사실을 알았는지에 대한 명시적인 언급은 없다. 그러나 통상적인 대위소송의 절차와 민법상 통지 의무를 고려할 때, A가 소송 사실을 알았다고 전제한다면 판례의 법리에 따라 기판력이 미치게 된다. 만약 A가 소송 사실을 전혀 몰랐다면 판례에 의할 때 기판력은 미치지 않는다.

2. 판결의 효력 및 후소예의 영향

(1) 기판력의 발생

- A가 소송 사실을 알았다고 가정할 경우, 甲의 청구를 기각한 확정판결의 효력은 A에게 확장된다. 이는 A의 乙에 대한 매매대금 채권이 존재하지 않거나 행사할 수 없는 상태임을 확정하는 효과를 가진다.

(2) 후소 제기의 금지

- 판결의 확정으로 인해 A는 동일한 매매대금 채권을 원인으로 乙에게 직접 소를 제기하더라도, 이전 판결의 기판력에 의해 그 주장이 봉쇄된다. 법원은 기판력에 저촉되는 A의 청구를 기각해야 한다.

V. 결론

- 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우, 채무자가 그 소송 계속 사실을 알았을 때에 한하여 민사소송법 제218조 제3항에 따라 판결의 기판력이 채무자에게 미친다는 것이 판례의 확립된 견해이다. 사안에서 甲의 기각 판결이 확정되었으므로, 채무자 A가 소송 사실을 알고 있었다면 A에게도 기판력이 미치게 된다. 따라서 A는 추후 乙을 상대로 동일한 매매대금 채권을 행사할 수 없으며, 이는 증거의 공백이나 중복 소송으로 인한 법적 혼란을 방지하고 판결의 실효성을 확보하기 위한 법적 장치로 기능한다.

《【문제2】 준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과 (25점)》

<문제2> 준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과

I. 문제의 제기

- 준비서면이란 당사자가 변론에서 하고자 하는 진술 내용을 기일 전에 미리 작성하여 법원에 제출하는 서면을 말한다. 민사소송법은 변론의 집중과 효율성을 기하기 위해 준비서면의 제출을 제도화하고 있으며, 이를 제출하지 않았을 때에는 실기한 공격방어방법의 각하, 무론각하 등 일정한 불이익을 규정하고 있다. 이하에서는 준비서면 미제출 시 발생하는 단계별 절차적 효과와 실질적 불이익에 대하여 설명한다.

II. 변론기일 전의 효과

1. 무변론판결의 선고

(1) 요건

- 피고가 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하지 아니하거나, 답변서를 제출하였더라도 원고의 청구취지를 완전히 인정하는 취지일 때 법원은 변론 없이 판결을 선고할 수 있다.

(2) 예외

- 공시송달 사건이거나, 판결이 선고되기 전까지 피고가 원고의 청구취지를 다투는 취지의 답변서를 제출한 경우에는 무변론판결을 할 수 없다.

2. 준비기일에서의 진술 제한

- 변론준비절차에서 준비서면을 제출하지 않은 당사자는 상대방이 출석하지 아니한 경우 준비서면에 적지 아니한 사실을 주장할 수 없다. 이는 기일 전 상대방에게 방어 기회를 부여하기 위한 취지이다.

III. 변론기일에서의 효과

1. 진술 간주(의제)의 제한

(1) 출석 시의 원칙

- 당사자가 기일에 출석하였더라도 준비서면에 적지 아니한 사실은 상대방이 출석하지 아니한 때에는 주장하지 못한다. 다만, 상대방이 출석한 경우에는 구술로 새로운 사실을 주장할 수 있으나 실기한 공격방어방법으로 각하될 위험이 있다.

(2) 불출석 시의 효과

- 당사자 일방이 불출석한 경우 제출된 준비서면이 있다면 이를 진술한 것으로 간주(민사소송법 제148조)하나, 준비서면 자체를 제출하지 않았다면 진술 간주의 혜택을 받을 수 없어 상대방의 주장 사실을 다투지 않은 것으로 취급될 수 있다.

2. 자백간주 성립 여부

(1) 답변서 미제출의 경우

- 피고가 답변서나 준비서면을 제출하지 않고 기일에도 불출석한 경우, 원고가 주장한 사실을 명백히 다투지 아니한 것으로 보아 자백한 것으로 간주할 수 있다.(민사소송법 제150조 제3항)

(2) 공시송달의 예외

- 다만, 소송 서류가 공시송달의 방법으로 송달된 경우에는 자백간주의 규정이 적용되지 아니하므로 원고는 자신의 주장 사실을 별도로 입증하여야 한다.

IV. 증거조사 및 소송 지연에 따른 효과

1. 실기한 공격방어방법의 각하

- 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 준비서면 제출을 게을리하여 소송의 완결을 지연시키게 된다고 인정될 때, 법원은 직권 또는 상대방의 신청에 따라 해당 공격방어방법을 각하할 수 있다.(민사소송법 제149조) 이는 변론집중주의를 실현하기 위한 강력한 제재 수단이다.

2. 소송비용의 부담

- 당사자가 적당한 시기에 준비서면을 제출하지 않아 소송이 지연된 경우, 그 지연으로 말미암아 생긴 소송비용은 승패와 관계없이 그 당사자가 부담하게 할 수 있다.(민사소송법 제100조)

V. 결론

- 준비서면 미제출은 당사자에게 다양한 절차적 불이익을 초래한다. 피고의 경우 무변론판결이나 자백간주를 통해 패소의 위험에 직면할 수 있으며, 원고 또한 입증의 기회를 잃거나 실기한 공격방어방법으로 취급되어 불리한 판결을 받을 수 있다. 특히 현대 민사소송법이 추구하는 적정·공평·신속·경제의 이념 중 신속과 경제를 달성하기 위해 준비서면의 성실한 제출은 필수적이다. 따라서 당사자는 법원이 정한 기간 내에 충실한 준비서면을 제출함으로써 자신의 절차적 권리를 보호받고 법률관계를 조기에 확정 지을 필요가 있다.

《【문제3】 반소 (25점)》

<문제3> 반소의 의의, 요건, 제기 및 절차, 효과

I. 문제의 제기

- 반소란 소송절차의 계속 중에 피고가 원고에 대하여 본소의 청구와 관련 있는 새로운 청구를 하기 위하여 동일한 소송절차에서 제기하는 소를 말한다. 이는 본소와 반소를 병합 심리함으로써 심판의 중복을 피하고 판결의 모순·저촉을 방지하며 소송 경제를 도모하려는 데 목적이 있다. 이하에서는 반소의 요건 및 절차와 관련한 내용을 서술한다.

II. 반소의 요건

1. 상호 관련성

(1) 본소 청구와의 관련성

- 반소 청구가 본소 청구와 동일한 법률관계 혹은 동일한 사실상·법률상 원인에 기초하고 있어야 한다. 예컨대, 본소의 매매대금 청구에 대하여 반소로 목적물의 인도나 하자담보책임을 묻는 경우 등이 해당한다.

(2) 본소 방어방법과의 관련성

- 본소의 항변 사유와 반소 청구가 법률상·사실상 공통점이 있어야 한다. 상계의 대상이 되는 채권을 반소로 청구하는 경우 등이 이에 해당한다.

2. 본소의 계속 중 제기

- 반소는 본소가 법원에 계속되어 있는 동안에만 제기할 수 있다. 변론이 종결된 후에는 제기할 수 없으며, 본소가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸한 경우에는 원칙적으로 반소를 제기할 수 없다.

3. 절차적 요건

(1) 본소와 동일한 소송절차

- 본소와 반소가 병합하여 심리될 수 있는 동종의 소송절차여야 한다. 본소가 민사소송인데 반소가 행정소송인 경우에는 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 배타적 관할의 위배 금지

- 반소 청구가 다른 법원의 전속관할에 속하지 않아야 한다. 다만, 임의관할인 경우에는 본소가 제기된 법원에 관할권이 인정된다.

4. 소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것

- 반소의 제기가 기존 본소 심리의 경과에 비추어 소송절차를 현저히 지연시킬 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다.

III. 반소의 제기 및 절차

1. 제기 시기 및 방식

(1) 제기 시기

- 제1심 변론종결 전까지 제기하는 것이 원칙이다. 항소심에서의 반소 제기는 상대방의 동의가 있거나 상대방이 이의 없이 반소의 본안에 관하여 변론한 때, 혹은 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우에 한하여 예외적으로 허용된다.

(2) 제기 방식

- 반소는 본소와 마찬가지로 소장을 제출하는 방식에 의하며, 반소장에는 본소와의 관련성을 명시하여야 한다.

2. 심리와 판결

- 법원은 본소와 반소의 요건을 각각 심사하며, 요건을 갖춘 경우 병합 심리한다. 판결 시에는 본소와 반소에 대하여 하나의 전부판결을 내리는 것이 원칙이나, 필요한 경우 일부판결을 통해 분리하여 선고할 수도 있다.

IV. 반소의 효과

1. 소송계속과 시효중단

- 반소가 제기되면 그 시점에 반소 청구에 대한 소송계속의 효과가 발생하며, 시효중단 및 기간준수의 효과는 반소장을 제출한 때에 발생한다.

2. 본소 취하와의 관계

- 본소가 취하되더라도 피고는 반소를 취하지 않고 독자적으로 소송을 유지할 수 있다. 다만, 피고가 본소 취하에 동의한 이후에는 반소도 취하된 것으로 간주되는 경우가 있으므로 유의하여야 한다.

V. 결론

- 반소는 피고의 방어권을 보장하고 분쟁을 일거에 해결하는 유용한 제도이다. 법원은 관련성 요건을 엄격히 심사하여 남용을 막으면서도, 실질적인 분쟁 해결을 위해 적극적으로 활용할 필요가 있다. 특히 노사관계와 같은 복잡한 법률관계에서는 본소와 관련된 반소가 제기되는 경우가 빈번하므로, 법원은 양 청구의 유기적 관련성을 살펴 모순 없는 판결을 내려야 할 것이다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2013-1-1]도급계약상 연대책임 관계인 공동 피고에 대한 임금청구소송에서 소송대리인의 대리권 범위

《[문제1] 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50점)》

(문제1) 위 소송에서 甲이 변호사 A를 소송대리인으로 선임한 경우 소송대리인 A의 대리권의 범위는? (20점)》

<문제1의 물음1> 도급계약상 연대책임 관계인 공동 피고에 대한 임금청구소송에서 소송대리인의 대리권 범위

I. 문제의 제기

- 사안은 丙의 근로자인 甲이 임금을 지급받지 못하자 도급계약 관계인 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <원고 甲이 공동 피고 乙과 丙을 상대로 선임한 소송대리인인 변호사 A의 대리권의 범위가 어디까지인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송대리인의 일반적인 대리권의 범위, 특별수권이 필요한 사항, 소송대리권의 제한 가능성 여부에 대하여 설명한다.

II. 소송대리권의 범위에 관한 법리

1. 일반적 소송대리권의 범위

(1) 법정 대리권의 의의

- 민사소송법 제90조 제1항에 의하면 소송물에 관한 양도나 대리권의 제한이 없는 한 당해 소송에 관한 모든 소송행위를 할 수 있는 권한을 가진다. 이는 소송계속 중 발생하는 대내외적인 변론, 증거신청, 기일지정 신청 및 상대방의 소송행위에 대한 대응 등을 모두 포함한다.

(2) 심급대리의 원칙

- 소송대리인의 대리권은 특별한 약정이 없는 한 수임한 당해 심급의 소송절차에만 한정된다. 따라서 제1심에서 선임된 소송대리인의 대리권은 제1심의 종국판결이 대리인에게 송달됨으로써 원칙적으로 소멸하며, 판결 송달 전이라 하더라도 상소심의 소송절차에는 대리권의 효력이 미치지 않는다.

2. 특별수권사항의 범위와 내용

(1) 특별수권의 필요성

- 민사소송법 제90조 제2항은 당사자의 처분권과 직결되거나 당사자에게 중대한 불이익을 초래할 수 있는 일정한 소송행위에 대하여는 본인의 특별한 권한의 위임(특별수권)을 받도록 강제하고 있다.

(2) 구체적 법정 사항

- 특별수권이 있어야만 대리인이 행할 수 있는 행위는 다음과 같다. ① 반소의 제기. ② 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙 또는 제80조의 규정에 따른 탈퇴. ③ 상소의 제기 또는 취하. ④ 대리인의 선임.

3. 소송대리권 제한의 효력

(1) 대리권 제한의 원칙적 무효

- 민사소송법 제91조 본문에 의하면 변호사인 소송대리인의 소송대리권은 당사자의 사적 합의로 제한하지 못한다. 법정된 일반적 소송대리권에 가한 당사자 간의 사적인 제한은 법원이나 상대방에 대하여 효력이 없다. 이는 소송대리인의 자격을 신뢰한 법원과 상대방을 보호하고 소송절차의 확실적 안정을 도모하기 위함이다.

(2) 소송외적 제한의 상대적 효력

- 다만, 사적인 제한이라도 당사자 내부 관계에서는 채무불이행에 따른 민사상 손해배상책임 등의 원인이 될 수 있을 뿐이다. 또한, 특별수권사항(민사소송법 제90조 제2항)에 대하여 대리권을 별도로 수여하지 않기로 하는 것은 애초에 법정 소송대리권에 가해지는 소송법상의 사적 제한이 아니므로, 수권하지 않거나 제외하는 약정은 전적으로 유효하다.

III. 사안의 적용

1. 일반대리권의 범위

(1) 대리권 행사의 주체

- 원고 甲의 소송대리인 변호사 A는 특별한 사정이 없는 한 제1심 소송절차의 종국판결 송달 시까지 甲을 대리하여 소송행위를 수행할 법정 대리권을 가진다.

(2) 공동소송에서의 대리관계

- 乙과 丙은 임금지급에 대한 연대책임 관계에 있어 통상공동소송 관계에 해당한다. 소송대리인 A는 공동피고 乙과 丙 모두에 대하여 甲의 임금채권을 관철하기 위한 변론, 증거조사 신청, 준비서면 제출 등의 소송행위를 대리인으로서 적법하게 수행할 수 있다.

2. 특별수권의 범위

(1) 특별수권 유무에 따른 판단

- A가 乙이나 丙 중 일부에 대하여 소를 취하하거나, 법정에서 화해를 하거나, 청구의 포기·인낙을 하고자 하는 경우, 또는 패소 시 상소를 제기하고자 하는 경우에는 원고 甲으로부터 별도의 특별수권을 받아야만 한다. 특별수권이 없는 상태에서 행한 처분행위는 무권대리행위로서 무효이다.

(2) 대리권의 제한 요건

- 설령 甲이 A를 선임하면서 '상대방 乙에 대해서만 소송행위를 하고 丙에 대해서는 적극적으로 다루지 말 것'이라는 식으로 일반 대리권 범위를 제한하는 내부 계약을 체결하였더라도, 이러한 사적 제한은 민사소송법 제91조 본문에 의하여 수소법원과 상대방인 乙·丙에게 전적으로 효력이 없다.

IV. 결론

- 변호사 A의 소송대리권은 법정 심급대리 원칙에 따라 제1심 소송절차 전반에 미치며, 공동피고 乙과 丙 모두를 상대로 甲의 권리를 옹호하기 위한 변론 및 기일지정 등 일반적 소송행위 일체를 대리할 수 있다. 다만, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 상소의 제기 등 당사자의 처분권과 직결된 법정 특별수권사항에 대해서는 甲의 구체적인 특별위임이 있어야만 대리권을 행사할 수 있으며, 이외에 법정 대리권에 가해진 사적 제한은 민사소송법 제91조에 따라 소송법상 모두 무효이다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2013-1-2]공동피고 중 1인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부

《【문제1】 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50점)

(문제2) 위 소송계속 중에 乙이 丙을 선정당사자로 선정할 수 있는가? 그리고 丙이 선정당사자로서 소송을 수행하여 판결이 확정될 경우 丙이 받은 판결의 효력은 乙에게도 미치는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 공동피고 중 1인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙과 丙이 임금지급에 관한 연대책임 관계에 있는 상황에서 甲이 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구소송을 제기하고, 소송 계속 중 乙이 丙을 선정당사자로 선정하려는 상황이다. 쟁점으로 <공동소송 관계에 있는 당사자 사이에서 선정당사자 선정의 가부와 선정당사자가 받은 확정판결의 효력이 다른 선정자에게 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 선정당사자 제도의 요건과 선정당사자가 수행한 소송의 판결효력 범위를 논한다.

II. 선정당사자 제도의 의의 및 요건

1. 선정당사자의 의의 및 취지

(1) 개념 및 의의

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중 그들 전체를 위하여 소송을 수행할 당사자로 선정되어 소송을 당사자 명의로 수행하는 자를 말한다.(민사소송법 제53조)

(2) 인정 취지

- 다수인이 관여하는 소송에서 절차의 번잡함을 피하고 소송을 보다 신속하고 경제적으로 진행하기 위한 제도이다.

2. 선정당사자의 법정 요건

(1) 공동의 이해관계의 존재

- 선정당사자가 허용되려면 다수자 사이에 공동의 이해관계가 존재하여야 한다. 판례는 다수자 상호간에 소송물이 되는 권리의무가 공동이거나 동일한 사실상·법률상 원인에 기한 경우와 같이, 소송의 주요한 쟁점이 공통되는 경우를 의미한다고 판단한다.

(2) 선정의 시기 및 형식

- 선정은 소송 계속 중뿐만 아니라 소제기 전에도 할 수 있으며, 서면으로써 증명하여야 한다. 또한 피선정자는 반드시 공동의 이해관계를 가진 다수자 중의 일원이어야 한다.

III. 선정당사자 판결의 효력 확장 범위

1. 기판력 및 집행력의 확장

(1) 기판력의 인적 범위 확장

- 민사소송법 제218조 제3항에 의하면, 선정당사자를 상대방으로 하여 내린 확정판결은 선정자 모두에게 기판력이 미친다.

(2) 집행력의 확장 여부

- 확정판결의 급부 명령에 따른 집행력 또한 선정자에게 미치므로, 판결에 기하여 선정자의 재산에 대하여 직접 강제집행을 실시할 수 있다.

2. 선정자의 소송 탈퇴 효과

(1) 소송탈퇴의 의제

- 선정당사자가 선정되면 기존에 소송에 참여하고 있던 선정자는 소송에서 당연히 탈퇴한 것으로 본다.(민사소송법 제53조 제2항)

(2) 단독 수행권의 전속

- 탈퇴 결과 소송수행권은 선정당사자에게 전속되며, 선정자는 소송 수행에 직접 관여하거나 독자적으로 소송행위를 할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 丙에 대한 선정당사자 선정의 적법 여부

(1) 공동의 이해관계 충족 여부

- 공동피고 乙과 丙은 임금지급채무에 대하여 연대책임 관계에 있으므로, 소송의 핵심 쟁점인 임금청구권의 발생 여부 및 범위에 관하여 밀접한 이해관계를 공유한다. 따라서 양자 사이에는 공동의 이해관계가 인정된다.

(2) 피선정자 자격의 구비 여부

- 丙은 공동의 이해관계를 가진 공동피고 중 1인이므로 피선정자 자격이 있다. 따라서 乙이 소송 계속 중 丙을 선정당사자로 선정하는 소송행위는 적법하며, 선정 시 乙은 소송에서 탈퇴하게 된다.

2. 확정판결 효력의 乙에 대한 확장 여부

(1) 기판력의 확장 효과

- 丙이 선정당사자로서 소송을 단독으로 수행하여 최종 판결을 얻게 되면, 민사소송법 제218조 제3항의 명문 규정에 따라 당해 판결의 기판력은 선정된 당사자인 乙에게 당연히 확장된다.

(2) 집행력의 확장 효과

- 해당 임금청구소송에서 甲의 승소 판결이 확정되는 경우, 그 집행력 또한 乙에게 확장되므로 甲은 乙의 재산에 대하여도 판결에 기한 강제집행을 유효하게 실시할 수 있다.

V. 결론

- 공동피고 乙과 丙은 연대책임 관계로서 공동의 이해관계가 인정되므로, 소송 계속 중 乙이 丙을 선정당사자로 선정하는 소송행위는 전적으로 적법하다. 선정당사자인 丙이 수행한 소송의 판결이 확정되면, 민사소송법 제218조 제3항에 의하여 그 판결의 기판력 및 집행력 등의 소송법상 효력은 선정된 당사자인 乙에게도 당연히 미친다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제03절 재판상 화해>

[기출][2013-2]소송상 화해의 의의, 요건, 효력, 하자 구제수단

《【문제2】 소송상 화해에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송상 화해의 의의, 요건, 효력, 하자 구제수단

I. 문제의 제기

- 소송상 화해는 소송계속 중 양 당사자가 서로 양보하여 소송목적인 권리관계에 관한 다툼을 중단하고 소송을 종료시키기로 하는 합의를 말한다. 이는 소송의 주관적 해결방법으로서 판결에 의하지 않고 분쟁을 신속하게 종결짓는 기능을 한다. 소송상 화해가 성립하면 재판상 화해로서 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되므로, 그 성립요건과 효력의 범위, 그리고 화해에 하자가 있는 경우의 구제책이 논의의 핵심이 된다. 이하에서는 소송상 화해의 법적 성질, 요건, 효과 및 불복방법에 대하여 설명한다.

II. 소송상 화해의 법적 성질 및 요건

1. 법적 성질

(1) 학설의 대립

- 소송상 화해의 성질에 대하여는 사법상의 화해계약으로 보는 사법행위설, 소송종료를 목적으로 하는 소송행위로 보는 소송행위설, 그리고 사법행위와 소송행위가 병존하는 것으로 보는 양성설(병행설) 등이 대립한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 소송상 화해를 사법상의 화해계약인 동시에 소송법상의 소송행위라고 보고 있다. 다만, 일단 화해조서가 작성되면 확정판결과 같은 효력이 생기므로 사법상의 하자를 이유로 그 효력을 다룰 수 없고 준재심에 의해서만 취소할 수 있다고 보아 소송행위적 측면을 중시한다.

2. 성립 요건

(1) 당사자에 관한 요건

- 당사자에게 소송능력이 있어야 하며, 대리인의 경우 화해에 관한 특별수권이 있어야 한다.(민사소송법 제90조 제2항)

(2) 소송물에 관한 요건

- 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계여야 한다. 따라서 처분권주의가 적용되지 않는 친족·상속법상의 권리관계 등은 원칙적으로 화해의 대상이 될 수 없다.

(3) 시기 및 방식

- 소송이 법원에 계속 중이어야 하며, 당사자 쌍방이 법원에 출석하여 화해의 의사를 표시하고 이를 조서에 기재함으로써 성립한다.

III. 소송상 화해의 효력

1. 소송종료적 효력

- 소송상 화해가 성립하여 조서에 기재되면 소송은 그 즉시 당연히 종료된다. 이는 판결의 선고와 같은 효과를 지닌다.

2. 재판상 화해의 효력

(1) 확정판결과 동일한 효력

- 민사소송법 제220조에 의하여 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력과 집행력이 발생한다.

(2) 효력의 범위

- 기판력은 조서에 기재된 합의 사항에 한하여 발생한다. 판례는 화해조서의 기판력은 그 내용이 강행법규에 위반되거나 무효인 사유가 있더라도 준재심에 의해 취소되지 않는 한 당연무효라고 할 수 없다고 본다. 다만, 화해 내용이 특정되지 않거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 경우에는 효력이 부정될 수 있다.

IV. 화해의 하자과 구제수단

1. 화해의 무효·취소와 준재심

(1) 준재심의 소

- 소송상 화해에 기망, 착오 등 사법상 하자나 소송법상 하자가 있는 경우, 당사자는 재심에 관한 규정을 준용하여 준재심의 소를 제기함으로써 그 효력을 다룰 수 있다.(민사소송법 제461조)

(2) 하자의 주장 시기

- 화해조서가 작성된 후에는 별소로써 무효를 주장하거나 취소할 수 없으며, 반드시 준재심 절차를 밟아야 한다. 이는 확정판결의 안정성을 유지하기 위함이다.

2. 기일지정신청

(1) 의의

- 화해의 성립 과정에서 중대한 절차적 하자가 있어 화해 자체가 성립하지 않았다고 주장하는 경우(예 : 당사자의 불출석 등), 당사자는 소송종료의 효력을 다투며 기일지정신청을 할 수 있다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 화해가 유효하게 성립한 경우에는 준재심으로 다투어야 하지만, 화해가 부존재하거나 당연무효인 경우에는 기일지정신청을 통해 원래의 소송절차를 속행할 수 있다고 본다.

V. 결론

- 소송상 화해는 당사자의 자주적 분쟁 해결을 존중하는 제도로써, 성립 시 확정판결과 동일한 강력한 효력을 부여받는다. 이는 분쟁의 종국적 해결을 도모하는 이점이 있으나, 하자가 있는 경우에도 준재심이라는 제한된 수단에 의해서만 구제가 가능하다는 점에 유의해야 한다. 따라서 화해 조서 작성 시 당사자의 의사를 명확히 반영하고 절차적 요건을 엄격히 준수하는 것이 소송경제와 실질적 정의 실현을 위해 필수적이다.

《【문제3】 문서제출명령에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 문서제출명령의 의의, 대상과 범위, 신청과 심리, 불이행 효과

I. 문제의 제기

- 문서제출명령이란 문서거증자가 상대방 또는 제3자가 소지하고 있는 문서를 증거로 제출하고자 할 때, 법원이 소지자에 대하여 그 문서의 제출을 명하는 재판을 말한다. 이는 현대 소송에서 증거의 편재 현상을 해소하고 진실 발견을 도모하기 위한 중요한 수단이다. 민사소송법은 2002년 개정을 통해 문서제출의무를 일반 의무화하여 그 범위를 대폭 확대하였다. 이하에서는 문서제출명령의 대상이 되는 문서의 범위와 신청 요건, 법원의 심리 및 결정, 그리고 명령에 위반했을 때 발생하는 법적 효과에 대하여 설명한다.

II. 문서제출의무의 대상과 범위

1. 문서제출의무가 인정되는 경우

(1) 인용문서와 인도·열람청구권 있는 문서

- 당사자가 소송에서 인용한 문서를 소지하고 있는 때(민사소송법 제344조 제1항 제1호), 또는 거증자가 소지자에 대하여 그 문서를 넘겨달라고 하거나 보여달라고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가진 때(동항 제2호)에는 제출의무가 있다.

(2) 이익문서와 법률관계문서

- 문서가 거증자의 이익을 위하여 작성되었거나, 거증자와 소지자 사이의 법률관계에 관하여 작성된 때(동항 제3호)에도 제출의무가 인정된다.

2. 일반적 제출의무와 예외

(1) 일반적 제출의무

- 위의 사유에 해당하지 않더라도 문서가 증거조사의 대상이 되는 경우에는 원칙적으로 소지자에게 제출의무가 있다.(제344조 제2항)

(2) 제출거부사유

- 공무원의 직무상 비밀에 관한 문서로서 국가의 이익을 해칠 우려가 있는 경우, 자기 또는 친족이 형사소추를 당하거나 치욕을 입을 우려가 있는 사항이 적힌 경우, 직무상 비밀이 적힌 문서로서 비밀유지의무가 면제되지 않은 경우 등은 제출을 거부할 수 있다.

III. 문서제출명령의 신청과 심리

1. 신청 요건

(1) 신청의 방식

- 서면으로 신청해야 하며, 문서의 표시, 문서의 취지, 문서의 소지자, 증명할 사실, 문서제출의무의 근거 등을 명시해야 한다.(제345조)

(2) 문서의 특정

- 신청인은 원칙적으로 문서를 특정해야 한다. 다만, 신청인이 문서의 표시나 취지를 구체적으로 알기 어려운 경우에는 소지자에게 그에 관한 사항을 밝히도록 요구하는 서류의 사본 제출을 신청할 수 있다.

2. 법원의 심리와 결정

(1) 소지자의 신문

- 법원은 문서제출명령 신청이 있는 경우 원칙적으로 상대방이나 제3자인 소지자를 신문해야 한다.

(2) 인카메라(In-camera) 절차

- 문서가 제출거부사유에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 법원은 소지자에게 그 문서를 제시하게 하여 비공개로 열람할 수 있다. 이를 통해 비밀을 보호하면서도 제출의무 유무를 객관적으로 판단한다.

IV. 문서제출명령 불이행의 효과

1. 당사자가 불응한 경우

- 당사자가 명령에 응하지 않거나, 상대방의 사용을 방해할 목적으로 문서를 멸실·훼손한 경우 법원은 그 문서에 관한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.(제349조, 제350조) 이는 증거평가의 자유를 제한하는 일종의 제재적 효과이다.

2. 제3자가 불응한 경우

- 문서를 소지한 제3자가 정당한 사유 없이 명령에 위반한 경우에는 법원은 결정으로 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.(제351조) 당사자와 달리 제3자의 불응은 상대방의 주장 내용을 진실로 인정하는 사유가 되지 않는다.

V. 결론

- 문서제출명령은 증거를 독점하고 있는 당사자나 제3자로부터 증거를 현출시켜 재판의 공정성과 실체적 진실을 확보하는 데 기여한다. 특히 일반적 제출의무의 도입과 인카메라 절차의 활용은 소송 당사자의 입증 곤란을 완화하는 핵심적 기제로 작동하고 있다. 다만, 개인의 사생활이나 직무상 비밀이 침해될 우려가 있으므로 법원은 제출의무의 존부를 엄격히 판단하여 남용을 방지해야 하며, 불이행 시에는 법이 정한 제재를 엄격히 적용하여 실효성을 확보해야 한다.

《【문제1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)

(물음1) 甲은 乙회사를 피고로 해서 해고무효 확인의 소를 제기할 수 있는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 민법상 조합인 회사를 상대로 한 해고무효 확인의 소 제기 가능성

I. 문제의 제기

- 사안은 민법상 조합인 乙회사를 상대로 근로자 甲이 해고무효 확인의 소를 제기하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 <乙회사가 실질적으로 민법상 조합에 불과한 경우, 민사소송법 제52조의 법인 아닌 사단에 해당하여 독자적인 당사자능력을 가질 수 있는지, 아니면 조합원 전원을 피고로 해야 하는지>가 핵심이다. 이하에서는 민법상 조합의 당사자능력 유무, 판례의 태도, 당사자능력이 부정될 경우의 소송 수행 방법인 선정당사자 및 조합대리인 제도 등에 대해 논한다.

II. 민법상 조합의 당사자능력

1. 원칙적 부정

(1) 법리적 근거

- 민법상 조합은 2인 이상이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 성립하는 계약관계에 불과하다. 조합 그 자체는 법인격이 없으며, 조합재산은 조합원 전원의 합유로 귀속된다. 따라서 소송법상으로도 원칙적으로 조합 자체는 당사자능력이 없다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 민법상 조합은 법인격이 없고 사단성도 결여되어 있으므로 민사소송법 제52조가 정하는 법인 아닌 사단에 해당하지 않는다고 본다. 따라서 조합 명의로 소를 제기하거나 조합을 피고로 하여 소를 제기하는 것은 부적법하다는 것이 일관된 입장이다.

2. 법인 아닌 사단과의 구별

(1) 구별 기준

- 어떤 단체가 법인 아닌 사단인지 아니면 민법상 조합인지는 그 단체의 실질에 따라 판단한다. 고유한 명칭을 가지고 사회적 활동을 하며, 의사결정 기관과 집행기관을 갖추고, 구성원의 변경에 관계없이 단체 자체가 존속하는 등 단체성이 강하면 법인 아닌 사단으로 본다.

(2) 사안의 경우

- 문제에서 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 3인이 공동으로 출자하여 설립한 민법상 조합에 불과하다고 명시되어 있다. 따라서 특별한 단체적 조직을 갖추지 못한 순수한 조합으로 보아야 하며, 민사소송법 제52조를 적용하기 어렵다.

III. 조합 소송의 수행 방법

1. 조합원 전원에 의한 소송(합유관계)

(1) 필수적 공동소송

- 조합재산에 관한 소송이나 조합의 채무에 관한 소송은 원칙적으로 조합원 전원이 당사자가 되어야 하는 고유필수적 공동소송에 해당한다. 따라서 甲이 乙회사를 상대로 소를 제기하려면 조합원 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기해야 한다.

(2) 흠결의 효과

- 조합원 중 일부만을 피고로 하거나 조합 명의로만 소를 제기한 경우, 이는 당사자능력이 없는 자를 상대로 한 것이거나 당사자확정이 잘못된 것으로서 부적법 각하 대상이 된다.

2. 소송 수행의 편의를 위한 제도

(1) 선정당사자[민사소송법 제53조]

- 조합원 전원이 당사자가 되어야 함이 원칙이나, 절차의 간소화를 위해 조합원 중 1인 또는 수인을 선정당사자로 선임하여 소송을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 선정되지 않은 나머지 조합원들은 소송에서 탈퇴하게 된다.

(2) 조합대리인에 의한 소송

- 조합의 업무집행조합원이 있는 경우, 그에게 소송대리권을 수여하여 소송을 진행할 수 있으나, 이는 당사자 명의 자체를 조합으로 할 수 있다는 의미는 아니며 여전히 당사자는 조합원 전원이 되어야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙회사의 당사자능력 부정

- 乙회사는 민법상 조합에 불과하므로 민사소송법 제52조의 법인 아닌 사단에 해당하지 않는다. 따라서 乙회사라는 명칭을 피고로 적시하여 소를 제기하는 것은 당사자능력이 없는 자를 피고로 한 것이 되어 부적법하다.

2. 올바른 피고의 지정

- 甲은 해고무효 확인의 소를 제기함에 있어 乙회사의 구성원인 A, B, C 3인 전원을 피고로 지정하여 공동소송의 형태로 제기하여야 한다. 만약 乙회사만을 피고로 제기했다면 법원은 석명권을 행사하여 피고를 조합원 전원으로 보정하도록 명하여야 하며, 이에 응하지 않을 경우 소를 각하해야 한다.

V. 결론

- 민법상 조합은 독자적인 당사자능력을 가지지 못한다는 것이 통설과 판례의 입장이다. 따라서 甲은 乙회사를 피고로 하여 해고무효 확인의 소를 제기할 수 없다. 甲은 乙회사의 실질적 운영자인 조합원 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기하여야 하며, 이것이 소송법상 적절한 소제기 방법이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2014-1-2]근로자가 청구하지 않은 임금지급을 명한 판결의 적법성 여부

《【문제1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)

(물음2) 甲이 적법하게 제기한 해고무효 확인의 소에서 제1심 법원이 甲이 청구 하지도 않은 해고처분 이후 미지급한 임금의 지급을 명하는 판결을 하였다면 동 임금지급 판결은 적법한지 여부에 대해 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 甲이 청구하지 않은 임금지급을 명한 판결의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 민법상 조합인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 적법하게 제기하였는데, 제1심 법원이 甲이 청구하지 않은 해고 후 미지급 임금의 지급까지 명하는 판결을 한 상황이다. 쟁점으로 <법원이 당사자가 신청하지 않은 사항에 대하여 판결할 수 있는지>와 <처분권주의 및 신청사항 구속의 원칙에 위반되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 법원이 해고무효 확인의 소에서 청구하지 않은 임금지급을 명하는 판결의 적법성에 대하여 논한다.

II. 처분권주의의 의미와 내용

1. 처분권주의의 의미

- 처분권주의란 절차의 개시, 심판의 대상 및 범위, 그리고 절차의 종결에 대하여 당사자에게 주도권을 맡기는 원칙을 말한다. 이는 사적 자치의 원칙이 소송법적으로 발현된 것으로, 법원은 당사자가 신청한 범위 내에서만 심판해야 한다는 제약을 받는다.

2. 심판의 대상 및 범위와 관련된 내용

(1) 양적 제한

- 법원은 당사자가 청구한 상한을 초과하여 판결할 수 없다. 예를 들어 1,000만 원의 원금 지급을 청구했는데 법원이 1,200만 원을 인용하는 것은 처분권주의 위반이다.

(2) 질적 제한

- 법원은 당사자가 신청한 것과 다른 종류의 판결을 할 수 없다. 확인의 소를 제기했는데 이행 판결을 하거나, 특정 물건의 인도를 청구했는데 대금 지급을 명하는 것은 허용되지 않는다.

III. 처분권주의 위반의 효과

1. 판결의 적법성

- 처분권주의를 위반하여 당사자가 청구하지 않은 사항을 판결한 경우, 그 판결은 법령 위반으로서 상소나 재심의 대상이 된다. 다만, 이러한 결함이 있더라도 판결이 당연히무효가 되는 것은 아니며, 상소 절차를 통해 취소되기 전까지는 유효한 판결로 존재한다.

2. 상소심에서의 처리

- 상소심 법원은 처분권주의 위반을 이유로 원심판결 중 청구 범위를 벗어난 부분을 취소하여야 한다. 이는 당사자의 신청 범위를 확정하는 법원의 해석 오류에 기인한 것이므로 법률 위반에 해당한다.

IV. 사안의 적용

1. 심판 대상의 확정

- 근로자 甲이 제기한 소송은 해고무효 확인의 소이다. 이는 사용자의 해고 처분이 법률적으로 무효임을 확인받고자 하는 소송으로, 심판의 대상은 해고의 효력 유무에 한정된다.

2. 임금지급 판결의 성격

- 해고무효 확인 소송에서 승소할 경우 근로자는 소급하여 근로자의 지위를 회복하며, 이에 따른 임금청구권이 발생하는 것이 법적 효과이다. 그러나 확인의 소 그 자체에 임금지급이라는 이행청구가 당연히 포함되는 것은 아니다. 임금지급은 별도의 이행청구가 있어야만 소송물로 편입된다.

3. 처분권주의 위반 여부

- 제1심 법원이 甲이 신청하지도 않은 임금지급을 명한 것은 당사자가 청구하지 않은 이행의무를 직권으로 판단한 것이다. 이는 처분권주의의 질적 제한(청구하지 않은 종류의 판결)을 정면으로 위반한 것에 해당한다. 법원은 설령 임금청구권이 당연히 발생한다고 판단하더라도, 당사자의 명시적인 청구가 없는 한 이를 판결 주문에 기재해서는 안 된다.

V. 결론

- 제1심 법원이 甲이 청구하지 않은 미지급 임금의 지급을 명한 판결은 민사소송법 제203조가 규정하는 처분권주의를 위반한 것이다. 따라서 해당 임금지급 판결 부분은 부적법하며, 상소 등에 의하여 취소되어야 할 법령 위반의 판결에 해당한다.

<제1편 총설.제01장 민사소송.제03절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙>
[기출][2014-2]해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부

《【문제2】 甲은 乙회사로부터 해고처분을 받고 임금과 퇴직금을 아무런 조건 없이 모두 수령하였다. 甲이 소를 제기하는 데에 특별한 장애사유가 없었음에도 3년여가 경과한 뒤 乙회사의 해고처분이 부당하다고 주장하면서 해고일로부터 정년 시까지의 임금의 지급을 구하는 소를 제기한 경우에 소권의 실효 여부에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 해고 처분 후 임금과 퇴직금을 조건 없이 수령하고, 3년이 지나 소를 제기한 행위가 실효의 원칙에 위배되어 소권이 부정되는지 검토가 필요한 상황이다. <권리자가 장기간에 걸쳐 포기한 것으로 믿을 만한 외관을 형성한 후 새삼스럽게 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙상 허용되는지>가 쟁점이다. 이하에서는 실효의 원칙의 의미, 요건, 사안의 경우 실효의 원칙 적용 여부에 대하여 설명한다.

II. 실효의 원칙의 의미 및 요건

1. 실효의 원칙의 의미

- 실효의 원칙이란 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여, 상대방으로 하여금 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 사유를 준 경우에 새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의칙에 어긋나 허용되지 않는다는 원칙을 말한다.

2. 실효의 원칙의 요건

(1) 장기간의 권리 불행사

- 권리자가 유효하게 권리를 행사할 수 있었음에도 불구하고 상당한 기간 동안 이를 행사하지 않아야 한다. 여기서 상당한 기간의 판단은 구체적 사례에 따라 개별적으로 결정된다.

(2) 정당한 신뢰의 형성

- 상대방인 의무자가 이제는 권리자가 권리를 행사하지 않을 것이라고 믿을 만한 객관적이고 정당한 사유가 있어야 한다. 단순히 시간의 경과만으로는 부족하며, 권리자의 태도나 주변 정황이 고려된다.

III. 해고무효와 실효의 원칙에 관한 판례의 태도

1. 일반적인 기준

- 판례는 근로자가 해고를 당한 후 소송을 제기함에 있어 특별한 장애사유가 없음에도 불구하고 장기간이 경과하여 소를 제기한 경우, 사용자가 그 해고가 유효한 것으로 신뢰할 만한 정당한 사유가 있다면 실효의 원칙에 위배된다고 본다.

2. 퇴직금 등의 수령과 실효

(1) 조건 없는 수령

- 해고된 근로자가 퇴직금이나 해고예고수당 등을 수령하면서 아무런 이의를 제기하지 않았다면, 이는 해고를 수용하겠다는 의사표시로 해석될 여지가 크다.

(2) 예외적 상황

- 다만, 생계의 곤란 등으로 인해 부득이하게 수령했거나, 수령 시 이의를 제기한 경우, 또는 다른 동료들과 함께 복직 투쟁을 계속하고 있었던 경우 등은 실효의 원칙 적용이 배제될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 장기간의 불행사 여부

- 사안에서 甲은 해고 처분을 받은 후 3년이라는 상당한 기간 동안 소송을 제기하지 않았다. 특히, 소를 제기하는 데에 특별한 장애사유가 없음에도 불구하고 3년이 경과한 것은 실효의 원칙에서 말하는 장기간의 불행사에 해당할 가능성이 매우 높다.

2. 정당한 신뢰의 형성 여부

(1) 경제적 급부의 수령

- 甲은 해고 이후 乙회사로부터 임금과 퇴직금을 아무런 조건 없이 모두 수령하였다. 이는 사용자 乙의 입장에서 甲이 해고의 효력을 더 이상 다투지 않고 근로관계를 종료시키겠다는 의사로 신뢰하기에 충분한 정황을 제공한 것이다.

(2) 신뢰의 확정

- 장애사유 없는 3년의 침묵과 퇴직금의 전액 수령이 결합함으로써, 사용자는 새로운 직원을 채용하거나 기업 경영을 안정화하는 등 해고가 유효함을 전제로 한 후속 조치를 취했을 것이므로, 乙의 신뢰는 정당하다고 판단된다.

V. 결론

- 근로자 甲의 소 제기는 실효의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 해고 후 3년이라는 장기간의 권리 불행사와 임금 및 퇴직금의 무조건적 수령은 사용자 乙에게 권리 불행사에 대한 정당한 신뢰를 부여하였으므로, 뒤늦게 해고의 부당함을 주장하며 소를 제기하는 것은 신의성실의 원칙상 소권이 실효된 것으로 보아야 한다. 따라서 해당 소는 신의칙 위반을 이유로 부적법 각하되거나 청구 기각될 사안이다.

《【문제3】 중복된 소제기의 금지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 중복된 소제기 금지의 의의, 요건, 형태, 법원의 조치 및 간과 판결의 효력

I. 문제의 제기

- 민사소송법 제259조는 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다고 규정하고 있다. 이는 판결의 모순·저촉을 방지하고, 피고의 응소 번거로움을 피하며, 소송경제를 도모하기 위한 취지이다. 중복소송에 해당하기 위해서는 전소와 후소의 당사자 및 소송물이 동일해야 하며 전소가 법원에 계속 중이어야 한다. 이하에서는 중복된 소제기 금지의 요건, 특수한 형태, 간과 판결의 효과에 대하여 설명한다.

II. 중복된 소제기 금지의 요건

1. 전소의 계속

- 중복소송이 성립하기 위해서는 후소가 제기될 당시 전소가 법원에 계속되어 있어야 한다. 소송계속은 소장이 피고에게 송달된 때 발생하며, 전소가 상소심에 계류 중이거나 판결이 확정되기 전까지의 상태를 포함한다.

2. 당사자의 동일성

(1) 원칙

- 전소와 후소의 당사자가 동일해야 한다. 원고와 피고의 지위가 바뀌어 있는 경우(채무부존재확인인 소)에도 당사자가 동일하다면 중복소송의 요건을 충족한다.

(2) 예외

- 민사소송법 제218조에 의해 기판력이 미치는 범위에 있는 자. 즉, 채권자대위소송에서의 채무자나 선정당사자 소송에서의 선정자 등 실질적 당사자가 동일한 경우에도 당사자 동일성이 인정된다.

3. 소송물의 동일성

(1) 판단 기준

- 구실체법설에 따르면 실체법상의 권리를 기준으로, 신소송물론에 따르면 신청과 사실관계(청구취지와 청구원인)를 기준으로 소송물의 동일성을 판단한다. 판례는 원칙적으로 전소와 후소의 청구원인이 동일하고 청구취지가 같은 경우뿐만 아니라, 청구취지가 반대되거나 모순되는 관계에 있는 경우에도 소송물의 동일성을 인정한다.

(2) 공격방어방법과의 구별

- 상계의 항변은 소송물이 아닌 공격방어방법에 해당하므로, 전소에서 상계의 항변을 제출하고 후소로 그 상계하고자 하는 채권을 청구하는 것이 중복소송에 해당하는지에 대해서는 별도의 검토가 필요하다.

III. 중복소송의 특수한 형태

1. 채권자대위소송과 중복소송

(1) 채권자가 제기한 후 채무자가 제기한 경우

- 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 안 때에는 대위소송의 판결의 효력이 채무자에게 미치므로, 채무자가 별도로 제기한 소는 중복소송에 해당한다.

(2) 채무자가 제기한 후 채권자가 제기한 경우

- 채무자가 이미 소를 제기하여 계속 중인 경우, 채권자가 동일한 권리를 대상으로 대위소송을 제기하는 것은 중복소송에 해당하여 부적법하다.

2. 상계의 항변과 중복소송

- 판례는 소송물 동일성 요건과 관련하여, 전소에서 자동채권으로 상계의 항변을 제출한 상태에서 후소를 제기하는 것은 중복소송 금지 규정에 직접 저촉되지 않는다고 본다. 상계의 항변은 소송 계속을 발생시키지 않기 때문이다. 다만, 판결의 모순 저촉 방지를 위하여 후소의 정지 등을 통해 조절한다.

IV. 중복소송의 법원 조치 및 간과 판결의 효력

1. 법원의 조치

- 중복된 소제기는 소송요건 중 하나인 소의 이익이 없는 부적법한 소에 해당한다. 법원은 이를 직권조사사항으로 취급하여야 하며, 요건을 갖추지 못한 후소에 대하여 판결로써 소를 각하하여야 한다.

2. 간과한 판결의 효력

(1) 확정 전

- 중복소송 금지를 간과하고 판결이 선고된 경우, 상소(항소나 상고)를 통해 판결의 취소를 구할 수 있다.

(2) 확정 후

- 판결이 확정된 경우에는 비록 중복소송 금지에 위반된 판결이라 하더라도 재심사유가 되지 않으며, 기판력이 발생한다. 만약 전소와 후소가 모두 확정되어 서로 모순되는 경우에는 후순위 판결이 우선한다는 견해와 전순위 판결이 우선한다는 견해가 대립하나, 실무적으로는 전소 판결의 기판력에 의해 후소 판결의 효력이 제한될 수 있다.

V. 결론

- 중복된 소제기 금지의 원칙은 사법 자원의 낭비를 방지하고 법적 안정성을 도모하는 핵심적인 제도이다. 법원은 후소 제기 시 전소와의 당사자 및 소송물 동일성을 엄격히 심사하여 판결의 저촉을 예방해야 한다. 특히, 현대 소송에서 빈번한 대위소송이나 단체소송 등에서 실질적 당사자 개념을 확장 적용하여 중복소송의 범위를 합리적으로 확정하는 것이 중요하다.

《【문제1】 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스크관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스크관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50점)

(물음1) 위와 같은 소송형태의 적법 여부와 이에 대한 법원의 조치 및 판단에 대하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 피고를 특정하여 소를 제기한 후 예비적으로 피고를 추가한 소송형태의 적법 여부와 법원의 조치

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 A은행의 부서장인 리스크관리본부장 乙을 피고로 특정하여 퇴직금 관련 청구를 제기한 후 법률적 불확실성을 이유로 예비적으로 A은행을 피고로 추가한 상황이다. 쟁점으로 <피고 특정의 적법성과 예비적 피고 추가 형태의 허용 여부 및 이에 대한 법원의 심리·판단 방법>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 잘못 지정된 피고와 예비적 피고 추가의 소송형태에 관한 법리 및 법원의 조치와 판단에 대해 논한다.

II. 예비적 공동소송과 피고 추가의 법정 요건

1. 주관적 예비적 공동소송의 요건

(1) 의의 및 취지

- 공동소송인 일부에 대한 청구가 다른 공동소송인에 대한 청구와 법률상 양립할 수 없는 경우를 주관적 예비적 공동소송이라 한다. 이는 재판의 모순·저축을 방지하고 분쟁을 한꺼번에 해결하기 위한 제도이다.

(2) 법률상 양립 불가능성

- 양립할 수 없는 관계란 한쪽 피고에 대한 청구가 인용되면 타방 청구는 당연히 기각되는 관계를 뜻한다. 실체법상 채무의 귀속 주체가 누구인지 불분명하여 모순되는 주장을 하는 경우 등이 이에 속한다.

2. 예비적 피고 추가의 적법성

(1) 피고 추가의 허용 여부

- 민사소송법 제70조 제1항은 예비적 공동소송에 필수적 공동소송인 추가에 관한 제68조를 준용한다. 따라서 소송계속 중 예비적 피고를 추가하는 후발적 피고 추가도 적법하게 인정된다.

(2) 추가의 시기적 한계

- 피고 추가 신청은 제1심의 변론을 종결할 때까지만 할 수 있다. 항소심 단계에서의 예비적 피고 추가는 피고의 심급의 이익을 해칠 우려가 있어 원칙적으로 허용되지 않는다.

III. 피고 추가 신청에 대한 법원의 조치

1. 피고 추가의 신청과 허가

(1) 원고의 신청

- 원고가 기존 피고 외에 다른 사람을 예비적 피고로 추가하고자 할 때에는 서면으로 신청하여야 한다.

(2) 법원의 허가결정

- 법원은 추가 요건을 심사하여 적법한 경우 제1심 변론종결 전까지 결정으로 피고 추가를 허가한다.

2. 허가결정에 따른 송달 및 소급효

(1) 정본 및 부분의 송달

- 법원은 허가결정을 한 때에는 결정 정본을 당사자 모두에게 송달하여야 하며, 추가될 피고에게는 소장 부분도 송달하여야 한다.

(2) 소제기의 소급효

- 추가된 피고에 대한 관계에서는 처음의 소가 제기된 때에 소가 제기된 것으로 간주되므로 시효중단 등의 효력이 소급하여 발생한다.

IV. 예비적 공동소송에 대한 법원의 판단

1. 심판의 범위와 전부판결의 의무

(1) 심판 대상의 범위

- 민사소송법 제70조 제2항에 따라 주위적·예비적 공동소송에서는 모든 공동소송인에 관한 청구에 대하여 판결을 하여야 한다.

(2) 일부판결의 금지

- 법원은 일부 피고에 대해서만 판단을 내리고 누락하여서는 안 되며, 누락 시 일부판결 금지 원칙에 위배되어 부적법하다.

2. 주위적 피고와 예비적 피고에 대한 개별 판단

(1) 주위적 피고 乙에 대한 판단

- 리스크관리본부장은 은행 내부 기관에 불과하여 당사자능력이 없다. 乙 개인에 대한 소로 보더라도 퇴직금 지급의 실체법상 의무자가 아니므로 피고격이 없어 소각하 또는 청구기각 판결을 내려야 한다.

(2) 예비적 피고 A은행에 대한 판단

- A은행은 법인으로서 당사자능력 및 퇴직금 지급의 실체법상 의무를 부담하는 피고격적자이다. 따라서 법원은 乙에 대한 소를 배척함과 동시에 A은행에 대한 청구의 존부를 실질적으로 심리하여 판결해야 한다.

V. 사안의 적용

1. 소송형태의 적법성 판단

(1) 양립 불가능성 충족

- 퇴직금 지급의무자가 乙 개인인지, 아니면 법인인 A은행인지 여부는 법률상 양립할 수 없는 관계이므로 주관적 예비적 공동소송의 요건을 구비한다.

(2) 피고 추가의 적법성

- 원고 甲이 제1심 소송 계속 중에 A은행을 예비적 피고로 추가한다는 취지의 준비서면을 제출한 것은 제1심 변론종결 전의 서면 신청으로 적법한 피고 추가 신청이다.

2. 법원의 조치 및 판단의 대입

(1) 법원의 허가 및 송달 조치

- 수소법원은 甲의 신청을 피고 추가 신청으로 다루어 허가결정을 내려야 한다. 허가결정 정본을 乙과 A은행에 송달하고, A은행에는 소장 부분도 함께 송달하여 절차를 마쳐야 한다.

(2) 전부판결의 수행

- 법원은 乙에 대한 청구와 A은행에 대한 청구 모두를 판단하여야 한다. 당사자능력이 없는 乙에 대한 청구는 각하하되, 예비적 피고인 A은행에 대해서는 본안을 실질적으로 심리하여 판결한다.

Ⅵ. 결론

- 원고 甲이 乙을 상대로 제기한 소송 중 A은행을 예비적 피고로 추가한 소송형태는 법률상 양립 불가능한 공동소송 및 피고 추가 요건을 충족하므로 적법하다. 법원은 피고 추가 허가결정을 내리고 정본과 소장 부분을 송달하여야 한다. 또한 전부판결 원칙에 따라 乙에 대한 청구를 각하·기각함과 동시에 예비적 피고인 A은행에 대한 청구를 판단하여야 한다.

《【문제1】 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50점)》

(물음2) 이 때 피고 A은행에 대한 소장부분을 A은행 사무원인 丙에게 우체국 창구에서 교부하였다면, 이러한 송달은 적법한가? (20점)》

<문제1의 물음2> 피고 은행의 소장부분을 은행 사무원에게 우체국 창구에서 교부한 송달의 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 甲은 고용계약서상의 퇴직금 조항 무효확인 및 퇴직금 지급을 구하는 소를 제기하며 예비적으로 A은행을 피고로 추가하였다. 이에 법원이 피고 A은행에 대한 소장부분을 우체국 창구에서 A은행의 사무원인 丙에게 교부한 상황이다. 쟁점으로 <법인인 A은행에 대한 소장부분을 사무원에게 우체국 창구에서 교부한 송달이 민사소송법상 적법한 송달로 인정될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고 A은행에 대한 우체국 창구교부송달의 적법 여부를 설명한다.

II. 법인에 대한 송달과 보충송달의 일반 법리

1. 법인에 대한 송달과 송달장소

(1) 법인의 대표자 송달 원칙

- 법인은 대표자가 소송을 대리하므로 법인에 대한 송달은 그 대표자에게 하여야 한다. 공동대표의 경우 그중 1인에게 송달하면 효력이 발생한다.

(2) 적법한 송달장소의 획정

- 송달은 원칙적으로 대표자의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에서 하여야 한다. 이때 영업소나 사무소는 당해 법인의 시설을 의미한다.

2. 보충송달의 요건과 장소적 한계

(1) 보충송달의 의의와 요건

- 보충송달은 송달장소에서 송달받을 자를 만나지 못한 때 사무원, 고용인 또는 동거인으로서 사리를 분별할 지능이 있는 자에게 서류를 교부하는 송달이다. 수령대행인은 서류를 본인에게 교부할 것을 기대할 수 있는 능력이 있어야 한다.

(2) 적법한 송달장소 요구와 판례

- 대법원은 보충송달이 적법한 송달장소에서 하는 경우에만 허용된다고 판시한다. 따라서 송달장소가 아닌 곳에서 사무원 등을 만나 서류를 교부하는 것은 송달수령을 거부하지 않더라도 보충송달로서 부적법하다.

3. 조우송달과 우체국 창구 송달의 제한

(1) 만날 송달(조우송달)의 요건

- 송달장소를 알지 못하거나 송달할 수 없는 경우에도 송달받을 자 본인을 만나면 그의 거부 의사가 없는 한 교부송달을 할 수 있다. 다만 이는 송달받을 자 본인을 직접 만난 경우에만 허용되는 조우송달의 성격을 가진다.

(2) 우체국 창구 송달의 불인정

- 우체국 창구는 적법한 송달장소에 해당하지 않는다. 따라서 우체국 창구에서 사무원 등 수령대행인에게 서류를 교부하는 것은 보충송달로서 부적법하며, 수령권자 본인이 아니므로 조우송달로서도 무효이다.

III. 사안의 적용

1. 피고 A은행에 대한 송달 수령권자와 송달장소

(1) 피고 A은행에 대한 송달의 원칙적 수령권자

① 대표자 대리의 원칙

- 피고로 추가된 A은행은 법인에 해당하므로 소송법상 대표자가 대리하여야 한다.

② A은행 대표자의 수령권한

- 따라서 A은행에 대한 송달의 정당한 법정 수령권자는 A은행의 대표자(은행장 등)가 된다.

(2) 적법한 송달장소의 획정

① 원칙적 송달장소

- A은행에 대한 송달은 대표자의 주소, 거소 또는 A은행의 사무소나 영업소에서 실시되어야 한다.

② 우체국 창구의 성격

- 사안의 송달이 이루어진 우체국 창구는 피고 A은행의 대표자의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에 해당하지 않는다.

2. 우체국 창구에서 丙에게 교부한 송달의 적법 여부

(1) 보충송달로서의 적법성 검토

① 송달장소의 흠결

- 우체국 창구는 적법한 송달장소가 아니므로 적법한 송달장소에서 행할 것을 요구하는 보충송달의 장소적 요건을 흠결하였다.

② 보충송달의 부적법성

- 따라서 우체국 창구에서 A은행의 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 것은 보충송달로서의 효력을 가질 수 없다.

(2) 조우송달로서의 적법성 검토

① 본인 대면 요건의 결여

- 조우송달은 송달장소 외의 곳에서 송달받을 본인을 대면하여 교부하여야 인정되는 제도이다.

② 조우송달의 불성립

- 수령한 丙은 송달받을 사람인 A은행의 대표자가 아닌 사무원에 불과하므로 우체국 창구에서의 교부는 조우송달로서도 부적법하다.

IV. 결론

- 법인인 피고 A은행에 대한 소장부분의 송달은 그 대표자를 수령권자로 하여 주소나 사무소 등 적법한 송달장소에서 실시되어야 한다. 송달장소가 아닌 우체국 창구에서 법인의 대표자가 아닌 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 행위는 장소적 한계를 이탈하여 보충송달의 요건을 결여하였으며, 본인이 아닌 대행인에게 교부되어 조우송달로서도 효력이 없다. 따라서 우체국 창구에서 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 송달은 절차상 중대한 하자가 존재하므로 부적법하여 송달의 효력이 발생하지 않는다.

《【문제2】 사물관할에 하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사물관할의 의의, 결정 기준, 구체적 범위

I. 문제의 제기

- 민사소송법상 사물관할이란 제1심 소송사건에 대하여 지방법원 단독판사와 지방법원 합의부 간에 사건의 경중을 표준으로 하여 재판권의 부담관계를 정해 놓은 것을 말한다. 사물관할의 적정한 부담은 재판의 신속성과 신중성을 동시에 조화롭게 달성하기 위한 법적 장치로서 실무상 매우 중요하다. 이하에서는 사물관할의 의의와 결정 기준인 소가의 산정 방법, 지방법원 합의부와 단독판사의 관할 사건을 구체적으로 설명한다.

II. 사물관할의 의의 및 결정 기준

1. 사물관할의 개념 및 구별

- 사물관할은 제1심 소송사건을 다루는 단독판사와 합의부 사이의 관할 부담이다. 이는 법원 내부의 단순한 사무분담이 아닌 법률상 관할의 문제이므로, 이를 위반한 소제기는 관할위반으로서 이송의 대상이 된다.

2. 소송목적의 값(소가) 산정 법리

- 소가는 원고가 소로써 달성하려는 객관적인 경제적 이익을 기준으로 산정한다.

(1) 산정의 기준시기

- 민사소송법 제26조 제1항에 의하여 소가는 소를 제기한 때를 기준으로 산정하며, 소제기 이후 목적물의 가격 변동 등 사정변경이 있더라도 사물관할에는 영향이 없다.

(2) 산정의 일반 원칙

- 소가는 원고가 전부 승소할 경우에 직접 받게 되는 경제적 이익을 화폐 단위로 평가하여 산출하며, 병합 청구의 경우 원칙적으로 청구의 값을 합산하여 산정한다.

III. 단독판사와 합의부의 구체적 사물관할

1. 지방법원 합의부의 관할 범위

- 지방법원 및 지방법원의 합의부는 비교적 무겁고 신중한 판단이 필요한 다음 사건을 제1심으로 심판한다.

(1) 소가 기준에 따른 관할

- 민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙에 따라 소송목적의 가액이 5억 원을 초과하는 민사사건 및 소가를 산출할 수 없는 사건(비재산권상의 소 등)은 합의부 관할에 속한다.

(2) 재정 및 관련 청구 기준

- 합의부에서 심판할 것으로 합의부가 스스로 결정한 재정합의사건과, 합의부 관할인 본소에 병합하여 제기하는 반소 또는 독립당사자참가 등의 관련청구는 합의부가 관할한다.

2. 지방법원 단독판사의 관할 범위

- 지방법원 단독판사는 신속한 해결이 요구되는 비교적 가벼운 사건을 제1심으로 심판한다.

(1) 원칙적 단독 관할 사건

- 소송목적의 가액이 5억 원 이하인 사건은 단독판사의 관할에 해당하며, 소가 2억 원 초과 5억 원 이하의 고액단독사건은 경험이 풍부한 부장판사가 담당하도록 편제되어 있다.

(2) 특수 및 재정단독 사건

- 수표금·어음금 청구사건 및 금융기관의 대여금 청구사건 등은 사안이 명확하고 신속한 권리 실현이 요구되므로 소가와 관계없이 단독판사가 관할한다. 또한 합의부 사건 중 단독판사가 심판하도록 합의부가 결정한 재정단독사건 역시 이에 속한다.

IV. 구체적 예시

1. 6억 원의 대여금 청구소송을 제기하는 경우

- 소가 5억 원을 초과하는 민사사건이므로 사건의 중대성을 고려하여 제1심 법원으로서 지방법원 합의부에 소를 제기하여야 한다. 만약, 이를 단독판사에게 잘못 제기한 경우 법원은 직권으로 관할권이 있는 합의부에 이송하여야 한다.

2. 3억 원의 손해배상청구소송을 제기하는 경우

- 소가 5억 원 이하인 민사사건에 해당하므로 제1심 관할법원은 지방법원 단독판사가 된다. 다만, 당사자가 제1회 변론기일 전에 합의부 심리를 신청하거나 사건의 난이도가 높은 경우 재정합의 결정을 통해 합의부로 이송할 수 있다.

V. 결론

- 사물관할은 제1심 소송의 경중에 따라 재판의 효율성과 신중성을 기하기 위하여 합의부와 단독판사 간에 재판권을 부담하는 제도이다. 현행 민사 및 가사소송의 사물관할 규칙에 따라 소가 5억 원을 기준으로 초과 시 합의부, 이하 시 단독판사가 담당하는 체계를 취하되, 어음·수표금 등 특수 사건은 단독판사의 고유관할로 둔다. 사물관할은 강행규정이 아니므로 당사자 합의나 변론관할의 성립이 가능하나, 원칙적으로 관할 규정을 그르친 소제기에 대하여 법원은 이송 결정을 통해 적법한 수소법원에서 재판이 이루어지도록 조정하여 국민의 재판받을 권리를 실체적으로 보장하고 있다.

《【문제3】 재소의 금지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 재소의 금지의 요건, 적용 범위, 효과

I. 문제의 제기

- 재소금지란 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다는 원칙을 의미한다.(민사소송법 제267조 제2항) 이는 소취하의 자유를 악용하여 법원을 농락하거나 상대방을 괴롭히는 행위를 방지하고, 국가 재판권의 권위를 유지하며 사법 자원의 낭비를 막는 데 그 목적이 있다. 재소금지는 기판력과 달리 소송계속 중의 행위인 소취하에 기해 발생하므로 실체적 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니지만, 소송법상 적법한 소 제기 권능을 박탈하는 효과를 가진다. 이하에서는 재소금지의 요건으로서 주관적 요건, 객관적 요건, 소취하의 시기적 요건 및 재소의 동일성 여부와 그 효과에 대하여 설명한다.

II. 재소금지의 요건

1. 주관적 요건(당사자의 동일성)

(1) 원칙

- 재소금지는 소를 취하한 원고와 그 피고 사이에 적용된다. 따라서 원고나 피고가 다른 경우에는 원칙적으로 재소금지가 적용되지 않는다.

(2) 예외

- 당사자가 동일하지 않더라도 민사소송법 제218조에 따른 기판력의 주관적 범위가 미치는 승계인 등에게는 재소금지의 효력이 미친다는 것이 판례의 태도이다. 또한 채권자대위소송에서 채무자가 소송계속 사실을 알았음에도 원고인 채권자가 중국판결 후 소를 취하였다면 채무자에게도 재소금지의 효력이 미친다.

2. 객관적 요건(소송물의 동일성)

(1) 동일한 소의 의미

- 재소금지에서 말하는 동일한 소란 전소와 후소의 당사자, 소송물 및 권리보호이익이 동일한 경우를 말한다. 소송법상 경제적 이익이 같더라도 소송물이 다르면 재소금지에 해당하지 않는다.

(2) 신청의 형태

- 전소가 이행의 소였으나 후소가 확인의 소인 경우처럼 소의 형태가 다르더라도 그 기초가 되는 권리관계가 동일하고 재소금지의 취지에 반한다면 동일한 소로 취급될 수 있다.

3. 시기적 요건(중국판결 후의 소취하)

(1) 중국판결의 존재

- 본안에 대한 중국판결이 선고된 이후여야 한다. 소간각하나 소송판결 후의 소취하는 재판권의 낭비가 없으므로 재소금지가 적용되지 않는다. 1심 판결 후뿐만 아니라 항소심 판결 선고 후 소를 취하한 경우도 포함된다.

(2) 소취하의 유효성

- 소취하가 유효하게 성립해야 한다. 만약 소취하가 무효이거나 취소된 경우에는 재소금지의 문제가 발생하지 않는다.

4. 권리보호이익의 동일성(새로운 사정의 유무)

- 후소를 제기할 정당한 사유나 새로운 사정이 발생한 경우에는 예외적으로 재소금지가 적용되지 않는다. 전소 취하 당시에는 예상할 수 없었던 사정변경이 생겨 다시 소를 제기할 필요가 있는 경우가 이에 해당한다.

III. 재소금지의 적용 범위

1. 반소의 경우

- 피고가 본안에 대한 중국판결 후 반소를 취하한 경우에도 재소금지의 원칙이 적용되어 다시 반소를 제기하거나 별도로 청구할 수 없다.

2. 소의 변경

- 소의 변경 중 추가적 변경은 기존의 소를 유지하면서 새로운 청구를 보태는 것이므로 취하의 문제가 없으나, 교환적 변경은 구 청구의 취하와 신 청구의 제기가 결합된 것이므로 중국판결 후 교환적 변경을 하여 구 청구를 취하하게 되면 재소금지의 적용을 받는다.

IV. 재소금지의 효과

1. 소송법상 효과

- 재소금지의 요건에 해당하면 후소는 부적법하게 되며, 법원은 직권으로 이를 조사하여 판결로써 소를 각하하여야 한다. 이는 전속관할과 유사한 공익적 성격을 가지므로 당사자의 합의로도 재소금지의 효과를 배제할 수 없다.

2. 실체법상 효과

- 재소금지는 소송법상의 제재일 뿐이므로, 원고의 실체법상 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니다. 따라서 원고는 소송 외에서 권리를 행사하거나 상계의 청구 등으로 대항하는 것은 가능하다.

V. 결론

- 재소금지의 원칙은 법원의 중국판결이 있는 후 소를 취하하여 판결을 무효화시킨 자에게 부과하는 강력한 소송법상 제재이다. 이는 소송 경제를 도모하고 사법 제도의 신뢰를 유지하기 위한 필수적인 장치이다. 그러나 당사자의 재판을 받을 권리를 본질적으로 제한하는 측면이 있으므로, 판례는 승계인에 대한 효력이나 새로운 사정변경이 있는 경우 등 구체적 사안에서 재소금지의 범위를 합리적으로 해석하여 운영하고 있다. 실무적으로는 중국판결 후의 소취하가 가져올 불이익을 당사자에게 충분히 고지하여 신중한 절차 선택을 유도하는 것이 필요하다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2016-1-1]노동조합이 조합원을 위하여 제기한 손해배상청구소송에서 노동조합의 당사자적격 여부

《【문제1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50점)
(아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음1) 甲이 소속하고 있는 노동조합 丙이 원고로서 사용자인 乙회사를 상대로 甲을 위하여 소송을 수행할 경우, 丙노동조합에 당사자적격이 있는지를 설명하시오. (35점)》

<문제1의 물음1> 노동조합이 조합원을 위하여 제기한 손해배상청구소송에서 노동조합의 당사자적격 여부

I. 문제의 제기

- 민사소송법상 당사자적격이란 특정의 소송물에 관하여 본안판결을 받기에 적합한 자격으로서 원칙적으로 권리관계의 주체인 당사자에게 인정된다. 사안에서 丙노동조합은 조합원 甲의 개인적 권리인 손해배상청구권을 행사하려고 하는 상황이다. 쟁점으로 <권리주체가 아닌 제3자가 타인의 권리에 대하여 소송을 수행할 수 있는 임의적 소송담당에 해당하는지>, <노동조합이 조합원의 이익을 위해 소송을 제기할 수 있는 명문의 규정이 없는 상황에서 판례가 인정하는 예외적 허용 요건을 충족하는지> 검토가 필요하다. 이하에서는 이러한 노동조합의 당사자적격에 대해 설명한다.

II. 당사자적격과 임의적 소송담당

1. 당사자적격의 원칙

- 당사자적격은 소송물인 권리관계의 존부와 직접 이해관계를 가진 자에게 주어진다. 이행의 소에서는 스스로 원고라고 주장하는 자에게 원고적격이 인정되는 것이 원칙이다.

2. 임의적 소송담당의 의의

- 권리주체인 당사자의 의사에 따라 제3자에게 소송수행권을 부여하는 것을 말한다. 이는 변호사대리의 원칙(민사소송법 제87조)이나 신탁법상 소송 신탁의 금지(신탁법 제6조)와 충돌할 우려가 있어 제한적으로 허용된다.

III. 임의적 소송담당의 허용 요건

1. 명문의 규정이 있는 경우

- 민사소송법 제53조에 따른 선정당사자, 추심명령을 얻은 채권자, 가압류채권자 등이 이에 해당한다.

2. 명문의 규정이 없는 경우(판례의 태도)

(1) 허용 요건

- 판례는 법률의 명문규정이 없더라도 ① 이를 인정할 합리적 필요가 있고, ② 변호사대리의 원칙이나 소송신탁 금지의 탈법적 수단으로 이용될 우려가 없으며, ③ 제3자의 소송수행을 허용함으로써 본래의 권리주체에게 부당한 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 예외적으로 임의적 소송담당을 인정한다.

(2) 소송신탁의 금지

- 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 채권양도 등이 이루어지는 것은 소송신탁으로서 무효이나, 위 요건을 갖춘 정당한 업무 범위 내의 소송 수행은 금지되지 않는다.

IV. 노동조합의 당사자적격 인정 여부

1. 단체소송의 가능성

- 노동조합은 노동조합 및 노동관계조정법에 따라 단체교섭 및 단체협약 체결권이 있으나, 조합원 개개인의 미지급 임금이나 손해배상청구권은 조합 원에게 전속하는 권리이다. 따라서 노동조합이 자신의 이름으로 조합원의 권리를 청구하는 단체소송은 원칙적으로 부정된다.

2. 임의적 소송담당 인정 여부

(1) 긍정설

- 노동조합의 본질적 기능인 조합원의 권익 보호를 위해 소송수행의 필요성을 강조하는 견해이다.

(2) 부정설(판례의 태도)

- 판례는 노동조합이 조합원들을 위하여 원고가 되어 사용자에게 조합원들의 임금 등을 청구하는 소송은 법률에 명문의 규정이 없는 한 허용되지 않는다고 본다. 노동조합이 조합원으로부터 소송수행권을 위임받아 소를 제기하는 것은 변호사법 위반이나 소송신탁 금지에 저촉될 가능성이 크기 때문이다.

V. 사안의 적용

1. 권리의 전속성

- 사안에서 甲이 입은 업무 중 상해로 인한 손해배상청구권은 甲의 신체 침해에 따른 전속적 권리이다. 丙노동조합이 비록 甲을 보호할 목적이 있다 하더라도 소송물의 주체는 여전히 甲이다.

2. 선정당사자 제도의 활용

- 만약 여러 조합원이 동일한 사고로 피해를 입었다면 민사소송법 제53조에 따라 甲이 丙노동조합의 간부 등을 선정당사자로 지정하여 소송을 진행할 수는 있으나, 丙노동조합 자체가 원고가 될 수는 없다.

3. 소송수행권의 부존재

- 丙노동조합은 법령상 조합원의 개인적 손해배상청구권을 대리하여 소송할 권한이 없다. 판례의 엄격한 요건에 비추어 보더라도 노동조합에 의한 임의적 소송담당을 인정할 만큼 특수한 합리적 필요성이 있다고 보기 어렵다.

VI. 결론

- 민사소송법상 당사자적격은 권리관계의 실질적 주체에게 귀속됨이 원칙이며, 제3자에 의한 소송수행은 법률에 근거가 있거나 판례상 극히 예외적인 요건을 갖춘 경우에만 허용된다. 丙노동조합이 조합원 甲을 위하여 원고로서 소송을 수행하는 것은 우리 판례의 태도에 비추어 볼 때 임의적 소송담당의 요건을 충족하지 못하므로 丙노동조합은 당사자적격이 없다. 따라서 丙이 제기한 소는 부적법하여 각하될 것이다. 甲이 소송을 수행하기 위해서는 본인이 직접 소를 제기하거나, 변호사를 선임하여야 하며 노동조합은 소송 보조 등의 간접적 지원에 그쳐야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

[기출][2016-1-2]대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사의 소송대리권 부활 여부

《【문제1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50점) (아래 각 설문은 상호 무관함)》

(물음2) 위와는 달리, 甲이 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 그 소송의 항소심에서 변호사 丁이 甲의 소송대리인이었는데, 대법원의 파기환송판결에 의하여 사건이 항소심에 다시 계속하게 되었다면 위 丁의 소송대리권은 어떻게 되는지를 설명하시오. (15점)》

<문제1의 물음2> 대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사의 소송대리권 부활 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙회사를 상대로 제기한 손해배상청구소송의 항소심에서 소송대리인이었던 丁이 대법원의 파기환송판결 이후 다시 항소심에 계속된 사건에서도 종전의 소송대리권을 유지하는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <파기환송으로 사건이 원심에 다시 계속된 경우 종전 항소심 소송대리인의 소송대리권이 소멸하는지 아니면 그대로 존속하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기환송 후 항소심에서 소송대리인 丁의 소송대리권의 존속 여부를 설명한다.

II. 심급대리의 원칙과 소송대리권의 범위

1. 심급대리의 원칙

- 소송대리권은 특별한 약정이 없는 한 당해 심급에 한하여 존속한다. 이는 대리인의 책임 범위를 명확히 하고, 당사자가 각 심급마다 새로운 대리인을 선임할 기회를 보장하기 위함이다.

2. 소송대리권의 범위

(1) 원칙적 범위

- 민사소송법 제90조 제1항에 따라 소송대리인은 당해 심급의 소송물에 관한 일체의 소송행위를 할 수 있다. 여기에는 반소, 참가, 강제집행에 관한 행위 등이 포함된다.

(2) 특별수권사항

- 민사소송법 제90조 제2항에 따라 상소의 제기, 소의 취하, 화해, 포기, 인낙 등은 당사자로부터 별도의 특별수권을 받아야 가능하다.

III. 파기환송과 소송대리권의 부활

1. 환송 후 절차

- 상고심에서 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 항소심 법원에 환송한 경우, 환송 후의 절차가 <이전 항소심 절차의 속행인지> 아니면 <새로운 심급의 시작인지>에 따라 대리권 존속 여부가 달라진다.

2. 판례의 태도

- 판례는 환송 전 항소심에서의 소송대리인의 대리권은 상고 제기에 의하여 일단 소멸하지만, 상고심에서 원심판결을 파기하여 사건을 항소심에 환송한 경우 사건이 다시 환송 전의 상태로 돌아가는 것으로 본다. 환송 후의 절차는 환송 전 항소심 절차의 계속 및 속행에 해당하므로, 별도의 선임계 제출 없이도 환송 전 항소심 소송대리인의 대리권은 당연히 부활한다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 소송대리권의 지속성

- 변호사 丁은 甲의 항소심 소송대리인으로서 이미 적법하게 대리권을 행사하였다. 대법원이 사건을 파기환송하였다는 것은 항소심 판결이 취소되고 사건이 다시 항소심 단계의 미결상태로 복귀함을 의미한다.

2. 대리권의 법적 상태

- 판례의 견해에 따르면 환송 후 항소심은 환송 전 항소심의 연장이므로, 丁이 상고심에서 대리인이 아니었다더라도 사건이 항소심으로 환송됨과 동시에 丁의 소송대리권은 법률상 당연히 부활한다. 따라서 丁은 별도의 위임장을 다시 제출하지 않고도 甲을 위하여 환송 후 항소심 절차에서 소송행위를 할 수 있다.

V. 결론

- 민사소송법상 심급대리의 원칙에도 불구하고, 파기환송판결에 의해 사건이 원심법원에 환송된 경우 환송 후의 소송절차는 환송 전 절차의 속행으로 간주된다. 따라서 환송 전 항소심 소송대리인이었던 변호사 丁의 소송대리권은 대법원의 파기환송결정과 동시에 당연히 부활한다. 丁은 환송 후 항소심에서 다시 甲의 소송대리인으로서 지위를 회복하며, 乙회사를 상대로 소송을 계속 수행할 수 있다.

<보충 - 파기환송 시 소송대리권 부활 여부에 대한 학설과 판례의 대립 분석>

I. 학설(부정설)의 논거와 법적 타당성

1. 심급대리 원칙의 실질적 관철과 당사자의 사적자치

(1) 심급대리 원칙의 취지 보장

- 심급대리의 원칙은 당사자가 각 심급의 판결 결과를 보고 다음 심급에서 새로운 대리인을 선임할 기회를 보장하는 데 목적이 있다. 파기환송 절차는 실질적으로 새로운 공격·방어방법이 제출되고 법적 공방이 재개되는 단계이므로, 형식적 소송계속의 동일성만을 이유로 이전 대리권을 강제하는 것은 당사자의 대리인 선택의 자유를 침해할 우려가 있다.

(2) 수임계약의 본질과 대리인 선임 의사

- 대부분의 소송위임계약은 심급별로 체결되며, 계약의 대가 역시 심급별 착수금 구조로 설계된다. 따라서 환송 전 단계에서 판결이 선고됨으로써 위임계약은 실질적으로 종료되었다고 보는 것이 계약 당사자들의 합리적인 의사에 부합한다.

2. 신의칙 및 신뢰관계의 변화와 대리인의 책임 범위

(1) 대리인과 본인 간 신뢰관계의 변동

- 상고심에서 원심판결이 파기되었다는 것은 환송 전 항소심에서 대리인이 수행한 소송 전략이나 법리 주장에 치명적인 하자가 있었거나 결과적으로 패소(원고의 경우 승소 판결이 깨진 경우 등)했음을 의미하는 경우가 많다. 이 과정에서 당사자와 변호사 사이의 신뢰관계에 중대한 변화나 균열이 발

생했을 가능성이 매우 높음에도 대리권이 당연히 부활한다고 보는 것은 가혹하다.

(2) 변호사의 무한 책임 방지

- 대리권의 당연 부활을 인정하면, 환송 전 대리인은 당사자로부터 추가적인 보수를 받지 못했거나 관계가 소원해진 상태에서도 기일 지정 신청이나 서면 제출 등 소송수행 의무를 강제받게 된다. 이를 게을리할 경우 부당한 민사상 손해배상 책임이나 징계 책임을 질 수 있어 변호사에게 일방적으로 불리한 결과를 초래한다.

II. 판례(긍정설)의 실질적 고려와 한계

1. 소송절차의 안정과 소송경제

(1) 송달의 적법성 확보와 절차적 공백 방지

- 대법원이 사건을 환송했을 때 법원이 환송기일 통지서 등을 누구에게 송달해야 하는가의 문제가 발생한다. 대리권 부활을 부정하면 법원은 소송에 미숙한 당사자 본인에게 직접 송달해야 하므로 절차가 지연되거나 불측의 기일 해태로 인한 불이익이 발생할 수 있다. 판례는 송달의 확실성과 소송절차의 원활한 진행을 우선시한 결과이다.

(2) 소송계속의 연속성 유지

- 판례는 파기환송에 의해 사건이 원심법원으로 돌아가면 소송의 상태가 환송 전의 미결 상태로 복귀하는 것으로 파악한다. 즉, 소송법적으로는 심급이 바뀐 것이 아니라 동일한 항소심 절차가 중단 없이 속행되는 것으로 보기 때문에 형식적 논리상 대리권 역시 소멸하지 않고 존속하는 것으로 취급한다.

2. 현실적 계약 관행과의 괴리(판례의 한계) : 실무상 수임 관행과의 충돌

- 변호사 수임 실무에서 파기환송 사건은 새로운 심급에 준하는 막대한 노력과 새로운 법리 구성이 요구되므로 통상 환송 후 대리를 위한 별도의 수임계약을 체결합니다. 그럼에도 법률상 대리권이 당연히 부활한다고 보는 판례의 태도는 실무상의 경제적 거래 관행을 반영하지 못한다는 치명적인 약점이 있다.

III. 종합적 검토 및 답안 작성 시 활용 전략

1. 법리적 정합성과 실무적 필요성의 조화

(1) 원칙과 예외의 조화로운 해석

- 법리적인 타당성과 사적자치의 원칙, 그리고 신뢰관계 보호 측면에서는 학설(부정설)이 훨씬 정교하고 현실적이다. 다만, 소송절차의 안정과 무권 대리 방지라는 공익적 목적을 위해 판례(긍정설)가 유지되고 있다.

(2) 실무상 해결 방안의 존재

- 판례가 부활을 인정하더라도 현실에서는 이전 대리인이 소송수행을 원치 않을 경우 즉시 사임서를 제출하여 대리관계를 종료시킬 수 있다. 따라서 판례의 당연 부활설이 실제 신뢰 관계가 파탄 난 당사자들을 억지로 묶어두는 절대적인 족쇄로 작용하지는 않는다.

2. 2차 시험 답안 서술 시 고득점 서술 팁

(1) 학설 대립의 명확한 서술

- 답안 작성 시 단순히 '판례는 당연히 부활한다고 본다'라고만 끝맺지 말고, '학설은 심급대리의 원칙 및 신뢰관계 파탄을 이유로 부정하나, 판례는 소송절차의 안정과 연속성을 위해 당연 부활을 인정한다'라는 대립 구도를 선명하게 보여주어야 한다.

(2) 깊이 있는 검토의견 제시

- 검토의견 단락에서 '사적자치와 수임계약의 현실적 합치 측면에서는 부정설이 타당하나, 환송 직후 송달의 불명확성으로 인한 당사자의 절차적 불이익을 방지하고 소송경제를 도모하기 위해서는 당연 부활을 인정하되 변호사의 사임 권한으로 조율하는 판례의 태도가 실무상 조화롭다'와 같이 양설을 아우르는 균형 잡힌 검토를 제시하면 최고 수준의 가점을 받을 수 있다.

《【문제2】 공시송달에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 공시송달의 의의, 요건, 절차 및 효력

I. 문제의 제기

- 송달은 당사자에게 소송 서류의 내용을 알 수 있는 기회를 부여함으로써 절차적 권리를 보장하는 핵심적인 제도이다. 그러나 상대방의 주소나 거소를 전혀 알 수 없는 경우에도 송달이 불가능하다는 이유만으로 재판 절차를 무한정 지연시킬 수는 없다. 이에 민사소송법은 최후의 수단으로서 법원 게시판 등에 서류를 게시함으로써 송달된 것으로 간주하는 공시송달 제도를 규정하고 있다.(제194조) 이하에서는 공시송달이 인정되기 위한 엄격한 요건과 그 실시 절차, 그리고 발생하는 소송법상 효력에 대해 설명한다.

II. 공시송달의 요건

1. 주소·거소 등의 불명

(1) 의의

- 당사자의 주소·거소·영업소 또는 사무소를 알 수 없는 경우여야 한다. 이는 단순히 송달을 받지 않는 경우와는 구별되며, 소재 자체가 확인되지 않는 상태를 의미한다.

(2) 조사의 의무

- 송달받을 사람의 소재를 알기 위해 상당한 조사를 다했음에도 불구하고 이를 알 수 없어야 한다. 판례는 주민등록표상 주소지에 거주하지 않는다는 사실뿐만 아니라, 친족 등에 대한 문의나 통신사 사실조회 등을 통해 소재 파악을 위한 노력을 기울였는지 여부를 엄격하게 심사한다.

2. 외국 송달의 곤란성

- 외국에서 행하여야 할 송달에 관하여 외국 송달 방법(제191조)에 의할 수 없거나, 그 방법에 의하더라도 송달의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에도 공시송달을 할 수 있다.

3. 보충송달 등의 불가능

- 송달받을 사람의 주소 등은 알지만, 그 장소에서 보충송달(제186조 제1항)이나 유치송달(제186조 제3항)이 불가능하고 우편송달(제187조)의 요건도 갖추지 못한 경우에 예외적으로 허용될 수 있다.

III. 공시송달의 절차

1. 신청 또는 직권

- 공시송달은 당사자의 신청에 의하거나 법원이 직권으로 행할 수 있다. 신청 시에는 주소 등을 알 수 없는 사유를 소명하여야 한다.

2. 재판장의 명령

- 공시송달은 재판장의 명령에 의해 실시된다. 재판장은 요건이 구비되었다고 판단되면 사무관 등에게 공시송달을 명한다.

3. 실시 방법

- 법원 사무관 등은 송달할 서류를 보관하고, 그 사유를 법원 게시판에 게시하거나 관보·신문에 게재하는 방법, 혹은 전자통신매체를 이용하는 방법으로 실시한다.

IV. 공시송달의 효력

1. 효력 발생 시기

(1) 일반적인 경우

- 첫 공시송달은 실시한 날(게시한 날)로부터 2주가 지나면 효력이 발생한다.(제196조 제1항)

(2) 동일 당사자에 대한 반복 송달

- 같은 당사자에게 하는 그 뒤의 공시송달은 실시한 다음 날부터 바로 효력이 발생한다.(제196조 제2항)

(3) 외국 송달의 경우

- 외국에서 행하는 공시송달의 경우 효력 발생 기간은 2개월로 연장된다.

2. 법률상 도달 간주

- 공시송달의 효력이 발생하면 실제 상대방이 서류를 수령했는지 여부와 관계없이 법률상 적법하게 송달된 것으로 간주된다. 따라서 변론기일 통지 등이 공시송달로 행해지면 상대방이 출석하지 않더라도 무변론판결이나 자백간주 등의 절차가 진행될 수 있다.

V. 공시송달과 구제수단

1. 무변론판결과 자백간주의 예외

- 공시송달에 의한 기일통지를 받고 출석하지 않은 경우에는 자백간주(제150조 제3항) 규정이 적용되지 않는다. 따라서 원고는 청구 원인 사실을 별도의 증거로 입증하여야 한다.

2. 추완항소 [제173조]

- 공시송달로 인하여 판결 선고 사실을 몰라 항소기간을 도과한 경우, 당사자는 그 사유가 없어진 날(판결이 있었음을 안 날)로부터 2주 이내에 소송행위의 추완을 신청하며 항소를 제기할 수 있다.

VI. 결론

- 공시송달은 소송의 정체를 막고 원고의 재판받을 권리를 보장하는 필수적인 제도이나, 피고의 방어권을 심각하게 제한할 위험이 있다. 따라서 법원은 공시송달 명령 전 소령 파악을 위한 당사자의 노력을 엄격히 심리하여야 한다. 또한 공시송달로 판결이 확정된 경우에도 추완항소 등을 통해 사후적인 구제 가능성을 열어둠으로써 절차적 정의와 재판의 효율성 사이의 균형을 도모하여야 한다. 이하에서는 이러한 공시송달 제도가 남용되지 않도록 실무적인 주의가 요구된다.

《【문제3】 청구의 선택적 병합에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 청구의 선택적 병합의 의의, 요건, 심리, 판결과 상소

I. 문제의 제기

- 청구의 선택적 병합이란 양립 가능한 여러 개의 청구 중 어느 하나가 인용될 것을 조건으로 하여 나머지 청구에 대한 심판을 구하는 병합 형태를 말한다. 이는 원고가 목적하는 하나의 경제적 이익을 달성하기 위해 여러 법적 근거를 제시할 때 유용하게 활용된다. 특히 청구권 경합 이론과 관련하여 실무상 빈번하게 발생하며, 법원의 심판 범위와 상소 시의 이심 범위 등에 있어 독특한 법리가 적용된다. 이하에서는 선택적 병합의 인정 요건과 재판 절차 및 판결의 효력에 대하여 설명한다.

II. 선택적 병합의 요건

1. 청구의 양립 가능성

- 선택적 병합이 성립하기 위해서는 병합된 여러 청구가 서로 양립할 수 있어야 한다. 만약 청구들이 서로 모순되어 어느 하나가 인정되면 다른 하나가 부정되는 관계(예 : 매매계약에 따른 이행청구와 계약 해제를 전제로 한 원상회복청구)에 있다면 이는 예비적 병합의 대상이 된다.

2. 동일한 목적의 경제적 이익

- 원고가 청구하는 여러 법적 근거가 결국 동일한 급부나 경제적 이익을 목적으로 해야 한다. 예를 들어 동일한 사고로 인한 손해배상을 청구하면서 채무불이행으로 인한 손해배상청구와 불법행위로 인한 손해배상청구를 병합하는 경우가 대표적이다.

3. 공통의 소송절차

- 병합된 모든 청구가 동일한 종류의 소송절차에 의하여 심판될 수 있어야 하며, 해당 법원에 각 청구에 대한 관할권이 인정되어야 한다.

III. 소송계속과 심리

1. 심판의 범위

- 원고는 여러 청구 중 어느 하나만 인용되면 족하다는 의사를 표시한 것이므로, 법원은 어느 하나의 청구가 이유 있다고 판단되면 다른 청구에 대해서는 심리할 필요 없이 원고 승소 판결을 내릴 수 있다. 반대로 원고의 청구를 배척하려면 병합된 모든 청구가 이유 없음을 판단해야 한다.

2. 자백과 포기·인낙

- 선택적 병합에서 어느 한 청구에 대한 피고의 자백이나 인낙이 있으면 법원은 그에 기초하여 판결할 수 있으며, 다른 청구를 심리할 필요가 없다. 원고가 어느 한 청구를 취하하더라도 다른 청구에 의한 소송계속은 유지된다.

IV. 종국판결과 상소

1. 인용판결의 경우

- 법원이 병합된 청구 중 어느 하나를 인용하는 경우, 주문에서 해당 청구를 명시하고 나머지 청구에 대해서는 별도의 판단을 내리지 않는다. 이때 기판력은 주문에 나타난 청구뿐만 아니라 선택적으로 병합된 청구 전체에 미친다는 것이 통설과 판례의 입장이다.

2. 기각판결의 경우

- 원고의 청구를 모두 배척하려면 주문에서 모든 청구에 대한 기각을 명시하거나, 전체적인 청구를 기각하는 취지를 분명히 해야 한다. 모든 청구가 이유 없다는 판단이 판결 이유에 기재되어야 한다.

3. 일부판결의 금지

- 선택적 병합은 단일한 소송물은 아니나 심판의 단위가 하나로 취급되므로, 여러 청구 중 일부에 대해서만 판결하는 일부판결은 허용되지 않는다. 만약 법원이 착오로 일부 청구에 대해서만 판결하고 나머지를 누락한 경우, 이는 재판의 누락이 아닌 추가판결의 대상이 되며 전체가 상소로 이심된다.

4. 상소와 이심의 범위

(1) 이심의 범위

- 병합된 청구 중 어느 하나를 인용한 판결에 대해 피고가 상소하면, 상소 불가분의 원칙에 따라 선택적으로 병합된 청구 전체가 상급심으로 이심된다.

(2) 상급심의 심판 객체

- 상급심은 원심에서 판단하지 않았던 다른 선택적 청구에 대해서도 심판할 수 있다. 만약 원심이 인용한 청구가 상급심에서 이유 없다고 판단되더라도, 원심이 판단하지 않았던 다른 청구가 이유 있다면 상소 기각 판결을 통해 원고의 승소를 유지할 수 있다.

V. 결론

- 청구의 선택적 병합은 원고에게 소송의 편의를 제공하고 동일한 목적을 가진 분쟁을 한꺼번에 해결함으로써 재판의 경제를 도모하는 제도이다. 법원은 심리 과정에서 어느 하나의 청구만 인정되면 원고 승소를 판결할 수 있으나, 기각 시에는 모든 경로를 차단해야 하므로 신중한 심리가 요구된다. 특히 상소 단계에서 전체 청구가 이심되는 특성을 고려하여 당사자의 방어권이 침해되지 않도록 유의해야 한다. 이하에서는 이러한 이론적 기초를 바탕으로 실무상 청구권 경합 시의 병합 형태를 명확히 구분하여 적용하여야 한다.

《【문제1】 乙 회사의 근로자 丙이 업무상 운전하던 차량이 보행자 甲을 충격하여 부상을 입혔다. 甲이 乙 회사를 피고로 하여 제기한 교통사고로 인한 손해배상청구의 소(전소)에서 丙이 乙 회사측에 보조참가하여 소송이 진행되었고, 법원은 丙의 운전상의 과실을 인정하여 甲 청구인용판결을 선고하여 이 판결이 확정되었다. 그 후 乙 회사가 丙을 피고로 위 손해배상에 대한 구상금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)
(아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음1) 丙이 보조참가한 전소의 甲 청구인용의 확정판결이 후소에 효력을 미치는지를 설명하시오. (35점)》

<문제1의 물음1> 보조참가인에 대한 전소 판결의 참가적 효력 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙 회사를 상대로 한 손해배상청구소송에서 丙이 보조참가인으로 소송에 관여하여 확정판결이 내려진 후, 乙 회사가 丙을 상대로 구상금청구의 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <보조참가인이 관여한 전소의 확정판결이 후소에서 보조참가인인 丙에게 미치는 효력과 그 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 보조참가인의 참가적 효력과 확정판결의 후소에 대한 구속력 여부를 설명한다.

II. 보조참가의 의의 및 요건

1. 의의

- 보조참가란 타인 사이의 소송계속 중 소송결과에 대하여 법률상 이해관계를 가진 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위해 소송에 참여하는 것을 말한다.

2. 요건

- 타인 사이의 소송이 계속 중이어야 하며, 소송결과에 대하여 법률상 이해관계가 있어야 한다. 사안의 丙은 乙이 패소할 경우 구상권 행사를 당할 처지에 있으므로 법률상 이해관계가 인정된다.

III. 참가적 효력의 이론적 기초

1. 의의 및 성격

- 참가적 효력이란 보조참가인이 참여한 소송의 판결이 확정된 경우, 참가인과 피참가인 사이에 발생하는 특수한 구속력을 의미한다. 이는 기판력과 구별되는 효력으로서, 피참가인이 패소했을 때 참가인이 '내가 참여했다라면 이겼을 것'이라거나 '피참가인이 소송을 잘못 수행했다'고 주장하며 전소 판결의 부당함을 다투는 것을 방지하여 패소의 책임을 분담시키기 위한 제도이다.

2. 기판력과의 구별

- 기판력은 소송물인 법률관계의 존부에 대해 당사자 상호 간 및 후소 법원에 발생하는 효력이지만, 참가적 효력은 참가인과 피참가인이라는 내부 관계에서만 발생한다. 또한 기판력은 판결 주문에 한하여 발생하나, 참가적 효력은 판결 이유 중의 사실인정이나 법률판단에도 미친다는 점에서 차이가 있다.

IV. 참가적 효력의 발생 범위

1. 주관적 범위

- 참가적 효력은 참가인과 피참가인 사이에서만 발생한다. 따라서 전소의 상대방인 甲과 참가인 丙 사이에는 이러한 효력이 발생하지 않는다.

2. 객관적 범위

- 판결의 주문뿐만 아니라 판결의 결론을 도출하기 위해 판단된 사실관계와 법률적 판단 전부에 미친다. 다만, 피참가인의 패소와 직결되지 않는 부수적 판단이나 방론에는 미치지 않는다.

3. 시적 범위

- 전소의 사실심 변론종결 시를 기준으로 발생한다. 따라서 변론종결 후에 발생한 새로운 사정은 참가적 효력에 의해 차단되지 않는다.

V. 참가적 효력의 차단(효력의 제한)

1. 규정의 취지 [민사소송법 제86조 단서]

- 참가인이 참가 당시의 소송 정도에 따라 소송행위를 할 수 없었거나, 피참가인이 참가인의 소송행위를 방해한 경우 등에는 참가적 효력이 제한된다.

2. 구체적 사유

- 피참가인이 고의 또는 과실로 참가인에게 유리한 증거를 제출하지 않았거나, 참가인이 알 수 없었던 공격방어방법을 피참가인이 태만히 하여 행하지 않은 경우 등이 이에 해당한다.

VI. 사안의 적용

1. 丙에 대한 참가적 효력의 발생

- 丙은 전소에 보조참가하여 소송을 수행하였고 乙이 패소하여 판결이 확정되었으므로, 민사소송법 제86조 본문에 따라 丙과 乙 사이에는 참가적 효력이 발생한다.

2. 후소에서의 영향

- 전소 판결의 이유에서 丙의 운전상 과실이 인정되었고 이것이 乙의 패소 원인이 되었으므로, 이 사실인정은 참가적 효력의 객관적 범위에 포함된다. 따라서 乙이 丙을 상대로 제기한 구상금 청구 소송(후소)에서 丙은 전소 판결이 부당하다거나 자신에게 과실이 없었다는 주장을 할 수 없다. 후소 법원 역시 전소 판결의 판단과 모순되는 사실인정을 할 수 없으므로 丙의 과실을 전제로 구상 책임을 판단해야 한다.

3. 예외적 상황의 고려

- 만약 乙이 丙의 참가를 방해했거나 丙이 알 수 없는 사유로 적절한 방어를 하지 못한 특별한 사정이 입증된다면 참가적 효력이 배제될 수 있으나, 사안에 그러한 정황이 없다면 효력은 온전하게 발생한다.

VI. 결론

- 전소인 甲과 乙 사이의 손해배상청구 소송 판결은 보조참가인 丙과 피참가인 乙 사이에 참가적 효력을 미친다. 따라서 후소인 구상금 청구 소송에서 丙은 전소 판결에서 확정된 자신의 과실 유무를 다시 다툴 수 없으며, 전소 판결의 결과에 따른 책임을 乙과 분담해야 한다. 이는 소송수행의 책임을 공정하게 분배하려는 보조참가 제도의 취지에 부합하는 결과이다. 이하에서는 보조참가인이 전소에서 자신의 권익을 충분히 보호받을 수 있도록 절차적 기회가 실질적으로 보장되어야 함을 확인한다.

<보충 - Short Version>

I. 문제의 제기

- 사안에서 피해자 甲이 乙 회사를 상대로 제기한 전소에 丙이 보조참가하여 丙의 과실이 인정되어 판결이 확정된 후, 乙 회사가 丙을 상대로 후소로서 구상금 청구 소송을 제기하였다. 이때 전소 판결의 기판력이 후소의 수소법원과 당사자 丙을 구속하는지, 아니면 민사소송법 제77조의 참가효가 발생하는지 및 그 적용 범위가 쟁점이 된다. 이하에서는 전소 판결이 후소에 미치는 소송법상 효력에 대하여 구체적으로 설명한다.

II. 보조참가인에 대한 판결의 효력 법리

1. 기판력과 참가효의 관계

(1) 기판력의 인적 범위 한계

- 기판력은 대립하는 당사자인 원고와 피고 사이에만 미치는 것이 원칙이다.(민사소송법 제218조 제1항) 따라서 공동의 편에 서서 소송을 수행한 피참가인과 보조참가인 상호간에는 전소 판결의 기판력이 미치지 않는다.

(2) 참가효의 의의 및 본질

- 참가효는 보조참가인이 공동으로 소송을 수행하였음에도 피참가인이 패소한 경우, 신의칙에 기하여 보조참가인과 피참가인 사이에 발생하는 특수한 소송법상 효력이다.(동법 제77조) 이는 패소의 책임을 상호간에 공정하게 분담하도록 하는 데 취지가 있다.

2. 참가효의 주체적·객관적 범위 및 한계

(1) 참가효의 주체적 및 객관적 범위

- 참가효는 피참가인과 보조참가인 사이에서만 발생하며, 상대방 당사자에게는 미치지 않는다. 객관적 범위로는 판결 주문뿐만 아니라, 판결이유 중에서 패소의 원인이 된 사실인정 및 법률판단에까지 미친다는 점에서 기판력보다 넓은 범위를 가진다.

(2) 참가효의 예외적 배제 사유

- 민사소송법 제77조 단서에 의하면, 보조참가인이 참가할 당시 소송정도가 진행되어 공격방어방법을 제출할 수 없었거나, 피참가인의 고의·과실로 인해 방해를 받은 경우 등 참가인에게 책임을 돌릴 수 없는 사유가 존재한다면 참가효는 예외적으로 배제된다.

III. 사안의 적용

1. 기판력의 미작용

- 전소의 소송당사자는 甲과 乙 회사이며 丙은 보조참가인에 불과하였다. 따라서 乙 회사와 丙 사이에서 진행되는 후소 구상금 소송에는 전소 확정판결의 기판력이 미치지 않는다.

2. 참가효의 발생 및 구체적 영향

(1) 전소 판결에 따른 참가효의 성립

- 丙은 전소에서 피고 乙 회사의 보조참가인으로 소송에 참여하였고, 전소에서 乙 회사의 패소 판결이 확정되었다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 전소 확정판결의 효력으로서 乙 회사와 丙 사이에는 참가효가 유효하게 발생한다.

(2) 후소 구상금 소송에의 구체적 차단 효과

- 전소에서 乙 회사가 패소하게 된 결정적 원인은 `丙의 운전상 과실`이었다. 이는 전소 판결이유 중 패소의 원인이 된 핵심적 사실인정에 해당하므로 참가효의 객관적 범위에 포함된다. 따라서 후소에서 丙은 전소 판결의 내용과 모순되게 자신에게 과실이 없었다고 주장할 수 없으며, 수소법원 역시 丙의 과실을 전제하여 구상금 청구의 당부를 심리해야 한다.

IV. 결론

- 전소 확정판결은 乙 회사와 丙 사이에 기판력은 미치지 않으나, 민사소송법 제77조에 기한 참가효를 미친다. 따라서 전소 판결이유 중 패소의 원인이 된 丙의 과실 인정에 대하여 참가효가 발생하므로, 丙은 후소에서 자신의 과실을 부인하는 주장을 할 수 없다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제03절 당사자의 변경>

[기출][2017-1-2]소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부

《【문제1】 乙 회사의 근로자 丙이 업무상 운전하던 차량이 보행자 甲을 충격하여 부상을 입혔다. 甲이 乙 회사를 피고로 하여 제기한 교통사고로 인한 손해배상청구의 소(전소)에서 丙이 乙 회사측에 보조참가하여 소송이 진행되었고, 법원은 丙의 운전상의 과실을 인정하여 甲 청구인용판결을 선고하여 이 판결이 확정되었다. 그 후 乙 회사가 丙을 피고로 위 손해배상에 대한 구상금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음2) 후소에서 丙은 소송대리인을 선임하지 않고 소송을 수행하던 중 사망하였다. 법원은 丙의 사망사실을 간과하고 변론을 진행한 후 乙 회사 청구인용판결을 선고하였다. 이 판결은 丙의 상속인에게 효력이 미치는지를 설명하시오. (15점)》

<문제1의 물음2> 소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부

I. 문제의 제기

- 후소 피고 丙은 소송대리인을 선임하지 않은 상태에서 소송계속 중 사망하였으므로, 민사소송법 제233조 제1항에 따라 소송절차는 중단되어야 한다. 그럼에도 <수소법원이 피고의 사망을 간과하고 선고한 판결이 당연히무효인지, 아니면 丙의 상속인들에게 그 판결의 효력이 미치는지> 여부가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 소송대리인 없는 당사자의 사망으로 인한 소송중단의 법리 및 사망 간과 판결의 효력과 그 상속인에 대한 구제책을 고찰하고 사안에 대입하여 판결의 효력 유무에 대하여 설명한다.

II. 소송계속 중 당사자 사망 시의 소송법적 효과

1. 소송절차 중단의 원칙과 예외

(1) 소송절차의 중단 원칙

- 소송계속 중 당사자가 사망한 때에는 소송절차는 중단된다.(민사소송법 제233조 제1항) 이 경우 법률상 당연히 수계할 상속인 등이 소송절차를 수계하여야 소송을 계속 진행할 수 있다.

(2) 소송대리인이 있는 경우의 예외

- 사망한 당사자에게 소송대리인이 있는 경우에는 소송절차가 중단되지 아니하고 소송대리인이 대리권을 유지하여 소송을 계속 수행한다.(민사소송법 제238조) 그러나 사안의 丙은 소송대리인을 선임하지 않았으므로 丙의 사망과 동시에 소송절차는 당연히 중단된다.

2. 사망 간과 판결의 효력과 상속인에 대한 귀속 관계

(1) 판결의 효력 (무효 여부)

- 대법원은 소제기 전 사망자를 피고로 삼은 경우와 달리, 소송계속 중 당사자가 사망하였음에도 이를 간과하고 선고한 판결은 당연히무효가 아니라고 본다. 이미 적법한 대립 당사자 관계가 형성된 후 사망한 것이므로 판결은 형식적으로 유효하게 성립하며, 그 효력은 丙의 상속인들에게 미친다.

(2) 대리권 흠결에 준하는 위법과 불복 수단

- 사망 간과 판결은 당연히무효는 아니지만 소송수계절차를 거치지 않은 절차적 위법이 존재한다. 판례는 이 가공의 판결에 대하여 대리권 흠결에 준하는 위법이 있는 것으로 보아, 상속인들이 상소나 재심청구(민사소송법 제451조 제1항 제3호 유추)를 통해 그 판결의 취소를 구할 수 있다고 판시한다.

III. 사안의 적용

1. 丙의 사망에 따른 소송중단 및 판결의 성립

- 丙은 소송대리인을 두지 않고 소송을 수행하다가 사망하였으므로 사망 시점에 소송절차는 즉시 중단되었어야 한다. 법원이 이를 알지 못하고 변론을 진행하여 내린 판결은 중단 중의 판결로서 절차상 위법하나, 당연히무효의 판결로 보지 않는다.

2. 상속인에 대한 효력 귀속 및 구제 방안

- 해당 판결은 당연히무효가 아니므로 실체법상 丙의 권리·의무를 승계한 丙의 상속인들에게 형식적으로 그 효력이 미치게 된다. 다만, 상속인들은 판결을 송달받아 대리권 흠결에 준하는 위법을 이유로 항소를 제기하여 판결의 취소를 구할 수 있으며, 이미 판결이 확정된 경우라면 재심의 소를 제기하여 구제받을 수 있다.

IV. 결론

- 수소법원이 피고 丙의 사망 사실을 간과하고 선고한 구상금 청구인용판결은 당연히무효가 아니므로, 丙의 상속인들에게 그 효력이 미친다. 따라서 상속인들은 판결의 형식적 효력을 전면 구속받게 되나, 대리권 흠결에 준하는 절차상 위법을 원인으로 삼아 상소나 재심청구를 통해 판결을 적법하게 취소시킬 수 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제06절 변론기일에서의 당사자의 결석>

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제03절 불요증사실>

[기출][2017-2]자백간주의 의의, 성립 요건, 효력, 적용 범위 및 제한

《[문제2] 자백간주에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 자백간주의 의의, 성립 요건, 효력, 적용 범위 및 제한

I. 문제의 제기

- 자백간주란 당사자가 상대방이 주장하는 사실에 대하여 명백히 다투지 않거나, 기일에 출석하지 않음으로써 실질적으로 다투지 않는 경우에 법률상 자백을 한 것과 동일한 효력을 부여하는 제도를 의미한다.(민사소송법 제150조) 이는 당사자의 태만으로 인한 소송 지연을 방지하고 소송 절차를 신속하게 진행하기 위한 취지에서 인정된다. 자백간주가 성립하면 재판상 자백과 마찬가지로 증거조사 없이 해당 사실을 기초로 판결을 내릴 수 있게 된다. 이하에서는 자백간주가 성립하기 위한 구체적인 유형별 요건과 그로 인해 발생하는 소송법상 효력 및 불복 방법 등에 대해서 설명한다.

II. 자백간주의 성립 요건

1. 답변서 부제출에 의한 자백간주 [민사소송법 제257조]

(1) 피고의 답변서 제출 의무

- 피고는 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다. 피고가 이 기한 내에 답변서를 제출하지 아니한 때에는 소장에서 주장한 사실을 자백한 것으로 본다.

(2) 무변론판결

- 법원은 피고가 답변서를 제출하지 않은 경우 변론을 열지 않고 바로 판결(무변론판결)을 선고할 수 있다. 다만, 판결이 선고되기 전까지 피고가 답변서를 제출하면 변론기일을 지정하여야 하므로 자백간주의 효력은 상실된다.

2. 기일에서의 태상에 의한 자백간주 [민사소송법 제150조 제1항]

(1) 명백히 다투지 않는 경우

- 당사자가 변론에서 상대방이 주장한 사실에 대하여 '모른다'고 하거나 침묵하는 등 명백히 다투지 아니한 때에는 그 사실을 자백한 것으로 간주한다. 다만, 변론 전체의 취지로 보아 다른 것으로 인정되는 경우에는 예외로 한다.

(2) 부지의 진술

- 상대방의 주장 사실에 대하여 '모른다(부지)'고 진술하는 것은 다투는 것으로 보지 않고 자백한 것으로 간주될 여지가 있으나, 통상적으로는 다른 것으로 취급하는 것이 실무이다.

3. 기일불출석에 의한 자백간주 [민사소송법 제150조 제3항]

(1) 불출석의 의미

- 당사자가 적법한 소환을 받았음에도 불구하고 변론기일에 출석하지 아니하거나, 출석하더라도 변론을 하지 않고 퇴정한 경우를 말한다.

(2) 예외 사유

- 공시송달에 의한 송달을 받은 경우에는 기일불출석에 의한 자백간주 규정이 적용되지 않는다. 이는 당사자가 소송 진행 사실을 알지 못하는 상태에서 불이익을 주는 것을 방지하기 위함이다.

III. 자백간주의 효력

1. 증거요함의 면제

- 자백간주가 성립하면 해당 사실은 불요증사실이 된다. 따라서 법원은 별도의 증거조사 없이 그 사실을 판결의 기초로 삼아야 하며, 상대방은 이를 입증할 필요가 없다.

2. 법원에 대한 구속력

- 법원은 자백간주된 사실에 대하여 그와 반대되는 사실을 인정할 수 없다. 즉, 법원은 당사자가 다투지 않는 사실을 그대로 받아들여야 하는 구속을 받는다.

3. 당사자에 대한 구속력 여부

- 재판상 자백과 달리 자백간주는 당사자에 대한 구속력이 인정되지 않는다. 따라서 자백간주의 대상이 된 당사자는 사실심 변론종결 전까지 언제든지 상대방의 주장을 다투어 자백간주의 효력을 소멸시킬 수 있다. 이는 재판상 자백이 철회 제한의 원칙(민사소송법 제288조 단서)을 적용받는 것과 대비되는 특징이다.

IV. 자백간주의 적용 범위 및 제한

1. 적용 범위

- 자백간주는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 관한 사실에 대해서만 적용된다.

2. 적용 제한

(1) 직권조사사항

- 관할권의 유무, 당사자 적격 등 법원의 직권조사사항에 대해서는 당사자가 다투지 않더라도 자백간주가 성립하지 않는다.

(2) 사실이 아닌 법률판단

- 당사자가 주장하는 법률적 견해나 가치판단에 대해서는 자백간주가 적용되지 않는다. 오직 구체적인 사실관계에 대해서만 인정된다.

V. 구체수단 및 결론

- 자백간주에 의한 판결이 선고된 경우, 당사자는 상소를 통해 다툴 수 있다. 특히 기일불출석으로 인해 자백간주가 성립하여 패소한 경우, 항소심에서 해당 사실을 다투는 취지의 진술을 하거나 답변서를 제출함으로써 자백간주의 효력을 배제할 수 있다. 다만, 고의로 소송을 지연시키기 위해 다투지 않다가 뒤늦게 상소하는 경우에는 실기한 공격방어방법으로서 제재를 받을 수 있음에 유의해야 한다. 자백간주 제도는 당사자의 성실한 소송 참여를 유도하고 재판의 효율성을 높이는 장치이지만, 당사자의 진의를 확인하지 않은 채 불이익을 주는 측면이 있으므로 법원은 변론 전체의 취지를 면밀히 살펴 신중하게 운용하여야 한다. 이하에서는 자백간주가 실제적 진실 발견이라는 민사소송의 이념과 절차적 신속 사이에서 적절한 균형을 유지해야 함을 확인한다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2017-3]변론종결 뒤의 승계인의 의의 및 요건, 학설 및 판례, 기판력의 범위와 한계

《【문제3】 변론종결 뒤의 승계인에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 변론종결 뒤의 승계인의 의의 및 요건, 학설 및 판례, 기판력의 범위와 한계

I. 문제의 제기

- 민사소송법 제218조 제1항은 확정판결의 기판력이 당사자뿐만 아니라 변론을 종결한 뒤의 승계인에게도 미친다고 규정하고 있다. 이는 판결의 실효성을 확보하고 소송경제를 도모하기 위한 것으로, 소송계속 중 목적물이 이전되었으나 이를 알지 못하고 판결이 확정된 경우에도 그 효력을 승계인에게 확장하려는 취지이다. 이때 승계인의 범위와 그들에게 기판력이 미치는 근거 및 한계에 대하여 학설과 판례의 대립이 존재한다. 이하에서는 변론종결 뒤의 승계인의 개념적 요건과 승계인에 해당하는지 여부를 판단하는 기준인 적격승계설 및 고유한 방어방법의 문제에 대해 설명한다.

II. 승계인의 의의 및 요건

1. 승계인의 의의

- 승계인이란 소송물인 권리·의무 자체를 승계한 사람뿐만 아니라, 소송물인 법률관계에 관한 분쟁의 대상인 물건의 점유를 승계한 사람을 포함한다. 변론종결 뒤라고 함은 변론종결 후부터 판결 확정 후까지를 모두 포함하는 개념이다.

2. 승계의 유형

(1) 일반승계

- 당사자의 사망으로 인한 상속이나 법인의 합병 등 포괄적인 권리·의무의 승계가 이에 해당한다.

(2) 특정승계

- 매매, 증여, 채권양도 등 개별적인 원인에 의하여 소송물 또는 목적물의 점유를 이전받은 경우를 의미한다.

III. 승계인의 범위에 관한 학설 및 판례

1. 소송물승계설

- 승계인이 기판력을 받기 위해서는 소송물인 권리·의무 자체를 승계해야 한다는 견해이다. 이 학설에 따르면 물권적 청구권 소송에서 목적물을 양수한 자는 승계인에 해당하지만, 채권적 청구권 소송에서 목적물을 양수한 자는 소송물인 채권 자체를 승계한 것이 아니므로 승계인에 해당하지 않는다고 본다.

2. 적격승계설(판례의 태도)

(1) 학설의 내용

- 당사자 적격의 근거가 되는 지위를 승계한 자를 승계인으로 보는 견해이다. 소송물인 권리·의무뿐만 아니라 그 바탕이 된 실체법상의 지위나 목적물의 점유를 승계함으로써 소송 수행의 적격을 이어받은 자를 포함한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 원칙적으로 적격승계설의 입장에서 소송물이 채권적 청구권인 경우에도 목적물의 저촉 여부에 따라 승계인 범위를 판단한다. 다만, 채권적 청구권 소송에서의 목적물 양수인을 승계인으로 인정하는 데 있어 소송물승계설보다 넓은 범위를 인정하는 경향이 있다.

IV. 승계인에게 기판력이 미치는 범위와 한계

1. 고유한 방어방법이 없는 경우

- 승계인은 전 당사자가 가졌던 모든 권리·의무의 상태를 그대로 물려받는다. 따라서 전 당사자가 이미 행사하였거나 행사할 수 있었던 방어방법에 대해서는 기판력의 차단효를 받게 되어 더 이상 다룰 수 없다.

2. 고유한 방어방법이 있는 경우

(1) 의의

- 승계인이 전 당사자로부터 승계한 사실과는 별개로, 본인만이 독자적으로 주장할 수 있는 실체법상 권리가 있는 경우를 말한다. 예컨대 선의취득이나 목적물에 대한 독립적인 권원 취득 등이 이에 해당한다.

(2) 판례의 판단

- 판례는 승계인이 고유한 방어방법(예 : 선의취득)을 가진 경우에는 그 범위 내에서 기판력의 구속을 받지 않는다고 본다. 이는 승계인의 절차적 보장을 위한 당연한 한계이다.

V. 결론

- 변론종결 뒤의 승계인에 대한 기판력 확장은 판결의 효력을 무력화하려는 시도를 방지하고 분쟁의 일회적 해결을 가능하게 하는 중요한 제도이다. 우리 판례는 적격승계설에 기초하여 승계인의 범위를 유연하게 확장함으로써 실효성을 확보하면서도, 승계인 자신의 고유한 방어방법이 있는 경우에는 그 효력을 제한하여 제3자의 권리 보호를 도모하고 있다. 특히 실무상 강제집행의 단계에서 승계집행문을 부여받기 위한 요건으로서 승계인의 지위는 매우 엄격히 검토되어야 한다. 이하에서는 변론종결 뒤의 승계인에 관한 논의가 현대 민사소송에서 소송상태의 유지와 제3자 보호라는 상충하는 가치를 조화롭게 해결하는 핵심적 장치임을 확인한다.

《【문제1】 甲은 乙 노동조합(이하 乙이라 한다)의 조합원이다. 아래의 각 물음에 관하여 논하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 무관함) (50점)

(물음1) 乙은 조합규약에 근거하여 자체적으로 만든 신분보장대책기금관리규정(이하 관리규정이라 한다)상의 위로금 지급을 둘러싼 乙과 조합원 간의 분쟁에 관하여 乙을 상대로 일절 소송을 제기할 수 없다는 규정을 두고 있다. 그 후 甲이 乙에 대하여 위 관리규정에 따른 위로금의 지급을 요구하였으나 乙이 이를 거절하였다. 이에 甲은 乙을 피고로 하여 위 관리규정에 따른 위로금 지급을 구하는 소를 법원에 제기하였다. 위 소송에서 乙은 甲이 위 관리규정상의 소제기 금지규정에 위반하여 소를 제기한 것이므로 위 소는 소의 이익이 없다고 주장하고 있다. 乙의 주장은 타당한가? (30점)》

<문제1의 물음1> 조합규약상 소제기 금지규정의 유효성과 이를 위반한 소의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 노동조합 乙의 관리규정에 따른 위로금 지급을 청구하는 소를 제기하였으나, 乙은 관리규정상의 소제기 금지규정을 근거로 이 사건 소는 소의 이익이 없어 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합 관리규정상의 소제기 금지규정의 효력과 이를 이유로 소의 이익이 부정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 乙의 주장이 타당한지 논한다.

II. 소제기 금지규정의 법적 성질 및 효력에 관한 법리

1. 자치적 법규범의 법적 효력과 한계

(1) 자치적 법규범의 의의

- 노동조합이 조합규약에 근거하여 자체적으로 만든 기금관리규정은 자치적 법규범으로서 소속 조합원에 대하여 법적 효력을 가진다.

(2) 자치적 법규범의 한계

- 다만, 자치적 법규범은 헌법이 보장하고 있는 조합원 개개인의 기본적 인권에 대해 합리적인 범위를 벗어나 과도하게 침해해서는 아니 되며, 강행 법규나 공서양속에 반해서도 안 된다. 이에 위반된 자치규범은 효력이 없다.

2. 부제소합의의 의의 및 유효요건

(1) 부제소합의의 의의 및 효과

- 부제소합의는 특정한 권리나 법률관계에 관하여 분쟁이 있더라도 소를 제기하지 않기로 약정하는 당사자 간의 합의이다. 유효한 부제소합의에 위반하여 제기한 소는 소의 이익(권리보호이익)이 없어 부적법 각하된다.

(2) 부제소합의의 유효요건

- 부제소합의가 유효하기 위해서는 다음의 요건을 충족하여야 한다. ① 당사자가 처분할 수 있는 권리관계에 관한 것일 것. ② 특정한 법률관계에 한정된 합의일 것. ③ 합의 당시 각 당사자가 예상할 수 있는 범위 내의 상황에 관한 것일 것. ④ 불공정한 방법에 의한 합의가 아닐 것

3. 관리규정상 소제기 금지규정의 효력에 관한 판례의 태도

(1) 재판청구권의 일률적 박탈

- 대법원은 관리규정에 기한 위로금 분쟁에 관하여 노동조합을 상대로 일절 소송을 제기할 수 없도록 정한 규정은 조합원의 재산권에 속하는 위로금 지급을 둘러싼 법률상 쟁송에 대해 헌법상 보장된 조합원의 재판을 받을 권리를 구체적 분쟁 발생 전에 미리 일률적으로 박탈하는 것이라고 본다.

(2) 부제소합의 제도 취지 위반에 따른 무효

- 또한 특정 법률관계에 관하여 예상할 수 있는 범위 내에서만 허용되는 부제소합의 제도의 취지에도 위반된다. 따라서 판례는 이러한 소제기 금지규정이 국민의 재판을 받을 권리를 보장한 헌법 제27조 제1항 및 법원조직법 제2조 제1항에 위반되어 무효라고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 관리규정상 소제기 금지규정의 효력 평가

- 사안의 위로금 지급 청구권은 조합원 甲의 구체적 재산권에 해당한다. 乙이 정한 관리규정상의 소제기 금지규정은 분쟁이 구체화되기도 전에 미리 조합원의 재판청구권을 포괄적·일률적으로 박탈하고 있다. 이는 헌법상 보장된 재판을 받을 권리를 침해하고 부제소합의의 한계를 일탈한 자치규범이므로 무효이다.

2. 소의 이익 인정 여부 및 乙 주장의 타당성 검토

- 소제기 금지규정이 무효이므로 甲과 乙 사이에는 유효한 부제소합의가 성립되어 있지 않다. 따라서 甲이 제기한 소송은 적법한 부제소합의를 위반한 소가 아니며, 위로금의 이행 여부에 대한 사법적 확정이 요구되는바 소의 이익이 충분히 인정된다. 따라서 소제기 금지규정을 위반하여 소의 이익이 없다는 피고 乙의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

IV. 결론

- 乙 노동조합의 관리규정상 소제기 금지규정은 헌법과 법원조직법이 보장하는 조합원의 재판을 받을 권리를 일률적으로 침해하는 규정으로서 무효이다. 따라서 甲이 제기한 위로금 지급 청구의 소는 소의 이익을 구비한 적법한 소이며, 乙의 항변은 이유가 없다. 그러므로 법원은 乙의 주장을 배척하고 본안 심리를 개시하여야 한다.

《【문제1】 甲은 乙 노동조합(이하 乙이라 한다)의 조합원이다. 아래의 각 물음에 관하여 논하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 무관함) (50점)

(물음2) 甲은 乙에 대하여 5천만 원의 위로금 지급을 구하는 소를 제기하였다. 甲(제한능력자가 아님)의 배우자(공인노무사로 제한능력자가 아님)가 위 소송을 대리할 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음2> 배우자 및 공인노무사의 소송대리권 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 원고 甲이 乙 노동조합을 상대로 5,000만 원의 위로금 지급을 구하는 소송을 제기한 상황이다. 쟁점으로 <소송물이 5,000만 원인 단독사건에서 배우자라는 신분적 관계나 공인노무사라는 직업적 자격이 소송대리권 인정의 근거가 될 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변호사대리원칙의 의의와 비변호사의 소송대리 허용 요건을 중심으로 배우자의 소송대리 가능성에 대해 설명한다.

II. 변호사대리원칙과 예외

1. 변호사대리원칙 [민사소송법 제87조]

- 법률에 따라 재판상의 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다. 이는 소송절차의 원활한 진행과 당사자의 권익 보호를 위해 법률 전문가에 의한 대리를 강제하는 것이다.

2. 비변호사 소송대리의 예외적 허용 [민사소송법 제88조]

(1) 대상 사건의 범위

- 단독판사가 심리·판결하는 사건 중 수표·어음금, 대여금, 구상금, 손해배상 등 비교적 사안이 단순한 사건으로서 일정한 금액(현행 규칙상 소송물가액 1억 원) 이하인 사건에 한하여 인정된다.

(2) 대리인의 자격 요건

- 당사자와 밀접한 생활관계를 맺고 있는 일정 범위의 친족(배우자, 직계혈족, 형제자매)이거나, 당사자와 고용 등 상시적인 업무관계를 맺고 있는 사람이어야 한다.

(3) 법원의 허가

- 위 요건을 갖춘 경우라도 법원의 허가를 얻어야 하며, 법원은 언제든지 그 허가를 취소할 수 있다.

III. 공인노무사의 소송대리권 인정 여부

1. 공인노무사법상 직무 범위

- 공인노무사는 노동관계법령에 따른 서류 작성, 상담, 노동위원회 사건 대리 등을 직무로 한다. 그러나, 현행법상 공인노무사에게 민사소송법상 소송대리권이 일반적·당연적으로 부여되어 있지는 않다.

2. 판례의 태도

- 판례는 변호사법 및 민사소송법의 취지에 비추어 법률에 특별한 규정이 없는 한 비변호사의 소송대리를 엄격히 제한한다. 공인노무사라 하더라도 민사소송절차에서는 변호사대리원칙의 예외를 규정한 별도의 법률이 없으므로, 자격 그 자체만으로는 소송대리인이 될 수 없다고 본다.

IV. 사안의 적용

1. 소송물가액과 단독사건 해당 여부

- 甲이 제기한 소송의 금액은 5,000만 원이다. 이는 3,000만 원을 초과하여 소액사건심판법의 적용 대상은 아니지만, 1억 원 이하의 단독사건에 해당하므로 민사소송법 제88조에 따른 소송대리 허가 신청이 가능한 범위에 있다.

2. 배우자로서의 소송대리 가능성

- 배우자는 민사소송법 제88조 및 민사소송규칙 제15조가 정한 밀접한 생활관계에 있는 사람에 해당한다. 따라서 甲의 배우자는 공인노무사라는 자격 때문이 아니라 배우자라는 신분적 자격에 근거하여 법원에 소송대리 허가를 신청할 수 있다.

3. 법원의 허가 여부

- 다만, 배우자라는 신분만으로 당연히 대리권이 발생하는 것은 아니다. 甲과 배우자가 서면으로 소송대리 허가신청을 하고, 법원이 해당 사건의 난이도와 배우자의 법률적 지식 등을 고려하여 허가 결정을 내릴 때 비로소 대리권이 발생한다. 사안의 경우 배우자가 공인노무사로서 법률적 소양이 충분하므로 법원이 허가할 가능성이 높으나, 법원의 허가 없이는 소송행위를 할 수 없다.

V. 결론

- 甲의 배우자가 단지 공인노무사라는 직업적 자격만으로 소송을 대리할 수는 없다. 그러나 사안의 소송은 5,000만 원의 단독사건으로서 비변호사 대리 허가 대상에 해당하므로, 甲의 배우자는 배우자라는 신분적 관계를 근거로 법원의 허가를 받아 소송을 대리할 수 있다. 만약 법원의 허가를 받지 않고 소송행위를 한다면 이는 소송대리권 없는 자의 행위로서 무효가 되며, 법원은 대리인의 출석을 거부하거나 소송행위를 배제해야 한다.

《【문제2】 소송고지에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송고지의 의의, 요건, 절차 및 방식, 효력

I. 문제의 제기

- 소송고지란 소송계속 중 당사자가 그 소송에 참가할 수 있는 제3자에 대하여 소송계속의 사실을 법정의 방식에 따라 통지하는 것을 말한다.(민사소송법 제84조) 이는 고지자에게는 보조참가를 할 수 있는 자를 소송에 끌어들여 장래의 구상소송 등에서 판결의 효력을 미치게 함으로써 유리한 지위를 확보하게 하고, 피고지자에게는 소송 참여의 기회를 제공하여 자신의 권리를 방어할 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 특히 고지자가 패소했을 때 피고지자가 '내가 참여했더라면 이겼을 것'이라고 주장하는 것을 방지하는 소송법적 효력이 발생한다. 이하에서는 소송고지가 적법하게 성립하기 위한 요건과 구체적인 절차, 그리고 고지 후 발생하는 참가적 효력의 범위를 중심으로 설명한다.

II. 소송고지의 요건

1. 소송계속 중일 것

- 소송고지는 소송이 법원에 계속되어 있는 상태에서만 가능하다. 제1심뿐만 아니라 항소심에서도 가능하나, 판결이 확정된 후에는 고지할 수 없다.

2. 고지자와 피고지자의 자격

- 고지는 소송당사자(원고, 피고)뿐만 아니라 이미 참가한 보조참가인도 할 수 있다. 피고지자는 당해 소송에 참가할 수 있는 제3자여야 한다. 즉, 법률상 이해관계가 있어 보조참가나 공동소송참가, 독립당사자참가 등을 할 수 있는 자여야 한다.

3. 고지 사유의 존재

- 고지자는 피고지자에게 소송고지를 하는 이유를 명시해야 한다. 통상 고지자가 소송에서 패소할 경우 피고지자에게 구상권을 행사하거나, 반대로 피고지자로부터 책임을 추궁당할 염려가 있는 경우 등이 이에 해당한다.

III. 소송고지의 절차 및 방식

1. 서면에 의한 고지

- 소송고지는 고지 이유와 소송의 진행 정도를 적은 서면을 법원에 제출하여야 한다(민사소송법 제84조 제2항) 법원은 이 서면을 상대방과 피고지자에게 송달한다.

2. 고지의 시기

- 소송고지의 시기에 대해서는 특별한 제한이 없으나, 피고지자가 유효하게 소송에 참가하여 방어행위를 할 수 있는 시점에 이루어져야 효력이 온전하게 발생한다.

IV. 소송고지의 효력(참가적 효력)

1. 효력의 발생 근거

- 피고지자가 소송에 참가한 경우는 물론, 참가할 수 있었음에도 참가하지 않은 경우에도 민사소송법 제86조에 따라 참가적 효력이 발생한다. 이는 참가인과 피참가인 사이의 판결의 구속력을 의미한다.

2. 참가적 효력의 내용

- 참가적 효력은 기판력과는 구별되는 특수한 효력이다. 피고지자는 고지자와의 후행 소송에서 전소 판결이 부당하다고 주장하며 다툴 수 없게 된다.

(1) 주관적 범위

- 참가적 효력은 고지자와 피고지자 사이에서만 발생하며, 전소의 상대방에게는 미치지 않는다.

(2) 객관적 범위

- 판결의 주문뿐만 아니라 판결 이유 중에서 판단된 사실관계나 법률적 판단에 대해서도 효력이 미친다.

3. 효력의 제한

- 피고지자가 참가하지 못한 것에 정당한 사유가 있거나, 고지자가 소송수행을 태만히 하여 패소한 경우 등에는 참가적 효력이 제한될 수 있다. 또한 고지 시점이 너무 늦어 피고지자가 방어 기회를 전혀 갖지 못한 경우에도 효력은 발생하지 않는다.

V. 결론

- 소송고지는 분쟁의 일회적 해결과 관련 당사자 간의 공평을 기하기 위한 중요한 제도이다. 고지자는 이를 통해 향후 발생할 수 있는 구상 소송 등에서의 입증 부담을 덜 수 있고, 피고지자는 자신의 이해관계가 걸린 소송에 조기에 개입하여 불이익을 방지할 수 있다. 법원은 소송고지서가 적법하게 송달되었는지와 피고지자의 참가 자격 유무를 면밀히 살펴야 한다. 또한 소송고지에 따른 참가적 효력은 기판력보다 넓은 범위에 미치므로, 그 적용에 있어 당사자의 절차적 보장이 충분히 이루어졌는지를 엄격히 판단해야 할 것이다. 이하에서는 소송고지가 다수당사자 분쟁에서 효율적인 해결 수단으로 기능하고 있음을 확인한다.

《【문제3】 문서의 증거력에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 문서의 증거력(형식적 증거력, 실질적 증거력)

I. 문제의 제기

- 문서의 증거력이란 서증에 있어서 문서에 기재된 내용이 증거로서 가치(신빙성)를 가지는 정도를 의미한다. 이는 크게 문서가 당해 작성자에 의해 진정하게 성립되었는지를 다루는 형식적 증거력과, 진정하게 성립된 문서의 내용이 요건사실을 증명하는 데 얼마나 기여하는지를 다루는 실질적 증거력으로 구분된다. 민사소송법은 특히 문서의 성립에 관한 추정 규정을 두어 입증책임을 완화하고 있다. 이하에서는 형식적 증거력의 의의와 성립의 진정, 실질적 증거력의 판단 기준 및 관련 법리를 설명한다.

II. 형식적 증거력(성립의 진정)

1. 의의

- 형식적 증거력이란 문서가 거명된 작성자의 의사에 기하여 작성된 것을 의미하며, 이를 성립의 진정이라고도 한다. 모든 문서는 증거로 사용되기 위해 먼저 형식적 증거력을 갖추어야 한다.

2. 성립의 진정에 관한 입증 및 추정

(1) 직접 입증

- 문서의 성립을 다투는 경우, 제출자는 증인신문이나 감정 등을 통해 해당 문서가 작성자의 인장이나 서명에 의해 작성되었음을 증명해야 한다.

(2) 민사소송법 제357조와 제358조

- 사문서는 당사자 또는 대리인의 서명이나 날인이 있는 때에는 진정한 것으로 추정한다. 공문서는 그 모양과 성질에 따라 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정되는 때에는 진정한 것으로 추정한다.

(3) 인영의 진정에 의한 2층의 추정

- 판례는 문서에 찍힌 인영이 작성자의 인장에 의한 것임이 증명되면, 그 인영은 작성자의 의사에 기해 찍힌 것으로 사실상 추정되고(1층 추정), 인영이 진정하면 민사소송법 제358조에 의해 문서 전체가 작성자의 의사에 따라 진정하게 성립된 것으로 법률상 추정된다(2층 추정)는 이론을 확립하고 있다.

III. 실질적 증거력

1. 의의

- 실질적 증거력이란 진정하게 성립된 문서의 기재 내용이 증거로서 사실인정에 기여하는 가치를 의미한다. 이는 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것이 원칙이다.

2. 문서의 종류에 따른 차이

(1) 처분문서

- 증명하려는 의사표시가 그 문서 자체에 의해 이루어진 경우(예 : 계약서, 차용증)를 말한다. 처분문서는 형식적 증거력이 인정되면 법관은 특별한 사정이 없는 한 그 기재 내용대로 법률행위의 존재를 인정해야 한다.

(2) 보고서

- 작성자가 보고 들은 사실을 기재한 문서(예 : 일기, 장부, 편지)를 말한다. 보고문서는 형식적 증거력이 인정되더라도 법관이 다른 증거와 종합하여 그 내용의 진실성을 자유롭게 판단한다.

IV. 증거력의 다툼과 법원의 판단

1. 처분문서의 증거력 제한

- 처분문서라 할지라도 기재 내용과 다른 명백한 반증이 있거나, 기재 내용이 사회통념상 극히 이례적이라는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 그 증거력을 부정할 수 있다.

2. 문서의 변조와 증거력

- 문서의 일부가 변조되었다고 의심되는 경우, 법원은 변조된 부분의 증거력을 배제하고 나머지 부분의 진실성을 심리해야 한다.

V. 결론

- 문서의 증거력은 민사재판에서 사실관계를 확정하는 가장 강력한 수단이다. 특히 서증의 형식적 증거력은 실질적 증거력의 전제조건이 되며, 민사소송법상 추정 규정과 인영에 관한 판례 법리는 입증의 곤란을 해소하는 핵심적 역할을 수행한다. 법원은 처분문서의 강한 증거력을 존중하되, 진실에 반하는 기재가 발견될 경우 자유심증을 통해 이를 적절히 배제함으로써 실체적 진실 발견과 절차적 정의를 조화시켜야 한다. 이하에서는 문서의 증거력이 디지털 문서 등 현대적 증거 형태에서도 동일한 원칙 하에 엄격히 적용되어야 함을 확인한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2019-1-1]피고의 일부변제 미주장 시 법원이 원고 청구액 전액을 인용한 판결의 타당성 여부

《【문제1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음1) 乙은 위 소송절차에서 2017. 10. 1.에 일부변제한 사실을 주장하지 아니하였다. 3,000만 원의 변제사실을 인정하지 않고 1억 원의 지급을 명한 위 법원의 판결이 타당한지를 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 피고의 일부변제 미주장 시 법원이 원고 청구액 전액을 인용한 판결의 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였으나 乙은 변론종결 전 이미 이루어진 3,000만 원의 일부변제 사실을 주장하지 않았고, 법원은 이를 고려하지 않은 채 1억 원 전액의 지급을 명하는 판결을 선고하여 확정된 상황이다. 쟁점으로 <변론종결 전 발생한 일부변제 사실을 당사자가 주장하지 않은 경우 법원이 이를 직권으로 고려하여야 하는지>와 <이를 반영하지 않은 판결의 적법성>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변론주의와 처분권주의를 전제로 일부변제 사실을 주장하지 않은 경우 법원이 전액 지급판결을 선고한 것이 타당한지 논한다.

II. 변론주의의 일반 법리

1. 변론주의의 의의 및 필요성

(1) 개념 및 의의

- 변론주의란 소송자료인 사실과 증거의 수집·제출을 당사자의 책임과 권능으로 삼는 소송법상 원칙을 의미한다. 이는 당사자의 사적 자치를 소송절차상으로 관철하려는 데 취지가 있다.

(2) 필요성

- 변론주의는 국가기관인 법원이 불필요하게 사적인 분쟁에 개입하는 것을 방지하고, 당사자 스스로가 가장 잘 아는 사실관계를 직접 현출하도록 함으로써 실질적이고 신속한 심리를 도모하는 역할을 수행한다.

2. 변론주의의 내용과 주장책임

(1) 주장책임의 원칙

- 법원은 당사자가 소송에서 주장하지 않은 사실은 판결의 기초로 삼을 수 없다는 제1원칙이다. 이는 당사자가 주장한 사실만을 기초로 사실을 인정해야 하는 법원의 소극적 한계를 규정한다.

(2) 대상이 되는 사실의 범위

- 주장책임의 대상은 권리의 발생·변경·소멸에 직접적이고 법률적인 효과를 주는 주요사실에 한한다. 주요사실에 대립하는 간접사실이나 보조사실은 당사자의 구체적인 주장이 없더라도 증거에 의하여 법원이 직접 인정할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 일부변제 사실의 법적 성질

(1) 주요사실의 해당 여부

- 일부변제는 원고의 공사대금채권의 일부를 소멸시키는 실체법상 효과를 발생시키는 변제 항변에 해당한다. 따라서 이는 채권의 소멸이라는 법률 효과를 직접 가져오는 전형적인 주요사실에 속한다.

(2) 법원의 임의 판단 제한

- 일부변제가 주요사실에 해당하는 이상, 당사자가 이를 법정에 제출하여 주장하지 않는 한 법원은 직권으로 이를 재판의 기초로 삼을 수 없다.

2. 乙의 미주장과 법원 판결의 타당성

(1) 乙의 주장책임 흡결

- 사안에서 피고 乙은 3,000만 원을 이미 변제한 사실이 엄연히 존재함에도 불구하고, 2018. 12. 1. 변론종결 전까지 법원에 이를 전혀 주장하지 않았다. 이는 乙이 주장책임을 다하지 않은 것에 해당한다.

(2) 법원의 판결에 대한 평가

- 수소법원은 변론주의 원칙에 구속되므로, 乙의 구체적인 변제 항변 주장이 없는 상태에서 임의로 3,000만 원의 채무 소멸을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 따라서 법원이 제출된 소송자료만을 토대로 甲의 1억 원 청구를 전액 인용한 판결은 변론주의의 주장책임 원칙에 완벽히 부합하므로 전적으로 정당하고 타당하다.

IV. 결론

- 변론주의의 제1원칙에 따라 법원은 당사자가 주장하지 아니한 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 사안의 일부변제 사실은 채권 소멸이라는 법률 효과를 직접 발생시키는 주요사실에 해당함에도 피고 乙은 소송절차 내에서 이를 주장하지 않았다. 따라서 법원이 乙의 변제 사실을 고려하지 않고 甲의 공사대금 청구를 전액 인용한 것은 소송법상의 대원칙인 변론주의에 정밀하게 부합하는 적법·타당한 재판이다. 결국 乙은 자신의 주장책임 태만으로 인한 불이익을 스스로 감수하여야 한다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2019-1-2]확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

《【문제1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음2) 乙은 甲에 대하여 2018. 5. 1.을 지급기일로 하는 대여금 2,000만 원의 채권을 가지고 있었으나 상계항변을 하지 않았다. 乙이 2019. 7. 1.에 이 채권을 가지고 상계할 수 있는지를 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 공사대금 청구소송 계속 중 이미 변제기가 도래한 자신의 대여금채권을 가지고도 상계항변을 하지 않은 채 甲 승소의 확정판결이 이루어진 후 다시 그 채권으로 상계하려는 상황이다. 쟁점으로 <확정판결의 기판력이 변론종결 전 존재하였으나 행사하지 않은 상계권의 행사에 미치는 효력과 판결 확정 후 상계의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변론종결 전 발생한 상계권에 대한 실효의 적용 여부와 판결 확정 후 乙의 상계 가능 여부를 논한다.

II. 기판력의 시적 범위와 차단효

1. 기판력의 표준시

- 기판력은 무한정 인정되는 것이 아니라 특정 시점의 권리관계를 확정하는 것이다. 민사소송법상 사실심 변론종결 시를 기준으로 하며, 이를 기판력의 표준시라고 한다. 표준시 이전에 발생한 사유는 이후의 소송에서 더 이상 다툴 수 없게 되는데 이를 기판력의 차단효 또는 실효효과라 한다.

2. 차단효의 범위

- 당사자는 표준시 이전에 존재했던 모든 방어방법을 소송 절차 내에서 제출했어야 한다. 이를 게을리하여 판결이 확정된 경우, 설령 그 사유가 진실이라 하더라도 판결의 효력을 부정하는 주장을 할 수 없다.

III. 상계권 행사의 특수성과 차단효의 적용 여부

1. 학설의 대립

(1) 부정설(비차단설)

- 상계권은 소송상의 방어방법일 뿐만 아니라 실체법상 독립된 형성권이므로, 소송에서 행사하지 않았더라도 그 권리 자체가 소멸하는 것은 아니라고 본다. 따라서 판결 확정 후에도 상계권을 행사하여 집행력 배제를 구할 수 있다는 견해이다.

(2) 긍정설(차단설)

- 변제나 상계나 모두 채권의 소멸을 가져오는 방어방법이라는 점에서는 동일하다. 소송 절차의 안정을 위해 표준시 전에 행사가 가능했던 상계권을 행사하지 않았다면 차단효가 발생한다고 보는 견해이다.

2. 판례의 태도

- 대법원은 상계권의 행사가 소송 외에서 이루어지든 소송 내에서 이루어지든, 그것이 표준시 이전에 행사가 가능했던 것이라면 기판력의 차단효가 발생한다고 본다. 즉, 채무자가 전소 변론종결 전에 상계 적상에 있었던 채권을 가지고 있었다면, 이를 소송에서 주장하지 않았을 경우 판결 확정 후에 다시 상계권을 행사하여 전소 판결의 집행력을 배제하는 것은 허용되지 않는다는 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 상계 적상의 시점 확인

- 사안에서 피고 乙의 대여금 채권은 2018. 5. 1.이 지급기일이다. 甲이 제기한 소송의 변론종결일은 2018. 12. 1.이므로, 乙은 변론종결 전인 2018. 5. 1.부터 이미 상계 적상에 있었으며 소송 절차 내에서 상계 항변을 할 수 있는 상태였다.

2. 상계권 행사의 제한

- 乙은 충분히 상계 항변을 할 수 있었음에도 불구하고 이를 하지 않은 채 판결이 확정되도록 방치하였다. 판례의 확립된 견해에 따르면, 표준시(2018. 12. 1.) 이전에 발생한 상계 사유는 기판력에 의해 차단된다. 따라서 乙이 2019. 7. 1.에 이르러 전소 판결에 의한 채무를 면하기 위해 상계를 주장하는 것은 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

V. 결론

- 피고 乙은 2019. 7. 1.에 상계권을 행사하여 甲에 대한 공사대금 채무를 소멸시킬 수 없다. 비록 乙이 2,000만 원의 진정한 채권을 가지고 있다 하더라도, 이는 전소의 변론종결 전에 이미 행사가 가능했던 방어방법이므로 기판력의 차단효에 의해 행사가 제한되기 때문이다. 乙은 상계권 행사 대신 甲을 상대로 별도의 대여금 반환 청구 소송을 제기하여 자신의 채권을 회수해야 할 것이며, 이미 확정된 공사대금 1억 원의 판결에 대해서는 상계를 이유로 다툴 수 없다. 이하에서는 이러한 기판력의 원칙이 분쟁의 일회적 해결과 확정판결의 권위를 위해 필수적임을 확인한다.

《【문제2】 합의관할에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 합의관할의 의의, 성립요건, 종류, 효력

I. 문제의 제기

- 합의관할이란 민사소송법 제29조에 따라 제1심 법원에 한하여 당사자 사이의 합의에 의하여 생기는 관할을 말한다. 이는 당사자의 편의를 도모하고 사적 자치를 소송절차에도 반영하기 위한 제도로써, 법정관할에 우선하여 관할권이 발생한다. 합의는 소송계속 전후를 불문하고 가능하며, 특정 법원에 관할권을 부여하거나 기존 관할권을 배제하는 방식으로 이루어진다. 다만, 법적 안정성과 재판의 공정성을 위해 일정한 요건을 갖추어야 하며 전속관할에는 적용되지 않는 등 일정한 한계가 존재한다. 이하에서는 합의관할이 적법하게 성립하기 위한 요건과 그에 따른 소송법적 효력, 합의의 효력이 미치는 범위에 관하여 설명한다.

II. 합의관할의 성립요건

1. 제1심 법원의 관할에 관한 합의일 것

- 합의관할은 제1심 법원에 한하여 인정된다. 상소심(항소심, 상고심)의 관할은 법률에 의해 엄격히 규정되어 있으므로 당사자의 합의로 변경할 수 없다.

2. 법정의 재판적 중 임의관할에 관한 합의일 것

- 합의관할은 임의관할인 경우에만 성립한다. 민사소송법 제31조에 따라 전속관할로 정해진 사건(전속적 합의가 아닌 법정 전속관할 사건)에 대해서는 합의관할이 인정되지 않는다.

3. 특정한 법률관계에 관한 합의일 것

- 모든 분쟁을 특정 법원의 관할로 한다는 식의 포괄적 합의는 무효이다. 특정한 법률관계에서 발생하는 소송(예 : A와 B 사이의 2024년 3월 19일자 매매계약에 관한 소송)에 관한 합의여야 한다.

4. 관할법원이 특정되어 있을 것

- 합의에 의해 지정되는 법원은 특정되어야 한다. 모호한 지정(예 : 대한민국의 법정 중 하나)은 무효이다. 다만, 사후적으로 특정 가능한 방식(예 : 원고의 주소지 법원)은 허용된다.

5. 방식 및 시기

- 합의의 방식은 민사소송법 제29조 제2항에 따라 서면으로 하여야 한다. 이는 합의의 존부와 내용을 명확히 하기 위함이다. 합의의 시기는 소제기 전은 물론 소송계속 중에도 가능하다.

III. 합의의 종류

1. 전속적 합의

- 특정 법원에만 관할권을 인정하고 다른 법원의 관할권을 배제하는 합의를 말한다.

2. 부가적 합의

- 법정관할권은 그대로 유지하면서 특정 법원을 관할법원으로 추가하는 합의를 말한다. 이 경우 원고는 법정관할법원과 합의관할법원 중 선택하여 소를 제기할 수 있다.

3. 판례의 입장

- 판례는 전속적 합의인지 여부가 불분명할 경우, 법정관할 중 하나를 선택한 것이라면 부가적 합의로, 법정관할 이외의 법원을 선택한 것이라면 전속적 합의로 추정하는 경향이 있다.

IV. 합의관할의 효력

1. 관할권의 발생

- 적법한 합의가 이루어지면 합의된 법원에 관할권이 발생한다. 전속적 합의의 경우 합의된 법원만이 관할권을 가지며, 법정관할권은 소멸한다.

2. 효력의 주관적 범위

(1) 당사자 및 일반승계인

- 합의의 효력은 합의를 한 당사자와 그 상속인 등 일반승계인에게 당연히 미친다.

(2) 특별승계인

- 판례는 지명채권의 양수인과 같은 특별승계인에 대하여, 채권의 내용 자체에 합의관할 조항이 포함되어 있다면 그 효력이 미치는 것으로 본다. 다만, 물권적 청구권의 승계인에 대해서는 합의의 효력이 미치지 않는다고 보는 것이 일반적이다.

3. 합의관할의 유효성 심사

(1) 약관에 의한 관할합의

- 금융기관이나 대기업이 사용하는 약관에 관할합의 조항이 포함된 경우, 고객에게 일방적으로 불리하거나 재판받을 권리를 부당하게 제한한다면 약관의 규제에 관한 법률에 의해 무효가 될 수 있다.

(2) 전속관할과의 관계

- 법률상 전속관할로 지정된 사건(예 : 재심, 제권판결 등)에 대하여 당사자가 합의로 다른 법원을 지정하더라도 이는 효력이 없다. 전속관할은 공익적 이유로 법이 강제한 것이기 때문이다.

V. 결론

- 합의관할은 당사자의 의사를 존중하여 소송 편의를 극대화하는 제도이다. 특히, 국제거래나 기업 간 거래에서 분쟁 발생 시 예측 가능성을 높여주는 중요한 역할을 한다. 법원은 합의관할의 요건인 서면성 및 특정성을 엄격히 심사하여 당사자의 합의 의사가 왜곡되지 않도록 해야 한다. 또한, 경제적 약자가 약관 등을 통해 재판권 행사에 부당한 제약을 받지 않도록 신의칙과 약관규제법을 통해 적절히 통제해야 할 것이다.

《【문제3】 공동소송참가에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제3> 공동소송참가의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 효력

I. 문제의 제기

- 공동소송참가란 타인 사이의 소송계속 중 그 소송의 판결의 효력이 제3자에게도 미치거나, 소송물이 제3자와 합일확정되어야 할 경우에 그 제3자가 자기의 권리를 보호하기 위하여 당사자 일방의 공동소송인으로서 소송에 가입하는 것을 의미한다.(민사소송법 제83조) 이는 판결의 대세효가 인정되는 소송에서 제3자의 절차적 보장을 도모하고, 판결의 모순·저촉을 방지하여 분쟁을 일회적으로 해결하기 위한 제도이다. 일반 보조참가와 달리 참가인이 독자적인 당사자 지위를 가지며, 필수적 공동소송의 규정이 준용된다는 점에 특징이 있다. 이하에서는 공동소송참가의 성립요건과 절차, 그리고 참가 이후의 소송수행상 효력에 대해 설명한다.

II. 공동소송참가의 요건

1. 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 공동소송참가는 이미 개시된 소송에 중도 가입하는 것이므로, 제1심 또는 제2심의 변론종결 전까지 소송이 유효하게 계속되어 있어야 한다. 상고심에서의 참가는 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 소송물이 합일확정되어야 할 경우일 것

- 참가인이 원고 또는 피고 중 어느 일방과 공동소송인이 되어 판결의 결론이 반드시 일치해야 하는 관계여야 한다.

(1) 판결의 효력이 제3자에게 미치는 경우

- 상법상 주주총회결의 취소의 소나 무효확인 소와 같이 판결의 효력이 대세적으로 미치는 소송이 대표적이다.

(2) 고유필수적 공동소송인 중 일부가 누락된 경우

- 권리관계의 성질상 당사자 전원이 함께 소송을 수행해야 함에도 일부가 누락되어 소송이 진행 중일 때, 누락된 자가 공동소송참가 신청을 함으로써 소송 요건의 흠결을 보완할 수 있다.

III. 참가의 절차 및 심판

1. 참가의 신청

- 참가하려는 제3자는 참가의 취지와 이유를 명시하여 서면으로 신청해야 한다. 이때 참가인은 기존 당사자 중 누구의 공동소송인이 될 것인지를 분명히 해야 한다.

2. 참가신청에 대한 허부 결정

- 법원은 참가신청이 요건을 갖추었는지 심사한다. 상대방이 이익을 제기하거나 법원이 부적법하다고 판단하면 결정으로 각하할 수 있으나, 요건을 갖춘 경우 별도의 허가 결정 없이도 참가의 효력이 발생한다.

IV. 소송수행상의 효력

1. 당사자 지위의 취득

- 참가인은 단순히 보조적인 지위에 그치는 것이 아니라, 독립된 공동소송인으로서의 지위를 취득한다. 따라서 소송물의 처분이나 포기, 화해 등 독자적인 소송행위를 할 수 있다.

2. 필수적 공동소송 규정의 준용 [민사소송법 제67조]

- 공동소송참가인과 기존 당사자 사이에는 합일확정의 필요성이 있으므로 필수적 공동소송에 관한 규정이 적용된다.

(1) 소송자료의 공통

- 참가인 1인의 소송행위는 전원의 이익을 위해서만 효력을 가진다. 따라서 1인이 제출한 유리한 증거는 다른 당사자에게도 효력이 미치지만, 1인이 행한 자백이나 청구의 포기 등 불리한 행위는 전원이 함께하지 않는 한 효력이 발생하지 않는다.

(2) 소송진행의 공통

- 당사자 1인에게 발생한 소송절차의 중단이나 중지 사유는 전원에게 그 효력이 미친다. 판결 역시 모든 공동소송인에 대하여 동시에 선고되어야 하며 결론이 일치해야 한다.

V. 상소 제기 시의 취급

1. 상소의 불가분 원칙

- 공동소송인 중 1인이 상소를 제기하면 사건 전체가 상소심으로 이전하며, 상소하지 않은 나머지 당사자들도 상소심의 당사자가 된다. 이는 판결의 합일확정을 유지하기 위함이다.

2. 상소심의 심판 범위

- 상소심 법원은 불복하지 않은 당사자의 부분에 대해서도 심리하고 판결해야 하며, 전원에게 대하여 하나의 판결을 선고해야 한다.

VI. 결론

- 공동소송참가는 판결의 효력을 직접 받게 되는 제3자에게 소송 참여의 기회를 보장함으로써 재판의 적정과 공정을 기하는 제도이다. 특히 대세효가 있는 소송이나 필수적 공동소송에서 누락된 자를 구제하여 소송경제와 분쟁의 일회적 해결에 기여한다. 법원은 참가인의 당사자 지위를 충분히 보장하되, 합일확정의 원칙에 따라 기존 당사자와의 조화를 도모해야 한다. 이하에서는 이러한 공동소송참가 제도가 제3자의 재판받을 권리를 실질적으로 보호하는 중요한 절차적 장치임을 확인한다.

《[문제1] 甲(수원에 주소를 두고 살고 있음)은 대전에 소재한 자기 토지를 乙(대구에 주소를 두고 살고 있음)에게 매도하고 매매잔대금 1억 원을 받지 못하여, 그 지급을 구하는 소를 대전지방법원에 제기하였다. 이후에 甲은 乙이 소제기 이전에 사망하였다는 사실과 乙의 유일한 상속인인 丙(대구에 주소를 두고 살고 있음)이 있다는 사실을 알게 되었다. 甲은 피고를 丙으로 바꾸는 신청을 하였고 법원은 당사자표시정정하여 피고를 丙으로 바꾸었다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임)

(물음1) 丙은 변론기일에 출석하여 위 매매대금은 모두 지급되었으므로 甲의 이 사건 소에 대하여 청구기각을 구한다는 진술을 하였다. 위 법원에 관할권이 인정되는지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 당사자표시정정 후의 관할권 인정 여부와 변론관할의 성립

I. 문제의 제기

- 사안은 원고 甲이 이미 사망한 乙을 피고로 하여 소송물이 위치한 대전지방법원에 소를 제기하였다가, 이후 상속인 丙으로 당사자표시를 정정한 상황이다. 쟁점으로 <소가 지참채무인 매매잔대금 지급 청구로서 의무이행지(수원)나 피고의 주소지(대구)가 아닌 대전지방법원에 제기된바, 토지의 소재지라는 이유만으로 관할권이 발생하는지(특별재판적)>, 그리고 <당사자표시정정의 적법성 및 丙이 본안에 관하여 변론함으로써 변론관할(민사소송법 제30조)이 성립할 수 있는지>를 검토해야 한다. 이하에서는 당사자표시정정의 효력과 토지관할의 종류 및 변론관할의 성립 요건을 중심으로 관할권 인정 여부를 논한다.

II. 사망 피고에 대한 소제기와 당사자표시정정

1. 사망 피고에 대한 소제기의 효력

- 원고가 피고의 사망 사실을 모르고 사망자를 피고로 기재하여 소를 제기한 경우, 실질적인 당사자는 사망자의 상속인이며 표시만 사망자로 잘못된 것으로 본다. 따라서 이 소송은 부적법하여 각하될 대상이 아니라 표시를 바로잡음으로써 유효하게 계속될 수 있다.

2. 당사자표시정정의 적법성

- 판례는 소제기 전 사망자를 피고로 한 경우라도 실질적 당사자인 상속인으로 표시를 정정하는 것을 허용한다. 사안에서 甲이 乙의 상속인인 丙으로 피고를 바꾼 신청은 당사자의 동일성을 해치지 않는 적법한 당사자표시정정에 해당하며, 소송의 효력은 소제기 시로 소급하여 丙에게 미친다.

III. 대전지방법원의 토지관할권 검토

1. 보통재판적[민사소송법 제2조, 제3조]

- 피고의 보통재판적은 주소지에 따라 결정된다. 丙의 주소지는 대구이므로 대구지방법원이 보통재판적 소재지 관할법원이 된다.

2. 특별재판적

(1) 의무이행지의 특별재판적[민사소송법 제8조]

- 재산권에 관한 소는 의무이행지의 법원에 제기할 수 있다. 매매잔대금 지급 채무는 원칙적으로 채권자의 주소지에서 이행해야 하는 지참채무이므로, 원고 甲의 주소지인 수원지방법원에 특별재판적이 인정된다.

(2) 부동산 소재지의 특별재판적[민사소송법 제20조]

- 부동산에 관한 소는 부동산이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다. 그러나 판례는 부동산에 관한 소를 부동산 자체에 대한 소유권, 점유권 등 물권적 청구권이나 등기청구권 등에 한정하며, 매매대금 지급을 구하는 채권적 청구는 이에 포함되지 않는다고 본다. 따라서 대전지방법원은 부동산 소재지라는 이유만으로는 관할권을 가지지 못한다.

IV. 변론관할의 성립 여부

1. 변론관할의 의의 및 요건[민사소송법 제30조]

- 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기하였다더라도, 피고가 관할위반의 항변을 하지 아니하고 본안에 대하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술한 때에는 그 법원에 관할권이 생긴다.

(1) 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기하였을 것

- 대전지방법원은 앞서 살펴본 바와 같이 보통재판적이나 특별재판적 어느 것도 인정되지 않는 법원이다.

(2) 피고가 관할위반의 항변을 하지 않고 본안변론을 하였을 것

- 사안에서 피고 丙은 변론기일에 출석하여 '매매대금이 모두 지급되었다'며 청구기각을 구하는 진술을 하였다. 이는 소송요건이 아닌 소송물인 권리관계 자체에 관한 진술이므로 본안변론에 해당한다.

(3) 법원이 관할권이 없음을 간과하였을 것

- 법원이 관할위반임을 지적하여 이송하기 전에 피고의 변론이 이루어져야 한다.

2. 변론관할의 제한[민사소송법 제31조]

- 변론관할은 임의관할인 경우에만 성립하며, 전속관할이 정해져 있는 경우에는 성립하지 않는다. 매매대금 청구 소송은 합의관할이나 변론관할이 허용되는 임의관할 사건이다.

V. 사안의 적용

- 대전지방법원은 피고 丙의 보통재판적(대구)이나 의무이행지 특별재판적(수원)에 해당하지 않으며, 매매대금 청구는 부동산 소재지 특별재판적(대전) 대상도 아니므로 당초 관할권이 없다. 그러나 丙으로의 당사자표시정정은 적법하며, 정정된 피고 丙이 대전지방법원에서 관할위반의 항변 없이 본안에 관하여 청구기각을 구하는 진술을 하였으므로 민사소송법 제30조에 따른 변론관할이 성립한다. 따라서 대전지방법원에는 이 사건 소에 대한 관할권이 인정된다.

VI. 결론

- 결론적으로 변론관할이 성립함으로써 절차적 하자가 치유되었으므로 법원은 이송 없이 본안심리를 계속해야 한다.

《【문제1】 甲(수원에 주소를 두고 살고 있음)은 대전에 소재한 자기 토지를 乙(대구에 주소를 두고 살고 있음)에게 매도하고 매매잔대금 1억 원을 받지 못하여, 그 지급을 구하는 소를 대전지방법원에 제기하였다. 이후에 甲은 乙이 소제기 이전에 사망하였다는 사실과 乙의 유일한 상속인인 丙(대구에 주소를 두고 살고 있음)이 있다는 사실을 알게 되었다. 甲은 피고를 丙으로 바꾸는 신청을 하였고 법원은 당사자표시정정하여 피고를 丙으로 바꾸었다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임)

(물음2) 丙은 이 사건 법원의 당사자표시정정은 부적법하다고 주장하였다. 丙의 이 주장이 타당한지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 소제기 전 사망자를 피고로 한 경우 당사자표시정정의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 원고 甲이 피고 乙의 사망 사실을 모르고 소를 제기한 후 상속인 丙으로 당사자표시정정을 신청하여 법원의 허가를 받았으며, 이에 피고 丙은 당사자표시정정이 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <사자 상대 소송의 보정 방법으로서 당사자표시정정이 허용되는지 아니면 민사소송법 제260조의 피고경정을 거쳐야 하는지> 검토해야 한다. 이하에서는 이와 관련한 당사자확정 및 피고 경정·표시정정 법리를 고찰하고 사안에 대입하여 丙의 주장 타당성 여부를 논한다.

II. 당사자확정 및 피고 사망 시의 보정 법리

1. 당사자의 확정 기준과 사자 대 상속인의 관계

(1) 당사자확정의 기준의 학설과 판례

- 소송 당사자 확정 기준에 대하여는 원고의 주관적 의사를 기준으로 하는 의사설, 소장 기재 표시를 기준으로 하는 표시설, 실제 소송 행위자를 기준으로 하는 행동설이 대립한다. 대법원은 소장의 전체적인 기재와 청구 내용 등을 종합하여 합리적으로 당사자를 확정하는 규범적 표시설(실질적 표시설)을 취한다.

(2) 소제기 전 사망한 경우의 당사자확정

- 실질적 표시설에 의할 때, 원고가 피고의 사망 사실을 모르고 사자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우, 원고의 실질적 의사는 상속인을 상대로 분쟁을 해결하려는 것이다. 따라서 표시에도 불구하고 실질적 피고는 처음부터 상속인으로 확정된다.

2. 사망자를 피고로 한 소송의 보정 방법

(1) 당사자표시정정설 (판례의 입장)

- 대법원은 소제기 전 사망자를 피고로 삼은 소송은 원칙적으로 부적법하다고 본다. 다만, 원고가 선의인 경우 실질적 피고는 상속인이고 단지 표시의 오류에 지나지 않으므로, 상속인으로서의 당사자표시정정을 허용한다. 이 경우 제소의 효과는 최초 소장 제출 시로 소급하여 발생한다.

(2) 피고경정설 (학설의 비판)

- 일부 학설은 사망한 사자에서 상속인으로 당사자를 바꾸는 것은 당사자의 동일성을 해치는 변경이라고 비판한다. 따라서 민사소송법 제260조의 피고경정 요건과 절차를 거쳐 피고를 변경해야 하며, 표시정정을 허용하는 판례의 태도는 타당하지 않다고 주장한다.

III. 사안의 적용

1. 실질적 피고의 확정 및 동일성 범위

(1) 실질적 피고의 확정

- 원고 甲은 피고 乙이 소제기 전 이미 사망한 사실을 모르고 매매잔대금 청구소송을 제기하였다. 실질적 표시설을 취하는 판례에 따를 때, 甲의 실질적 의사는 乙의 유일한 상속인인 丙을 피고로 삼으려는 것이므로, 실질적 피고는 처음부터 상속인 丙으로 확정된다.

(2) 당사자의 동일성 인정 여부

- 사망자 乙과 유일한 상속인 丙은 분쟁의 실제적 귀속 관계에서 실질적으로 동일한 주체로 평가된다. 따라서 피고의 명의를 乙에서 丙으로 변경하는 것은 당사자의 명백한 오기를 바로잡는 당사자표시정정의 범위 내에 포섭된다.

2. 당사자표시정정의 적법성 및 丙의 주장 판정

(1) 당사자표시정정의 적법성

- 甲은 乙의 사망 사실을 안 이후 피고를 丙으로 변경하는 당사자표시정정을 신청하여 법원의 허가를 받았다. 판례에 따를 때, 소제기 전 사망자를 피고로 오기한 경우 상속인 丙으로서의 당사자표시정정은 정당한 보정 방법으로서 전적으로 적법하다.

(2) 피고 丙의 주장의 타당성 검토

- 피고 丙은 당해 당사자표시정정이 동일성을 해쳐 부적법하다고 주장하나, 이는 성문법상의 피고경정만을 고집하는 비판론에 불과하다. 실질적 피고가 상속인 丙으로 확정된다는 판례에 비추어 볼 때, 丙의 이러한 독자적 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

IV. 결론

- 선의의 원고 甲이 소제기 전 사망한 乙을 피고로 삼은 경우, 실질적 피고는 처음부터 상속인 丙으로 확정되므로 乙에서 丙으로 피고를 변경하는 당사자표시정정은 소송법상 전적으로 적법하다. 따라서 법원의 당사자표시정정이 부적법하다는 피고 丙의 항변은 타당하지 않다. 법원은 丙의 주장을 배척하고 본안 심리를 진행하여야 한다.

《【문제2】 석명 의무에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 석명 의무의 의의, 내용과 대상, 범위, 한계, 위반의 효과

I. 문제의 제기

- 석명권이란 소송관계의 사실상 또는 법률상 사항에 관하여 당사자의 진술이 불분명하거나 불완전한 경우, 법원이 질문을 하거나 입증을 촉구하여 이를 명료하게 하는 권능을 의미한다.(민사소송법 제136조) 이는 변론주의의 단점을 보완하여 실질적 진실을 발견하고 당사자의 절차적 정의를 실현하기 위한 제도이다. 특히 법률 지식이 부족한 당사자가 본인의 의사를 적절히 표현하지 못해 패소하는 억울한 사례를 방지하는 기능을 한다. 석명권은 법원의 권한인 동시에 적절한 재판을 위한 의무적 성격도 지니고 있어, 이를 소홀히 한 경우 석명 의무 위반을 이유로 상고이유가 될 수 있다. 이하에서는 석명 의무의 구체적 내용과 범위, 그리고 변론주의와의 관계에서 발생하는 한계에 대해 설명한다.

II. 석명권의 내용과 대상

1. 사실관계의 석명

- 당사자의 주장 내용이 모순되거나 불투명할 때 이를 확실히 하는 것을 말한다.

(1) 취지의 명료화

- 당사자의 신청이나 진술이 법률적으로 무슨 의미인지 불분명할 때 그 취지를 묻는 것이다. 예를 들어 피고의 진술이 단순한 부인인지 항변인지 명확히 하는 행위가 이에 해당한다.

(2) 불완전한 주장의 보완

- 주장된 사실의 전후 관계가 맞지 않거나 누락된 부분이 있을 때 이를 보충하도록 권유하는 것이다.

2. 법률적 사항에 대한 석명(민사소송법 제136조 제4항)

- 법원은 당사자가 간과한 것이 분명하다고 인정되는 법률적인 사항에 관하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

(1) 법적 관점의 제시

- 당사자가 주장하는 법률적 근거가 부적절하거나 법원이 다른 법률적 시각에서 판단하고자 할 때 이를 당사자에게 미리 알려 불이익의 타격을 방지해야 한다.

(2) 법률적 지적 의무

- 당사자가 전혀 인식하지 못한 법률적 쟁점에 대하여 법원이 판결의 기초로 삼고자 한다면 반드시 석명을 통해 변론의 기회를 부여해야 한다.

III. 석명 의무의 범위

1. 소극적 석명

- 당사자의 진술 속에 포함되어 있으나 불분명한 것을 명확히 하는 단계로, 이는 당연한 법원의 의무에 해당한다.

2. 적극적 석명

- 당사자가 전혀 제출하지 않은 새로운 주장이나 증거를 제출하도록 권유하는 단계이다.

(1) 원칙적 제한

- 법원이 당사자가 주장하지도 않은 사실을 먼저 제시하거나 특정 방향으로 소송을 유도하는 것은 변론주의의 원칙과 법원의 중립성을 해칠 우려가 있어 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 예외적 허용

- 판례는 당사자가 청구의 기초에 비추어 당연히 내놓아야 할 주장을 단순히 법률 지식의 부족으로 빠뜨린 경우나, 소송 자료가 이미 제출되어 있어 조금만 주의를 기울이면 알 수 있는 사항에 대해서는 예외적으로 적극적 석명을 인정하고 있다.

IV. 석명 의무의 한계

1. 변론주의와의 조화

- 석명권은 변론주의를 보완하는 수단이지 이를 대체하는 수단이 아니다. 당사자가 명백히 거부하는 주장을 강요하거나, 당사자의 의사에 반하여 새로운 소송물을 추가하도록 하는 것은 한계를 벗어난 것이다.

2. 중립 의무의 준수

- 법원은 어느 한쪽 당사자에게 치우쳐 승소를 돕는 조연자가 되어서는 안 된다. 석명은 양 당사자에게 공평하게 행사되어야 하며, 재판의 객관적 공정성을 의심받을 정도에 이르러서는 안 된다.

V. 석명 의무 위반의 효과

1. 상소 이유

- 중요한 사항에 대하여 법원이 석명 의무를 다하지 않아 판결 결과에 영향을 미쳤다면, 이는 심리미진의 위법으로서 항소 및 상고의 이유가 된다.

2. 판례의 경향

- 대법원은 당사자의 진술이 모순되거나 증거와 명백히 배치됨에도 법원이 이를 바로잡지 않고 그대로 판결한 경우 석명 의무 위반을 이유로 원심판결을 파기하는 등 엄격하게 판단하는 추세이다.

VI. 결론

- 석명 의무는 현대 민사소송에서 실질적 평등과 공정한 재판을 실현하기 위한 핵심적인 도구이다. 법원은 당사자의 자율성을 존중하는 변론주의의 틀 안에서, 법률적 문해력이 낮은 당사자가 절차적 불이익을 당하지 않도록 세심하게 석명권을 행사해야 한다. 특히 법률적 사항에 대한 지적 의무는 당사자에게 예측 가능성을 부여하고 판결에 대한 승복도를 높이는 데 기여한다. 법원은 석명권의 오남용을 경계하면서도, 진실 발견을 위해 필요한 범위 내에서는 과감하게 입증을 촉구하고 주장을 명료화하는 능동적인 역할을 수행해야 한다. 이하에서는 이러한 석명 의무의 실천이 사법 신뢰를 회복하는 중요한 밑거름이 됨을 강조한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2020-3]유사필수적 공동소송의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 특징

《【문제3】 유사필수적 공동소송에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 유사필수적 공동소송의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 특징

I. 문제의 제기

- 유사필수적 공동소송이란 공동소송인들 사이에 소송물이 이론상 합일확정될 필요는 없으나, 법률의 규정에 의하여 판결의 효력이 제3자에게 미치거나(대세효) 판결의 결과가 반드시 일치해야 하는 공동소송을 의미한다.(민사소송법 제67조 준용) 이는 고유필수적 공동소송과 달리 당사자 전원이 함께 소를 제기하거나 제기당할 필요는 없지만, 일단 공동소송이 성립하면 그 절차 내에서는 심리 및 확정의 통일이 강제되는 형태이다. 주로 회사관계 소송이나 행정소송 등에서 판결의 모순을 방지하기 위해 인정된다. 이하에서는 유사필수적 공동소송의 성립요건과 소송수행 과정에서의 특징, 그리고 고유필수적 공동소송과의 구별점에 대해 설명한다.

II. 유사필수적 공동소송의 성립요건

1. 공동소송인 간의 합일확정 필요성

- 판결의 결과가 공동소송인들 사이에서 서로 모순되지 않게 일치해야 할 법률상 필요성이 있어야 한다. 이는 주로 판결의 효력이 당사자 이외의 제3자에게도 미치는 대세효가 인정되는 경우에 발생한다.

2. 소송의 개시와 당사자 적격

- 고유필수적 공동소송과 달리, 공동소송인 전원이 소송의 당사자가 될 필요는 없다. 각 당사자는 단독으로 소를 제기하거나 피고가 될 수 있는 당사자 적격을 가진다. 다만, 여러 사람이 동일한 대상에 대하여 소를 제기하여 소송이 병합된 경우에 비로소 유사필수적 공동소송으로서의 성질을 갖게 된다.

III. 유사필수적 공동소송의 구체적 사례

1. 회사관계 소송

- 상법상 주주총회결의 취소의 소, 무효확인 소 등이 대표적이다. 동일한 결의에 대하여 여러 주주가 각기 소를 제기한 경우, 판결의 효력이 모든 주주에게 미치므로(상법 제190조 준용) 병합된 소송은 유사필수적 공동소송이 된다.

2. 행정소송

- 행정처분의 취소를 구하는 소송에서 여러 사람이 동일한 처분에 대하여 소를 제기한 경우, 취소판결의 제3자효(행정소송법 제29조)로 인하여 합일확정이 필요하므로 유사필수적 공동소송이 성립한다.

IV. 소송수행상의 특징(민사소송법 제67조 준용)

1. 소송자료의 공통

- 공동소송인 중 1인의 소송행위는 전원의 이익을 위해서만 효력을 가진다. 따라서 1인이 제출한 유리한 증거나 주장은 다른 공동소송인에게도 효력이 미치지지만, 1인이 행한 자백이나 포기 등 불리한 행위는 전원이 함께하지 않는 한 효력이 발생하지 않는다.

2. 소송진행의 공통

- 공동소송인 1인에 대한 중단이나 중지 사유는 전원에게 영향을 미친다. 또한 기일의 통지나 송달 등 절차적 사항도 전원을 대상으로 이루어져야 소송 절차의 통일성을 유지할 수 있다.

3. 판결의 합일확정

- 법원은 공동소송인들에 대하여 반드시 하나의 판결을 내려야 하며, 판결의 주문에서 각 당사자별로 결론이 달라져서는 안 된다. 일부 당사자에 대한 일부판결은 허용되지 않는다.

V. 상소 제기 시의 취급

1. 상소의 불가분 원칙

- 공동소송인 중 1인이 상소를 제기하면 소송 전체가 상소심으로 이전하며, 상소를 제기하지 않은 다른 공동소송인도 상소심의 당사자가 된다. 이는 판결의 합일확정을 위해 필수적인 조치이다.

2. 상소심의 심판 범위

- 상소심 법원은 상소를 제기한 당사자의 불복 범위에 국한되지 않고, 공동소송인 전체의 청구에 대하여 심리하고 판결해야 한다.

VI. 고유필수적 공동소송과의 구별

1. 소의 제기 단계에서의 차이

- 고유필수적 공동소송은 처음부터 전원이 함께 소를 제기하지 않으면 소 자체가 부적법하여 각하되나, 유사필수적 공동소송은 단독 제기가 가능하며 절차 도중의 병합을 통해 필수적 공동소송의 형태를 띠는 점에서 차이가 있다.

2. 추가의 허용 여부

- 유사필수적 공동소송에서는 민사소송법 제68조에 따른 공동소송인 추가 제도가 적용되지 않는다. 단독으로 소 제기가 가능하므로 누락된 자를 추가할 필요가 없기 때문이다.

VI. 결론

- 유사필수적 공동소송은 판결의 대세효로 인해 발생할 수 있는 법적 혼란을 방지하기 위한 제도적 장치이다. 단독 소제기의 자유를 보장하면서도 일단 병합된 이후에는 심리의 통일을 강제함으로써 재판의 모순을 제거하고 사법 신뢰를 높이는 기능을 수행한다. 실무적으로는 회사 소송이나 다수인이 연루된 행정 소송에서 빈번히 활용되므로, 법원은 합일확정의 원칙에 따라 소송자료의 공통과 상소의 불가분 원칙을 엄격히 적용하여 당사자 간의 형평을 기해야 한다. 이하에서는 이러한 공동소송 제도가 복잡한 현대적 분쟁을 효율적으로 해결하는 유용한 틀로 기능해야 함을 강조한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제03절 불요증사실>

[기출][2021-1-1]재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

《[문제1] 甲은 乙에게 5,000만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50점)

(물음1) 제1심 제1회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000만 원을 모두 변제했다고 주장하였고, 이에 대해 甲은 그 중 2,000만 원을 반환받은 사실이 있다고 진술하였다. 그러나 제2회 변론기일에 甲은 종전의 진술을 철회하고, 乙로부터 전혀 변제받은 적이 없다고 주장하였다. 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음1> 재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙과 丙을 상대로 대여금 및 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였는데, 제1회 변론기일에서 2,000만 원의 일부변제를 인정하였다가 제2회 변론기일에서 이를 철회하며 전혀 변제받지 않았다고 주장한 상황이다. 쟁점으로 <甲의 일부변제 인정 진술이 재판상 자백에 해당하는지, 그 철회가 허용되는지>와 <이에 따라 법원이 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용할 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 일부변제 인정 진술의 재판상 자백 해당 여부와 자백철회의 허용 여부 및 이에 따른 법원의 판단 가능 여부를 담한다.

II. 재판상 자백의 법리

1. 재판상 자백의 성립요건과 대상

(1) 재판상 자백의 개념 및 성립요건

- 재판상 자백이란 소송계속 중 당사자가 변론이나 준비절차에서 행한 상대방의 주장과 일치하고 자신에게 법률상 불이익한 사실의 인정 진술을 의미한다. 이는 대립하는 당사자 간의 원활한 심리 조율과 사적 자치의 원칙을 법원에 관철하는 소송법상 제도로써 반드시 변론기일 또는 변론준비기일에 행해져야 성립한다.

(2) 자백의 대상이 되는 사실

- 재판상 자백의 대상은 원칙적으로 구체적인 사실에 한하며, 법률적 평가나 의견 또는 권리관계의 존부는 제외된다. 또한 사실 중에서도 판결의 직접적인 법률 효과를 발생시키는 주요사실에 한하여 자백의 효력이 발생하며, 간접사실이나 보조사실에 대해서는 법원의 자유심증을 방해하지 않기 위해 원칙적으로 재판상 자백의 성립이 인정되지 않는다.

2. 재판상 자백의 효력과 철회의 제한

(1) 재판상 자백의 구속력

- 재판상 자백이 적법하게 성립하면 그 사실에 대해서는 더 이상 별도의 증명을 요하지 않는다.(민사소송법 제288조) 나아가 자백은 법원과 당사자 쌍방을 모두 구속하므로, 법원은 자백된 사실과 반대되는 사실을 인정하여 판결의 기초로 삼을 수 없으며, 당사자 역시 이를 마음대로 철회하여 다룰 수 없다.

(2) 자백 철회의 예외적 허용 요건

- 재판상 자백은 소송의 안정성을 위해 철회가 제한되지만, 당사자의 실질적 권리 구제와 구체적 타당성을 달성하기 위하여 다음과 같은 특별한 예외 조건에 부합할 때는 소송법상 철회가 허용된다.

① 상대방의 동의 또는 형사상 처벌받을 타인의 행위의 존재

- 자백 진술의 철회에 대하여 소송 상대방이 명시적으로 동의하였거나, 자백이 제3자의 기망이나 강박 등 형사상 처벌을 받을 수 있는 위법한 범죄 행위에 의하여 유발되었음이 규명된 경우에는 자백을 철회할 수 있다.

② 착오로 인한 진술이고 진실에 반함의 증명

- 당해 자백이 객관적 진실에 정면으로 반할 뿐만 아니라, 그 자백을 한 당사자가 중대한 착오로 인하여 사실과 다른 진술을 하였음이 소송 과정에서 엄격하게 주장·증명된 경우에는 법원의 구속력을 배제하고 적법하게 철회할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 일부 변제 수령 진술의 재판상 자백 성립 여부

(1) 자백 사실의 판단

- 사안에서 피고 乙은 대여금 5,000만 원 전액을 변제하였다는 권리소멸 항변을 제기하였으며, 이는 대여금 청구의 방어방법에 해당하는 주요사실이다. 이에 대하여 원고 甲이 '그 중 2,000만 원을 반환받은 사실이 있다'라고 변론한 것은, 乙이 주장한 변제 사실과 2,000만 원 범위 내에서 완벽히 일치하므로 대립하는 당사자 간의 주장 일치 요건을 충족한다.

(2) 불이익한 사실 인정

- 대여금 청구소송에서 이미 대금의 일부를 변제받았음을 직접 인정하는 진술은 원고 자신의 청구권의 범위를 감축시키는 법적 효과를 발생시킴으로 甲에게 불이익한 사실의 인정에 해당한다. 따라서 甲의 진술은 2,000만 원의 범위 내에서 민사소송법상 적법한 재판상 자백으로 성립한다.

2. 甲의 진술 철회의 효력 및 법원의 판결

(1) 자백 철회의 효력 판단

- 원고 甲은 제2회 변론기일에 종전의 2,000만 원 변제 수령 진술을 철회하고자 하였다. 그러나 피고 乙이 이에 대하여 명시적으로 동의하였거나, 甲의 자백이 타인의 형사상 처벌받을 행위에 매개되어 행해졌다는 사정은 전혀 보이지 않는다. 또한 甲은 자신의 선행 진술이 진실에 반하고 착오로 인한 것임을 입증하지도 못하였다. 따라서 甲의 진술 철회는 소송법상 요건을 결여하여 무효이며, 최초의 자백의 구속력은 소송절차 내에 유효하게 유지된다.

(2) 법원의 전부 인용 판결 가능성

- 소수법원은 자백의 구속력에 전적으로 귀속되므로, 자백된 2,000만 원의 변제 사실을 그대로 판결의 기초로 삼아야 하고 이와 반대되는 사실 인정을 할 수 없다. 따라서 법원은 청구금액 5,000만 원 중 자백에 의하여 이미 채무 소멸이 입증된 2,000만 원 청구 부분은 기각하고, 자백의 구속력이 미치지 않는 나머지 3,000만 원 청구 부분만 인용하여야 한다. 결과적으로 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 없다.

N. 결론

- 원고 甲의 2,000만 원 변제 수령 진술은 소송법상 재판상 자백에 해당하여 법원과 당사자에게 구속력을 미친다. 또한 甲이 행한 자백의 철회는 예외적 허용 요건을 전혀 갖추지 못하여 효력이 없다. 자백의 구속력에 의하여 2,000만 원 변제 사실이 확정되므로 법원은 甲의 대여금 청구 전부를 인용할 수 없으며, `피고 乙은 원고 甲에게 금 3,000만 원을 지급하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.`라는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2021-1-2]공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

《[문제1] 甲은 乙에게 5,000만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50점)》

(물음2) 제1심 제1회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000만 원을 모두 변제했다고 주장하고 그에 관한 증거를 제출하였다. 그러나 丙은 답변서도 제출하지 않았고 변론기일에도 불출석하였다. 법원이 증거조사한 결과 乙의 주장이 타당하다는 심증을 형성하였다면, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 기각하는 판결을 할 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음2> 공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 주채무자로, 丙을 보증채무자로 하여 대여금 반환을 구하는 공동소송을 제기하였고, 乙은 변제항변과 증거를 제출한 반면 丙은 소송에 응하지 않은 상황이다. 쟁점으로 <공동소송인 중 일부 당사자의 주장과 증거가 다른 공동소송인에 대한 청구 판단에 미치는 영향 및 법원이 甲의 각 청구를 함께 기각할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 공동소송의 형태와 심판방법, 공동소송인 사이의 주장·증거의 효력 및 이에 따른 법원의 판결 가능 여부를 설명한다.

II. 통상공동소송의 심리원칙과 자백간주의 법리

1. 공동소송인 독립의 원칙과 주장공통의 원칙

(1) 공동소송인 독립의 원칙

- 민사소송법 제66조에 의하면 공동소송인 1인의 소송행위, 상대방의 소송행위 및 1인에 대해 생긴 사항은 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 아니한다. 이를 공동소송인 독립의 원칙이라 하며, 사안의 주채무자·보증인 간 소송과 같은 통상공동소송에 전면 적용된다.

(2) 주장공통의 원칙의 인정 여부

- 공동소송인 독립의 원칙상 공동소송인 중 1인이 제출한 주요사실에 관한 주장은 다른 공동소송인에게 효력이 미치지 않는바, 이를 주장공통의 원칙 부정이라 한다. 대법원 역시 통상공동소송에서는 공동소송인 독립의 원칙이 적용되므로 공동소송인 중 1인이 한 주장은 다른 공동소송인에게 원칙적으로 효력이 미치지 않는다고 판시하여 이를 명백히 부정한다.

2. 증거공통의 원칙과 자백간주의 법리

(1) 증거공통의 원칙

- 증거공통의 원칙이란 공동소송인 중 1인이 제출한 증거는 다른 공동소송인과의 관계에서도 사실인정의 자료로 삼을 수 있다는 법리이다. 판례는 공동소송인 독립의 원칙에도 불구하고 소송 자료의 유기적 결합을 위해 이를 인정한다. 다만 변론주의 원칙상 사실의 주장이 전제되어야 하므로, 당사자가 주장하지 않은 사실을 타방의 증거만을 통해 임의로 인정할 수는 없다.

(2) 답변서 미제출 및 기일 불출석의 효과

- 민사소송법 제150조 제1항 및 제3항에 의하면, 당사자가 답변서를 제출하지 아니하고 변론기일에 출석하지 아니한 때에는 상대방이 주장한 사실을 자백한 것으로 본다. 이를 자백간주라 하며 법원은 이에 구속된다.

III. 사안의 적용

1. 피고 乙에 대한 청구의 판단

- 피고 乙은 제1회 변론기일에 변제 사실을 독자적으로 주장하였고 적법한 증거를 제출하였다. 수소법원이 심리 및 증거조사를 통해 乙의 변제 주장이 타당하다는 확고한 심증을 형성하였으므로, 대여금채무는 변제로 인하여 소멸한 사실이 인정된다. 따라서 법원은 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구를 기각하여야 한다.

2. 피고 丙에 대한 청구의 판단

(1) 주장공통원칙의 부정에 따른 제한

- 피고 丙은 소송과정에서 어떠한 변제 주장도 제기하지 않았다. 주장공통의 원칙이 부정되므로 주채무자 乙이 행한 변제 주장은 보증인 丙에게 효력이 미치지 않는다.

(2) 증거공통원칙의 적용 한계와 자백간주의 성립

- 乙이 제출한 증거가 증거공통의 원칙에 따라 丙을 위해서도 사용될 수 있으나, 변론주의의 한계상 丙이 변제 사실 자체를 주장하지 않았으므로 법원은 丙을 위하여 변제 사실을 인정할 수 없다. 나아가 丙은 답변서를 제출하지 않고 변론기일에 불출석하였으므로 민사소송법 제150조에 따라 甲이 주장한 대여금 채무의 존재를 자백한 것으로 의제된다.

(3) 부증성의 예외적 차단과 판결의 범위

- 보증채무의 부증성이라는 실체법적 성질이 존재하나, 소송법적으로는 변론주의와 공동소송인 독립의 원칙이 우선 적용된다. 따라서 법원은 丙에 대하여 변제 사실을 인정할 수 없으며 자백간주에 구속되므로, 보증채무의 이행을 구하는 甲의 丙에 대한 청구는 인용하여야 한다.

IV. 결론

- 수소법원은 주채무자인 피고 乙에 대한 청구는 변제 사실의 인정에 의하여 기각하여야 하는 반면, 보증인인 피고 丙에 대한 청구는 자백간주 성립에 의하여 인용하여야 한다. 결과적으로 법원은 피고 乙에 대한 청구는 기각하고 피고 丙에 대한 청구는 인용하는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 하므로, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 모두 기각하는 판결을 할 수는 없다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2021-2]당사자능력의 의의, 판정 기준, 비법인의 당사자능력, 당사자능력의 흠결과 효과

《【문제2】 당사자능력에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 당사자능력의 의의, 판정 기준, 비법인의 당사자능력, 당사자능력의 흠결과 효과

I. 문제의 제기

- 당사자능력이란 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력을 의미하며, 이는 민법상 권리능력에 대응하는 개념이다. 소송절차의 안정성과 실효성을 확보하기 위해 누가 소송의 당사자가 될 수 있는지를 확정하는 것은 소송요건 중 가장 기초적인 단계에 해당한다. 민사소송법은 원칙적으로 민법상 권리능력자에게 당사자능력을 인정하나, 소송의 편의를 위해 법인이 아닌 사단이나 재단에 대해서도 일정한 요건 하에 당사자능력을 예외적으로 인정하고 있다. 당사자능력은 소송의 전 과정에서 유지되어야 하는 직권조사사항이며, 이를 결여한 소송행위는 원칙적으로 무효이다. 이하에서는 당사자능력의 구체적인 판정 기준과 비법인 사단의 당사자능력, 능력이 흠결된 경우 법원이 취해야 할 조치를 중심으로 설명한다.

II. 당사자능력의 판정 기준

1. 자연인

- 모든 자연인은 생존하는 동안 당사자능력을 가진다. 국적이냐 연령, 정신상태와 관계없이 인격을 가진 존재라면 누구나 소송의 당사자가 될 수 있다.

(1) 태아의 당사자능력

- 태아는 원칙적으로 권리능력이 없으므로 당사자능력도 부정된다. 판례는 태아가 소송을 제기하기 위해서는 살아서 출생해야 한다는 정치조건설의 입장을 취하므로, 태아인 상태에서 제기된 소는 부적법하다.

(2) 외국인의 당사자능력

- 외국인도 자연인인 이상 당사자능력을 가진다. 다만, 소송비용 담보제공 등의 제한이 따를 수 있으나 능력 자체는 부정되지 않는다.

2. 법인

- 법인은 설립등기를 마침으로써 권리능력을 취득하며, 동시에 당사자능력을 가진다. 영리법인, 비영리법인, 공법인(국가, 지방자치단체) 모두 포함된다.

(1) 국가 및 지방자치단체

- 국가는 사법관계에서도 당사자능력을 가지며, 지방자치단체 역시 공법인으로서 당사자능력을 인정받는다. 그러나 지방자치단체의 하부조직인 동이나 면은 원칙적으로 당사자능력이 없다.

(2) 청산 중의 법인

- 법인이 해산되더라도 청산 사무가 완료될 때까지는 청산의 목적 범위 내에서 당사자능력을 유지한다.

III. 비법인 사단 및 재단의 당사자능력

1. 의의 및 인정 근거[민사소송법 제52조]

- 법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 이름으로 소송의 당사자가 될 수 있다. 이는 실질적으로 사회적 활동을 수행하는 단체의 소송 편의를 도모하기 위함이다.

2. 인정 요건

(1) 사단의 실체

- 단체로서의 조직을 갖추고 있고, 의사결정기관과 집행기관인 대표자가 선임되어 있어야 하며, 구성원의 변경과 관계없이 단체 자체가 존속되어야 한다.

(2) 독립된 재산의 존재

- 단체 고유의 목적을 달성하기 위한 독립된 재산이 형성되어 있어야 한다.

3. 구체적 사례에 대한 판례의 태도

(1) 중증

- 중증은 특별한 조직 행위가 없어도 공동조상의 후손들에 의해 당연 성립하는 종족 단체로서, 대표자가 선임되어 있다면 당사자능력이 인정된다.

(2) 학교

- 학교는 시설물에 불과하므로 당사자능력이 없다. 소송을 제기하려면 학교를 운영하는 법인이나 경영자를 당사자로 해야 한다.

(3) 조합

- 민법상 조합은 원칙적으로 당사자능력이 없다. 따라서 조합원 전원이 공동으로 소송을 수행하거나 선정당사자 제도를 활용해야 한다. 다만, 실무상 재건축조합 등은 비법인 사단의 실체를 갖춘 경우 민사소송법 제52조에 의해 당사자능력이 인정되기도 한다.

IV. 당사자능력의 흠결과 소송법적 효과

1. 직권조사사항

- 당사자능력의 존부는 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 항변이 없더라도 법원은 이를 스스로 조사하여야 하며, 상고심에서도 새로운 증거를 통해 이를 판단할 수 있다.

2. 소송계속 전후의 흠결

(1) 소 제기 당시부터 흠결된 경우

- 소 제기 당시에 이미 당사자능력이 없는 자를 상대로 하거나 그 명의로 제기된 소는 부적법하므로 법원은 소각하 판결을 내려야 한다. 다만, 보정이 가능한 경우에는 보정을 명할 수 있다.

(2) 소송 진행 중 흠결된 경우(당사자의 사망 등)

- 소송 도중 당사자가 사망하거나 법인이 해산된 경우에는 소송절차가 중단되며, 상속인이나 합병 후의 법인이 소송을 수계하여야 한다.

3. 당사자표시정정과의 관계

- 당사자를 잘못 지정했으나 실질적으로 동일성이 인정되는 경우에는 당사자표시정정을 통해 하자를 치유할 수 있다. 그러나, 동일성이 인정되지 않는 전혀 다른 사람으로 정정하는 것은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 당사자능력은 소송절차의 유효한 성립을 위한 필수적 전제 요건이다. 민사소송법이 비법인 사단에 대해 당사자능력을 인정하는 것은 현대 사회의 다양한 단체 활동을 소송법적으로 수용하기 위한 합리적인 조치이다. 법원은 당사자능력의 유무를 엄격히 심사하여 부적법한 소송에 의한 사법 자원의 낭비를 막아야 하며, 동시에 당사자표시정정이나 보정 명령 등을 적절히 활용하여 당사자의 재판받을 권리가 절차적 형식주의에 의해 침해되지 않도록 균형을 유지해야 한다.

《【문제3】중간확인 소에 대하여 설명하십시오. (25점)》

<문제3> 중간확인 소의 의의, 요건, 절차, 효력

I. 문제의 제기

- 중간확인 소란 소송계속 중 본래의 청구(주청구)의 판단의 전제가 되는 법률관계의 존부에 관하여 다툼이 있는 경우, 당해 소송절차를 이용하여 그 법률관계의 확정을 구하는 소를 말한다.(민사소송법 제264조) 이는 판결의 이유 중에서만 판단되는 선결적 법률관계에 대하여 기판력을 부여함으로써 동일한 쟁점에 대한 반복된 소송을 방지하고 분쟁을 일거에 해결하기 위한 제도이다. 통상적인 소의 추가적 병합의 일종이지만, 기존의 증거자료를 그대로 활용할 수 있다는 점에서 소송경제에 부합한다. 이하에서는 중간확인 소가 적법하기 위한 요건과 제기 절차, 그리고 그에 따른 소송법적 효력에 대해 설명한다.

II. 중간확인 소의 요건

1. 선결적 법률관계의 존재

- 중간확인 소의 대상은 주청구의 판단의 전제가 되는 법률관계여야 한다.

(1) 법률관계의 의미

- 권리나 의무 또는 법률상의 지위를 의미하며, 단순한 사실관계나 증거의 존부는 대상이 될 수 없다. 예를 들어 소유권이전등기청구소송에서 그 전제가 되는 매매계약의 유효 여부나 소유권 자체의 존부가 이에 해당한다.

(2) 선결성

- 본래의 청구가 인용되거나 기각되는 데 있어 반드시 그 존부가 확정되어야 하는 관계에 있어야 한다. 주청구의 인용 여부와 무관한 별개의 법률관계는 중간확인 소의 대상이 될 수 없다.

2. 상대방의 다툼이 있을 것

- 선결적 법률관계에 대하여 당사자 사이에 다툼이 있어야 한다. 상대방이 이를 인정하여 자백이 성립한 경우에는 확인의 이익이 없으므로 중간확인 소를 제기할 수 없다.

3. 주청구가 소송계속 중일 것

- 주청구가 사실심에 계속 중이어야 한다. 주청구가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸하면 중간확인 소도 부적법하게 된다. 다만, 항소심에서도 선결적 법률관계의 확정이 필요하다면 제기할 수 있다.

4. 동종의 소송절차와 관할

- 중간확인 소는 본래의 소송과 동종의 소송절차에 따라야 하며, 전속관할에 위반되지 않아야 한다.

III. 중간확인 소의 절차

1. 제기의 방식

- 중간확인 소는 소의 변경에 관한 규정을 준용하므로 서면으로 제기함이 원칙이다.(민사소송법 제264조 제2항) 다만, 변론기일에서 말로 제기하는 것도 가능하며 이 경우에는 조서에 기재하여야 한다.

2. 제기 시기

- 사실심의 변론종결 전까지 제기할 수 있다. 상고심에서는 새로운 사실인정을 할 수 없으므로 중간확인 소를 제기하는 것이 허용되지 않는다.

IV. 중간확인 소의 효력

1. 심판의 방법

- 법원은 주청구와 중간확인 소를 병합하여 심리하여야 한다. 중간확인 소는 주청구와 별개의 소송물이지만 절차적으로는 병합된 소송으로 취급된다.

2. 판결의 형태

(1) 전부 판결

- 법원은 원칙적으로 주청구와 중간확인 소의 청구에 대하여 하나의 전부 판결을 내려야 한다.

(2) 중간판결과의 구별

- 법원이 선결적 법률관계에 대하여 중간판결을 내릴 수도 있으나, 이는 당해 소송 내부에서 법원을 구속할 뿐 기판력이 발생하지 않는다. 반면 중간확인 소에 의한 판결은 종국판결로서 기판력이 발생한다.

3. 기판력의 발생

- 중간확인 소에 대한 판결이 확정되면 그 선결적 법률관계의 존부에 대하여 기판력이 발생한다. 따라서 추후 별개의 소송에서 동일한 선결적 법률관계가 다시 문제 될 경우 당사자는 이에 반하는 주장을 할 수 없으며 법원도 이에 저촉되는 판결을 할 수 없다.

V. 결론

- 중간확인 소는 판결 이유 속의 판단에 불과했던 선결적 법률관계를 주문에 표시함으로써 기판력을 확장시키는 기능을 한다. 이는 당사자 간의 분쟁을 근본적으로 해결하고 법적 안정성을 높이는 데 크게 기여한다. 특히 복잡한 권리관계가 얽힌 현대 소송에서 동일한 원인에 기한 후속 소송을 예방한다는 점에서 그 실익이 크다. 법원은 중간확인 소의 요건인 선결성을 엄격히 심사하되, 제도의 취지에 비추어 당사자가 효율적으로 분쟁을 종결지을 수 있도록 절차를 운영하여야 한다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제01절 청구의 원시적 병합>

[기출][2022-1-1]예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법

《[문제1] 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4인을 대표한다고 주장하는 乙은 X토지를 甲으로부터 매수하기로 하고 甲과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X토지의 등기를 위 4인에게 이전하여 주었으나 위 4인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음1) 제1심 법원은 乙에게 적합한 대리권이 없었다는 것을 이유로 원고의 주위적 청구를 배척하면서도 예비적 청구에 대하여는 아무런 판단을 하지 않았다. 이러한 제1심 법원의 판결에 대해 적법 여부와 불복방법에 관하여 쓰시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 매매대금 지급을 구하는 주위적 청구와 소유권이전등기 말소를 구하는 예비적 청구를 병합하여 제기하였으나 제1심 법원이 주위적 청구만 배척하고 예비적 청구에 대한 판단을 누락한 상황이다. 쟁점으로 <법원이 예비적 청구에 대한 판단을 하지 않은 경우의 판결의 적법성과 이에 대한 당사자의 불복방법>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 예비적 병합청구에서 판단누락의 효력과 이를 시정하기 위한 상소방법을 설명한다.

II. 예비적 병합의 심판법리와 재판의 유탈

1. 일부판결의 허용 여부

(1) 예비적 병합의 심판원칙

- 예비적 병합이란 원고가 양립할 수 없는 수개의 청구를 제기하면서 주위적 청구가 기각되거나 인용되지 않을 것을 해제조건으로 하여 예비적 청구의 심판을 구하는 소송 형태이다. 소수법원은 원고가 정한 심판 순위에 전적으로 구속되므로, 반드시 주위적 청구를 먼저 심리·판단하여야 한다.

(2) 절차적 불가분성과 일부판결 금지

- 예비적 병합은 각 청구가 조건부로 결부되어 있어 절차적으로 분리될 수 없는 불가분적 성질을 지닌다. 따라서 수개의 청구를 분리하여 변론하거나 일부판결을 선고하는 것은 소송법상 허용되지 않는다.

2. 판단 유탈의 법적 성질

(1) 학설의 대립

- 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구 판단을 빠뜨린 경우에 대하여 견해가 대립한다. ① 재판누락설은 이를 민사소송법 제212조의 재판의 누락으로 보아 누락된 부분이 여전히 원심에 계속되어 있으므로 추가판결을 구해야 한다는 견해이다. ② 판단누락설은 일부판결을 할 수 없는 경우에 해당하여 하자가 있는 전부판결로서 판단의 누락에 해당하고 상소로 다투어야 한다는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원 전원합의체 판결은 판단누락설의 입장이다. 예비적 병합에서는 일부판결이 허용되지 않으므로, 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대한 판단을 누락한 판결은 형식적으로 전부판결로 취급되며, 이는 판결의 내용상 흠결인 판단의 누락에 해당한다고 판단하였다.

III. 사안의 적용

1. 제1심 판결의 적법 여부 검토

(1) 심판의무의 위배

- 원고 甲이 임차 및 매매계약과 관련하여 제기한 주위적 청구(매매대금 청구)와 예비적 청구(이전등기말소 청구)는 계약의 유효·무효를 전제로 하므로 양립 불가능한 예비적 병합 관계이다. 제1심 법원이 乙의 대리권 결여를 이유로 주위적 청구를 배척하였다면, 조건 성취로 인해 예비적 청구를 판단하여야 할 심판의무가 당연히 발생한다.

(2) 일부판결 위법의 존재

- 그럼에도 제1심 법원이 주위적 청구에 대해서만 기각 판결을 선고하고 예비적 청구에 대해 판단하지 않은 것은 일부판결을 전면 금지하는 예비적 병합의 심판법리를 정면으로 위반한 위법이 존재하므로 부적법하다.

2. 원고 甲의 적법한 불복방법

(1) 추가판결 신청의 불가능

- 판례의 판단누락설에 의하면, 제1심의 부적법한 판결은 재판의 누락이 아닌 전부판결에서의 판단의 누락에 해당하므로 제1심의 소송계속은 종료된다. 따라서 원고 甲은 제1심 법원에 대하여 민사소송법 제212조에 따른 추가판결을 청구할 수 없다.

(2) 항소 제기를 통한 구제

- 원고 甲은 제1심의 위법한 판결 전부에 대하여 적법하게 항소를 제기하여야 한다. 이 경우 항소제기에 따른 이심의 효력에 의해 주위적 청구뿐만 아니라 판단이 누락된 예비적 청구까지 청구 전부에 대하여 항소심으로 이심된다. 항소심 법원은 제1심의 위법을 시정하기 위해 누락된 예비적 청구까지 심판 범위에 포함하여 판단하여야 한다.

IV. 결론

- 법원이 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대하여 아무런 판단을 하지 않은 판결은 일부판결을 할 수 없는 예비적 병합의 소송법적 대원칙을 무시하여 내린 판결로서 위법하며 부적법하다. 해당 판결은 판단의 누락에 해당하므로 원고 甲은 추가판결을 신청할 수 없으며, 제1심 판결에 대하여 적법하게 항소를 제기함으로써 사건 전체를 항소심으로 이심시켜 유탈된 예비적 청구에 대한 올바른 판결을 받아야 한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2022-1-2]공동선정당사자 중 1인의 진술이 가지는 소송상 효력

《【문제1】 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4인을 대표한다고 주장하는 乙은 X토지를 甲으로부터 매수하기로 하고 甲과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X토지의 등기를 위 4인에게 이전하여 주었으나 위 4인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음2) 소송계속 중 乙, 丙, 丁, 戊는 乙과 丙을 선정당사자로 선정하였다. 심리 도중 丙은 매매대금의 일부가 甲에게 이미 지급되었다고 주장하고 있으나, 乙은 甲이 주장하는 바와 같이 매매대금의 전액이 미지급상태에 있다고 진술하였다. 이러한 乙의 진술은 소송상 어떠한 효력을 가지는지 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 공동선정당사자 중 1인의 진술이 가지는 소송상 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙, 丙, 丁, 戊가 선정당사자를 선정하여 소송을 수행하는 과정에서 선정당사자인 乙과 丙이 서로 다른 내용의 진술을 하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <선정당사자가 복수인 경우 각 선정당사자의 소송상 진술이 다른 선정자 및 다른 선정당사자에게 미치는 효력과 그 법적 의미>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 선정당사자의 소송수행권과 선정당사자 상호 간 진술의 효력 및 소송상 취급을 검토한다.

II. 선정당사자 제도의 의의 및 법적 지위

1. 의의

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중에서 그 집단을 대표하여 소송을 수행하기 위해 선정된 사람을 말한다.(민사소송법 제53조) 이는 다수당사자 소송의 복잡함을 피하고 소송경제를 도모하기 위한 제도이다.

2. 법적 지위

- 선정당사자는 선정자들로부터 소송수행권을 위임받은 법정소송담당자이다. 선정당사자가 선정되면 선정자들은 소송에서 탈퇴하게 되며, 선정당사자가 받은 판결의 효력은 민사소송법 제218조 제3항에 따라 선정자 전원에게 미친다.

III. 공동선정당사자의 소송수행 방식

1. 소송수행의 독립성 원칙

- 선정당사자가 여러 명 선정된 경우, 각 선정당사자는 원칙적으로 독립하여 소송을 수행할 수 있다. 즉, 각자가 전원을 위하여 소송행위를 할 수 있는 권한을 가진다.

2. 필수적 공동소송 규정의 준용 여부

(1) 학설 및 판례의 태도

- 공동선정당사자 간의 관계에 대하여 판례는 민사소송법 제67조의 필수적 공동소송에 관한 규정을 준용한다. 선정당사자들은 선정자 전원을 위하여 하나의 소송물을 다투는 것이므로, 판결의 합일확정이 요구되기 때문이다.

(2) 소송행위의 효력 제한

- 필수적 공동소송 규정이 준용됨에 따라, 공동선정당사자 중 1인의 소송행위가 전원에게 이익이 되는 경우에는 효력이 발생하지만, 전원에게 불이익한 행위는 전원이 함께 하지 않으면 효력이 발생하지 않는다.

IV. 사안의 적용 : 乙의 진술에 대한 효력 판단

1. 乙과 丙의 진술 성격 분석

- 丙의 일부 지급 주장은 피고 측에 유리한 항변인 반면, 乙의 전액 미지급 진술은 원고의 주장을 시인하는 것으로서 피고 측(선정자 포함)에게 불리한 사실상의 자백 또는 자백에 준하는 진술에 해당한다.

2. 불리한 소송행위의 효력 제한(민사소송법 제67조 제1항)

- 필수적 공동소송의 원칙상 공동당사자 중 1인의 소송행위가 다른 공동당사자에게 불리한 경우에는 그 효력이 발생하지 않는다. 乙의 진술은 丙의 항변을 부정하고 원고의 청구 원인을 인정하는 것이므로 선정자들 전체에게 불이익한 행위이다.

3. 진술의 상충과 법원의 처리

- 공동선정당사자 간의 진술이 일치하지 않는 경우, 불이익한 진술을 한 乙의 행위는 효력이 없다. 따라서 乙의 진술은 재판상 자백으로서의 효력을 가질 수 없으며, 법원은 丙이 주장한 일부 변제 사실에 대하여 증거조사를 거쳐 사실관계를 확정하여야 한다.

V. 결론

- 공동선정당사자 중 1인인 乙이 행한 매매대금 전액 미지급이라는 진술은 다른 선정당사자인 丙의 진술과 상충하며, 선정자 전원에게 불리한 소송행위이다. 선정당사자 간에는 필수적 공동소송 규정이 준용되므로, 乙의 이러한 불리한 진술은 소송법상 효력이 발생하지 않는다. 법원은 乙의 자백에 구속되지 않고 丙의 항변을 바탕으로 대금 지급 여부를 심리하여야 한다.

《【문제2】 소송상 항변에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송상 항변의 의의, 부인과의 구별, 항변의 종류, 제출요건과 시기

I. 문제의 제기

- 소송상 항변이란 원고가 주장하는 청구원인 사실(요건사실)을 피고가 인정하면서도, 그와는 별개의 사실을 주장하여 원고 청구의 당부나 소송의 적법성을 다투는 방어방법을 의미한다. 이는 원고의 주장 사실 자체를 부정하는 부인과 구별되는 개념으로, 피고에게 증명책임이 전환된다는 점에서 실무상 매우 중요한 의미를 갖는다. 항소심 등 소송의 각 단계에서 항변의 제출 시기와 방식에 따라 소송의 결과가 크게 달라질 수 있다. 이하에서는 항변의 의의와 부인과의 구별 실익, 그리고 소송법상 항변과 본안전 항변 등 그 구체적인 종류에 대해 설명한다.

II. 항변의 의의와 부인의 구별

1. 항변의 개념

- 원고가 주장하는 요건사실의 존재를 전제로 하되, 그 법률효과의 발생을 저지·멸실·정지시키기 위하여 피고가 제출하는 별개의 독립된 사실 주장을 말한다.

2. 부인과의 구별 및 실익

(1) 개념적 차이

- 부인은 원고가 주장하는 사실 자체를 부정하는 것이며, 항변은 원고의 주장은 맞으나 다른 사정이 있다는 이유로 반박하는 것이다. 예를 들어 돈을 빌린 적 없다는 부인이지만, 돈을 빌렸으나 갚았다는 변제항변이다.

(2) 증명책임의 소재

- 부인의 경우 원고가 해당 사실의 존재를 증명해야 하지만, 항변의 경우 항변 사실에 대한 증명책임은 이를 주장하는 피고에게 전적으로 귀속된다.

III. 소송상 항변의 종류

1. 본안전 항변

- 원고의 청구가 적법한 소송요건을 갖추지 못하였음을 이유로 소를 부적법 각하해 달라고 구하는 방어방법이다.

(1) 부적법한 소의 제기 주장

- 관할위반, 중복소송, 재소금지 위반, 당사자 적격의 결여 등을 주장하는 것이 이에 해당한다.

(2) 직권조사사항과의 관계

- 소송요건은 법원의 직권조사사항이나, 당사자가 이를 지적하는 것은 법원의 주의를 촉구하는 의미의 본안전 항변이 된다. 다만, 임의관할이나 중재합의와 같은 변론관할의 경우에는 당사자의 항변이 있어야만 비로소 고려된다.

2. 본안상 항변

- 원고의 청구가 실체법상 이유 없음을 주장하여 청구기각 판결을 구하는 방어방법이다. 이는 법률효과에 따라 세 가지로 세분된다.

(1) 장애항변(성립저지 항변)

- 권리의 성립 자체를 방해하는 사실을 주장하는 것이다. 예 : 의사무능력, 선량한 풍속 위반(민법 제103조), 통정허위표시 등.

(2) 멸실항변(권리소멸 항변)

- 일단 유효하게 성립한 권리를 사후적으로 소멸시키는 사실을 주장하는 것이다. 예 : 변제, 소멸시효 완성, 상계, 면제 등.

(3) 저지항변(권리행사 저지 항변)

- 권리의 존재는 인정하나 그 행사를 일시적 또는 영구적으로 저지할 수 있는 사실을 주장하는 것이다. 예 : 동시이행의 항변권, 보증인의 최고·검색의 항변권 등.

IV. 항변의 제출 요건과 시기

1. 적기제출주의

- 민사소송법은 소송의 지연을 방지하기 위하여 공격방어방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하도록 규정하고 있다.

2. 실기한 공격방어방법의 각하

- 피고가 고의 또는 중대한 과실로 항변을 뒤늦게 제출하여 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 법원은 직권 또는 상대방의 신청에 의해 해당 항변을 각하할 수 있다.

V. 결론

- 소송상 항변은 피고가 자신의 권리를 보호하기 위해 행사하는 가장 강력한 법적 수단 중 하나이다. 특히 변제, 상계, 소멸시효와 같은 본안상 항변은 사건의 실체적 진실을 밝히는 데 핵심적인 역할을 한다. 당사자는 항변의 종류에 따른 증명책임을 명확히 인지하여야 하며, 법원은 제출된 항변이 단순한 부인인지 아니면 독립된 항변인지를 엄격히 구별하여 재판의 공정성과 효율성을 도모해야 한다. 이하에서는 이러한 항변권 행사가 신의성실의 원칙에 반하지 않도록 절차 내에서 적절히 통제되어야 한다.

《【문제3】 판결의 편취와 그 구제수단에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 판결의 편취의 의의, 유형, 확정 전·후 구제수단

I. 문제의 제기

- 판결의 편취란 당사자가 부정한 방법으로 법원을 기망하여 자기에 유리한 판결을 얻어내는 것을 의미한다. 이는 재판의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위이나, 일단 판결이 확정되면 기판력이 발생하므로 그 효력을 부인하기 위해서는 특별한 구제절차가 필요하다. 특히 상대방이 소송계속 사실을 알지 못한 상태에서 판결이 확정된 경우, 절차적 보권을 침해당한 당사자를 어떻게 보호할 것인지가 핵심이다. 이하에서는 판결 편취의 대표적인 유형과 그에 따른 상소 및 재심, 그리고 집행 단계에서의 구제방법에 대해 설명한다.

II. 판결 편취의 유형

1. 성명모용에 의한 판결

- 피고와 아무런 관계가 없는 사람이 피고의 이름을 사칭하여 소송을 수행하고 판결을 받는 경우이다.

2. 주소허위기재에 의한 판결

- 원고가 피고의 주소를 허위로 기재하여 송달이 불가능하게 하거나, 피고가 아닌 다른 사람이 서류를 받게 하여 피고가 소송 사실을 모르는 상태에서 승소 판결을 얻는 경우이다.

3. 공시송달의 남용

- 피고의 주소를 알고 있음에도 불구하고 주소불명으로 허위 신고하여 공시송달을 통해 판결을 편취하는 경우를 말한다.

III. 확정 전의 구제수단

1. 상소의 제기

- 판결이 선고되었으나 아직 확정되기 전이라면 통상의 상소(항소 또는 상고)를 통해 판결의 부당함을 다룰 수 있다.

2. 추완항소(민사소송법 제173조)

- 피고가 책임질 수 없는 사유로 인하여 항소기간을 지키지 못한 경우, 그 사유가 없어진 날로부터 2주 이내에 항소를 제기할 수 있다. 주소허위기재나 공시송달 편취의 경우 피고가 판결 사실을 뒤늦게 알게 되므로 추완항소가 주된 구제책이 된다.

IV. 확정 후의 소송법적 구제수단

1. 재심의 소(민사소송법 제451조)

- 판결이 확정된 후에는 재심 사유를 들어 재심의 소를 제기할 수 있다.

(1) 제451조 제1항 제3호(법정대리권 등의 흠)

- 성명모용 판결의 경우 대리권의 흠결을 이유로 재심을 청구할 수 있다.

(2) 제451조 제1항 제11호(허위 진술 등)

- 상대방의 기망행위가 형사상 처벌받을 범죄행위에 해당하는 경우 이를 이유로 재심을 제기할 수 있다.

2. 판례의 태도(무효선언설)

- 판례는 성명모용 판결과 같이 절차상 중대한 하자가 있는 경우, 그 판결은 기판력이 발생하지 않는 무효인 판결이라고 본다. 따라서 재심 절차 없이도 별도의 소송을 통해 권리관계를 다룰 수 있다고 본다. 반면 주소허위기재에 의한 판결은 일단 유효하므로 반드시 상소나 재심으로 취소되어야 한다고 본다.

V. 집행 단계 및 실체법적 구제수단

1. 청구이의의 소(민사집행법 제44조)

- 편취된 판결에 기초하여 강제집행이 들어오는 경우, 피고는 판결에 나타난 청구권이 실체법상 존재하지 않음을 이유로 청구이의의 소를 제기하여 집행력을 배제할 수 있다. 다만, 판례는 기판력의 차단효 때문에 전소 판결을 취소하지 않은 상태에서 청구이의의 소를 제기하는 것에는 소극적이다.

2. 손해배상청구 및 부당이득반환청구

- 판결을 편취한 자를 상대로 불법행위에 기한 손해배상을 청구하거나, 그 판결로 얻은 이익에 대해 부당이득반환을 청구할 수 있다. 판례는 판결이 취소되지 않았더라도 그 판결을 집행하는 것 자체가 사회통념상 허용되지 않는 경우 불법행위 구성을 인정한다.

VI. 결론

- 판결의 편취는 기판력이라는 법적 안정성과 구체적 정의가 충돌하는 영역이다. 법원은 주소허위기재 등 절차적 하자의 경중에 따라 판결의 유효·무효를 구별하고, 추완항소나 재심과 같은 소송법적 구제수단을 우선적으로 활용하도록 하되, 이것이 불가능한 경우 실체법적 구제수단을 보완적으로 인정하여 피해자를 보호하고 있다. 이하에서는 이러한 부정한 재판의 효력을 배제하여 사법 정의를 실현하는 방향으로 제도가 운영되어야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제07절 소제기의 효과>

[기출][2023-1-1]상계의 항변과 중복소송의 관계 및 전소와 후소의 선후에 따른 대여금채권 소구의 적법성

《【문제1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, A소라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, 이 사건 대여금채권이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음1)

i 상계의 항변을 주장한 乙은 A소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 甲을 피고로 하는 대여금반환을 구하는 소(이하, B소라 한다)를 제기하였다. 乙이 제기한 B소는 적법한가?

ii 만일 甲이 제기한 A소 계속 전에 乙이 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소(C소라 한다)를 제기하였다면, 乙은 그 후 제기된 甲의 A소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장할 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음1> 상계의 항변과 중복소송의 관계 및 전소와 후소의 선후에 따른 대여금채권 소구의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 매매대금청구소송(A소)에서 乙이 자신의 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장한 상태에서 동일한 대여금채권으로 별소(B소)를 제기하거나, 반대로 대여금반환청구소송(C소)이 먼저 계속 중인 상태에서 후소인 A소에서 상계의 항변을 주장한 상황이다. 쟁점으로 <상계항변과 별소 제기가 민사소송법상 중복소제기금지에 저촉되는지, 선행소송 계속 중 후소에서 동일 채권을 자동채권으로 한 상계항변이 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 B소의 적법성 및 C소 계속 중 A소에서 상계항변의 허용 여부를 답한다.

II. 상계의 항변과 중복소송에 관한 법리

1. 중복소송의 금지 [민사소송법 제259조]

(1) 의의 및 요건

- 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다. 이는 판결의 모순·저촉을 방지하고 피고의 이중 응소 부담 및 법원의 소송경제적 낭비를 막기 위함이다. 중복소송이 성립하기 위해서는 당사자의 동일성, 소송물의 동일성, 전소의 계속이라는 요건을 충족하여야 한다.

(2) 소송물 동일성의 판단

- 소송물은 청구취지와 청구원인에 의해 확정되는 소송의 대상을 의미한다. 소송물이 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라, 전소와 후소의 청구가 서로 반대관계에 있거나 모순·저촉되는 관계에 있는 경우에도 소송물의 동일성이 인정된다.

2. 상계의 항변 주장 후 별소 제기 (물음1- i 관련 법리)

(1) 학설의 대립

① 중복소송설 (긍정설)

- 상계의 항변이 판단되는 경우 민사소송법 제216조 제2항에 따라 기판력이 발생하므로, 별도의 소를 제기하는 것은 중복소송 금지에 위배되어 부적법하다고 보는 견해이다.

② 별소허용설 (부정설)

- 상계의 항변은 소송물이 아닌 방어방법에 불과하므로 전소의 계속 중에 동일한 채권으로 별소를 제기하더라도 소송물의 동일성이 없어 중복소송에 해당하지 않는다고 보는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 상계의 항변은 법원의 판단을 요하는 방어방법에 지나지 않아 소송물 자체가 될 수 없으므로, 전소에서 상계의 항변을 제출하였다 하더라도 그 후 동일한 대여금채권으로 제기한 후소(별소)는 중복소송에 해당하지 않아 적법하다고 판시하였다.

3. 별소 제기 후 상계의 항변 주장 (물음1- ii 관련 법리)

(1) 학설의 대립

① 상계항변 허용설

- 소의 제기과 상계의 항변은 성격이 다르며 당사자의 방어권을 보장하기 위해 선행 소송이 있더라도 후행 소송에서의 상계의 항변은 허용되어야 한다는 견해이다.

② 상계항변 불허설

- 전소에서 이미 소송물로 삼은 채권을 후소에서 다시 상계의 항변으로 삼는 것은 사실상 동일한 채권에 대하여 이중의 사법적 판단을 구하는 것이며, 모순·저촉의 위험을 초래하므로 허용되지 않는다는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 이미 대여금반환 청구의 전소(C소)를 제기한 자가 후소(A소)에서 동일한 채권을 자동채권으로 삼아 상계의 항변을 주장하는 것은, 전소와 후소에서 이중으로 판단이 내려짐으로써 판결의 모순·저촉을 초래할 우려가 있고 판결의 기판력 범위(제216조 제2항)와 저촉될 수 있으므로 허용되지 않는다고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 물음1- i의 적용

- 사안에서 전소인 A소의 소송물은 甲의 매매대금채권이고, 乙의 대여금채권은 상계의 항변이라는 단순한 방어방법으로 제출되었다. 따라서 乙이 동일한 대여금채권을 소송물로 하여 제기한 후소인 B소는 전소인 A소와 소송물이 동일하지 않다. 대법원 판례의 태도에 따를 때 상계의 항변은 중복소송 금지 조항의 적용을 받지 않으므로, 乙이 제기한 B소는 적법하다.

2. 물음1- ii의 적용

- 乙은 이 사건 대여금채권의 지급을 구하는 전소인 C소를 제기하여 소송계속을 발생시켰다. 이 상황에서 乙이 후소인 A소에서 동일한 대여금채권을 자동채권으로 삼아 상계의 항변을 제기하는 것은 이미 소송물로 법원에 계속되어 있는 대여금채권에 대하여 이중으로 법원의 판단을 구하는 것이다. 이는 중복소송금지 원칙의 취지(유추적용) 및 기판력의 모순·저촉 방지 원칙에 위배되므로 乙은 상계의 항변을 제기할 수 없으며, 법원은 이를 배척하여야 한다.

IV. 결론

1. 물음1- i 의 결론

- 乙이 A소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 제기한 B소는 소송물의 동일성이 없어 중복소송에 해당하지 않으므로 전적으로 적법하다.

2. 물음1- ii 의 결론

- 乙이 이미 C소를 제기한 후 제기된 A소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하는 것은 판결의 모순·저촉을 유발하는 무효한 주장이므로 이를 주장할 수 없다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2023-1-2]상계의 항변이 판단된 판결이 확정된 후 자동채권 소구의 적법성 및 기판력의 범위

《【문제1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, A소라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, 이 사건 대여금채권이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음2) 甲이 제기한 A소에서 乙이 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였고, 법원은 甲의 채권과 乙의 채권이 모두 인정된다고 판단하여 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이 판결이 확정된 후 乙은 甲을 피고로 상계의 항변으로 주장한 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소를 제기할 수 있는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 상계의 항변이 판단된 판결이 확정된 후 자동채권 소구의 적법성 및 기판력의 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 매매대금청구소송에서 乙은 자신의 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계항변을 하였고 법원이 양 채권을 모두 인정하여 청구기각판결이 확정된 후 乙이 다시 그 대여금채권에 기한 반환청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <상계항변에 관한 판단에 인정되는 기판력의 범위와 상계의 자동채권에 대한 판단이 후소에 미치는 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상계항변에 관한 판단의 기판력과 이를 전제로 한 乙의 대여금반환청구소송의 적법 여부를 설명한다.

II. 상계의 항변에 대한 기판력의 범위

1. 상계항변과 기판력의 범위 [민사소송법 제216조]

(1) 기판력의 원칙

- 기판력은 주문에 나타난 소송물에 한하여 발생하며 판결 이유 중의 판단에는 미치지 않는 것이 원칙이다.

(2) 상계항변의 예외

- 민사소송법 제216조 제2항에 의하면 상계의 주장인 자동채권의 존부에 대한 판단은 상계로 대항한 액수에 한하여 기판력을 인정한다. 이는 자동채권의 이중 행사를 방지하기 위한 예외적 규정이다.

2. 기판력의 범위와 후행 소송에 미치는 영향

(1) 기판력이 발생하는 수액적 한계

- 상계항변에 대하여 기판력이 발생하는 범위는 수동채권과 대등액에서 소멸한 범위로 제한된다. 수동채권을 초과하여 상계로 대항하지 않은 자동채권 잔액 부분은 전소에서 심리되지 않았으므로 기판력이 발생하지 않는다.

(2) 후소 제기 시 법원의 판결 양태

- 기판력이 발생하는 소멸 부분에 대하여 다시 소를 제기하는 경우 후소 법원은 전소 판결의 구속력에 의하여 청구기각 판결을 내려야 한다. 반면 기판력이 미치지 않는 초과 잔존 부분에 대해서는 후소 제기가 적법하게 허용되며 법원은 실제 심리를 거쳐 인용 판결을 내릴 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 이 사건 대여금채권에 미치는 기판력의 범위

(1) 상계로 대항한 액수의 확정

- 전소인 A소의 수동채권은 甲의 매매대금채권인 5,000만 원이다. 乙이 자동채권으로 내세운 대여금채권 6,000만 원 중 실제로 상계적상에 이르러 대항한 액수는 수동채권액인 5,000만 원으로 제한된다.

(2) 기판력이 인정되는 범위의 확정

- 따라서 민사소송법 제216조 제2항에 의하여 전소 판결로 소멸의 기판력이 발생하는 범위는 대등액인 5,000만 원 부분에 한정된다. 나머지 1,000만 원 부분은 상계로 대항하지 않은 잔존 채권이므로 기판력이 미치지 않는다.

2. 乙이 제기한 후소의 적법성 및 판결의 형태

(1) 기판력이 미치는 5,000만 원 청구 부분

- 乙이 후소로 이 사건 대여금채권 전액의 지급을 청구하는 경우 기판력이 미치는 5,000만 원 부분은 전소의 구속력에 의하여 법원으로부터 청구기각 판결을 받게 된다.

(2) 기판력이 미치지 않는 1,000만 원 청구 부분

- 기판력이 미치지 않는 나머지 1,000만 원 청구 부분은 전소 판결에 저촉되지 않으므로 乙의 후소 청구가 전적으로 적법하다. 법원은 이에 대하여 실제 심리를 진행하여 청구를 인용하여야 한다.

IV. 결론

- 乙이 후소로 청구한 대여금채권 중 전소에서 상계 완결로 소멸한 5,000만 원 부분은 기판력의 구속력에 따라 청구기각 판결을 받게 되므로 이 부분은 소구할 수 없다. 乙이 상계로 소멸하지 않고 남은 잔존 대여금채권인 1,000만 원 부분에 대하여 소를 제기하는 것은 전소 기판력에 반하지 않아 전적으로 가능하며 법원은 이를 인용하여야 한다.

《【문제2】 장래의 이행을 청구하는 소에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 장래의 이행을 청구하는 소의 법리, 구체적 양태

I. 문제의 제기

- 민사소송법상 장래의 이행을 청구하는 소는 청구권의 발생 또는 이행기가 소송의 변론종결 후에 도래하는 이행청구권을 소송물로 삼는 소송 형태를 의미한다. 이는 이행기가 오기 전에 채권자의 실질적인 이익을 위하여 미리 판결을 받아둠으로써 장래의 채무불이행에 대비하는 매우 유용한 예방적 권리구제 수단이다. 다만, 피고에게 무용한 소송 부담을 주지 않고 남소를 방지하기 위하여 일정한 법적 요건하에서만 예외적으로 허용되고 있다. 이하에서는 장래의 이행의 소의 법리와 구체적 양태에 대하여 설명한다.

II. 장래의 이행의 소의 법리

1. 의의 및 제도적 취지

(1) 의의

- 장래의 이행의 소는 변론종결 당시를 기준으로 아직 이행기가 도래하지 않았거나, 구체적인 채권은 장래에 순차적으로 발생하는 이행청구권을 대상으로 법원의 이행판결을 청구하는 소송이다.

(2) 제도적 취지

- 이행기가 도래하였을 때 즉시 강제집행을 실행할 수 있도록 미리 법적 집행력을 확보해 둠으로써, 채권자에게는 소송경제적 편의와 신속한 권리구제를 제공하고 사법제도 전반의 효율성을 도모하고자 함에 있다.

2. 장래의 이행의 소의 적법요건

(1) 청구권의 선행적 존재

- 장래 이행할 채무의 기초가 되는 계약이나 법률관계가 변론종결 당시에 이미 성립되어 존재하고 있어야 한다. 또한 장래 청구권 발생이 단순히 막연한 기대나 가능성에 그치지 않고 사실상 확실하게 예견되는 수준의 인과관계가 확보되어야 적법하다.

(2) 미리 청구할 필요성

- 이행기가 도래하더라도 채무자가 임의이행을 하지 않을 것으로 객관적으로 우려되는 사정이 인정되어야 한다. 판례는 채무자가 채무의 존부 자체를 다투고 있거나, 조건 성취를 완강히 부정하는 등 자발적인 급부 이행을 기대하기 어려운 경우에 이를 인정한다.

3. 미리 청구할 필요성의 구체적 판단 기준

(1) 채무자의 다투는 태도

- 피고가 원고의 청구권에 대하여 그 성립 자체를 전면 부인하거나 채무의 범위 등을 적극적으로 다투고 있는 경우라면, 장래 이행기가 도래하더라도 피고가 의무를 성실히 이행할 것을 기대하기 어려우므로 소의 이익이 긍정된다.

(2) 급부의 계속성과 이행 지체의 우려

- 부당이득반환이나 임료 상당의 손해배상 등 장래의 정기적 급부의 경우, 현재 이미 점유를 침탈하는 상태에서 피고가 불법 점유 사실을 완강히 부인하고 있다면 장래의 급부 부분에 대해서도 미리 청구할 필요성이 인정된다.

III. 구체적 양태

1. 기한부 및 조건부 채무에의 적용

(1) 기한부 채무의 적용

- 피고가 변제 약정에 따른 할부금의 지급 의무 자체를 완강하게 다투고 있는 상황이라면, 아직 이행기가 도래하지 않은 장래 할부금 채무에 대하여 소의 이익이 인정된다. 법원은 이를 인용하여 기한 도래 시 이행할 것을 명하여야 한다.

(2) 조건부 채무의 적용

- 정치조건부 채권의 경우 피고가 조건의 성취를 완강하게 저지하거나 권리의 존재를 다투는 상황이라면, 조건부 이행판결을 구할 소의 이익이 인정된다. 법원은 조건 성취를 기한으로 하는 이행 판결을 내려 채권자의 지위를 적법하게 보호할 수 있다.

2. 장래 기간 동안의 계속적 급부 청구에의 적용

(1) 토지 인도 및 장래 임료 상당의 배상

- 무단 점유자를 상대로 토지의 인도를 청구하면서 동시에 인도 완료일까지의 장래 임료 상당의 손해배상을 청구하는 것은 소송법상 대표적인 예이다. 이는 청구권의 선행적 기초가 존재하고 장래의 이행 거절이 확실히 예견되므로 전적으로 적법하다.

(2) 정기금 판결에 대한 변경의 소

- 정기금 급부를 명한 판결이 확정된 후, 액수 산정의 기초가 된 사정이 현저히 변경되어 부적당하게 된 경우 제기하는 변경의 소는 사정 변경에 따른 불이익을 방지하기 위한 장래 이행의 소의 성질을 가지며 전적으로 적법하게 인정된다.

IV. 결론

- 장래의 이행을 청구하는 소는 변론종결 이후에 발생할 채권의 신속한 집행력 확보를 보장하여 원고의 예방적 권리구제를 충실하게 실현해 주는 핵심적인 소송 제도이다. 다만, 법원은 피고에게 발생할 불필요한 소송상의 지위 불안을 억제하기 위하여 청구권의 기초관계가 실재하고 피고의 이행 거절이 확실한 경우로 그 범위를 엄격히 제한하고 있다. 결론적으로 장래의 이행의 소는 소송경제와 분쟁의 일회적 해결이라는 사법적 요청을 조화롭게 절충하는 장치이며, 법원은 이행 거절 의사를 엄격하게 심사하여 남소를 강력하게 억제하는 동시에 정당한 권리자의 장래 급부 확보라는 법적 편익을 실체적으로 충실하게 보장하고 있다.

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제02절 항소의 제기>

[기출][2023-3]부대항소의 의의, 요건, 절차와 방식, 효력, 특수한 경우의 부대항소

《【문제3】 부대항소에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 부대항소의 의의, 요건, 절차와 방식, 효력, 특수한 경우의 부대항소

I. 문제의 제기

- 부대항소란 항소를 당한 피항소인이 항소인의 항소에 의하여 개시된 항소심 절차에 편승하여 자기에게 유리하도록 제1심 판결을 변경할 것을 구하는 신청을 말한다.(민사소송법 제403조) 이는 항소권이 소멸하여 독립하여 항소를 할 수 없는 상태라 하더라도, 상대방이 항소를 제기해 온 이상 공평의 원칙상 피항소인에게도 불복의 기회를 부여하기 위한 제도이다. 또한 불이익변경금지의 원칙을 깨뜨리고 항소심의 심판 범위를 피항소인이 불복하는 범위까지 확장시키는 기능을 한다. 이하에서는 부대항소의 적법 요건과 구체적인 행사 방법 및 그 효력에 대해 설명한다.

II. 부대항소의 요건

1. 주된 항소가 적법하게 계속 중일 것

- 부대항소는 주된 항소에 의존하는 종된 권리이므로, 주된 항소가 적법하게 제기되어 항소심에 계속 중이어야 한다. 만약 주된 항소가 부적법하여 각하된다면 부대항소 역시 그 효력을 잃게 된다.

2. 피항소인이 항소인을 상대로 제기할 것

- 부대항소는 피항소인이 항소인을 상대로 제기하여야 한다. 통상적인 항소심 절차의 당사자 사이에서 이루어지며, 보조참가인이 피참가인을 위하여 부대항소를 하는 것도 허용된다.

3. 항소심의 변론종결 전까지 제기할 것

- 부대항소는 항소심의 변론종결 전까지 제기하여야 한다. 독립된 항소와 달리 항소기간의 제한을 받지 않으므로, 자신의 항소기간이 도과하거나 항소권을 포기한 후라도 항소심 변론종결 전이라면 언제든지 제기할 수 있다.

III. 부대항소의 절차와 방식

1. 부대항소장의 제출

- 부대항소는 항소에 관한 규정에 따라 부대항소장을 항소심 법원에 제출함으로써 한다. 부대항소장에는 부대항소의 취지와 이유를 적어야 하며, 독립된 항소장과 마찬가지로 인지를 첨부하여야 한다.

2. 불복 범위의 기재

- 부대항소인은 제1심 판결 중 자신에게 불리하게 판결된 부분에 대하여 어느 범위까지 변경을 구하는지 명확히 기재하여야 한다. 이에 따라 항소심의 심판 범위가 확장된다.

IV. 부대항소의 효력

1. 불이익변경금지 원칙의 배제

- 원칙적으로 항소심은 항소인의 불복 범위 내에서만 심판하며 항소인에게 불리하게 판결을 변경할 수 없으나, 부대항소가 제기되면 법원은 피항소인이 불복한 범위까지 심판할 수 있게 된다. 결과적으로 항소인에게 제1심보다 불리한 판결이 내려질 수 있다.

2. 주된 항소와의 종속성

- 부대항소는 주된 항소가 취하되거나 부적법하여 각하된 때에는 그 효력을 잃는 것이 원칙이다.(민사소송법 제404조 본문)

(1) 예외 : 독립항소 요건을 갖춘 경우

- 다만, 부대항소가 항소기간 내에 제기되어 독립된 항소로서의 요건을 갖추고 있는 경우에는 주된 항소가 취하되더라도 독립된 항소로 보아 그 효력이 유지된다.(민사소송법 제404조 단서)

(2) 상계항변과 부대항소

- 최근 판례는 상계항변이 인용되어 승소한 피고가 원고의 항소에 대하여 부대항소를 제기하지 않더라도, 항소심에서 다시 상계항변을 유지하거나 반대채권의 존부를 다투는 것은 부대항소 없이도 가능하다고 보아 피항소인의 방어권을 존중하고 있다.

V. 특수한 형태의 부대항소

1. 가집행선고만을 구하는 부대항소

- 제1심에서 가집행선고가 불지 않은 경우 피항소인은 항소심에서 가집행선고만을 구하기 위한 부대항소를 제기할 수 있다.

2. 예비적 부대항소

- 주된 항소가 인용될 것을 대비하여 예비적으로 제1심 판결의 변경을 구하는 형태의 부대항소도 가능하다.

VI. 결론

- 부대항소는 항소심 절차에서 당사자 간의 실질적인 형평을 기하고 분쟁을 일거에 해결할 수 있게 하는 유용한 제도이다. 특히 항소권이 소멸한 피항소인에게 다시금 불복의 기회를 제공함으로써 처분권주의와 공평의 원칙을 조화시킨다. 법원은 부대항소의 종속성과 심판 범위 확장 효과를 정확히 파악하여, 주된 항소의 운명에 따른 부대항소의 처리에 유의하여야 하며 당사자의 방어권이 침해되지 않도록 운영하여야 한다.

《【문제1】 甲은 乙에 대해 1억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 이 사건 소송이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50점)

(물음1) 원고 甲은 제1심 소송계속 중 피고 乙의 원고 甲에 대한 1억 원의 대여금 채무 전액에 대해서 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하였다. 이러한 예비적 피고의 추가가 적법한지 설명하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 원고가 제1심 소송계속 중 연대보증인을 예비적 피고로 추가한 행위의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기한 후 제1심 소송계속 중 해당 채무를 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하려는 상황이다. 쟁점으로 <소송 계속 중 제3자를 예비적 피고로 추가하는 것이 허용되는지>와 <그 요건 및 소송법상 취급>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 예비적 피고 추가의 법적 성질과 허용 여부 및 그 적법요건을 설명한다.

II. 주관적 예비적 · 선택적 공동소송의 의의와 요건

1. 의의

- 공동소송인들 사이에 법률상 양립할 수 없는 관계가 있어, 주위적 피고에 대한 청구가 인용되지 않을 것을 대비하여 예비적 피고에 대한 청구를 병합하거나, 누구에 대한 청구인지 선택적으로 판단을 구하는 형태를 말한다.

2. 성립 요건

- 민사소송법 제70조 제1항에 따르면, 공동소송인들 가운데 일부의 청구가 다른 공동소송인의 청구와 법률상 양립할 수 없어야 한다.

(1) 법률상 양립 불가능성

- 법률상 양립할 수 없다는 것은 동일한 사실관계에 바탕을 둔 권리관계에서 어느 한쪽의 권리가 인정되면 다른 쪽의 권리가 부정되는 관계를 의미한다. 예를 들어 갑이 소유자인지 을이 소유자인지와 같은 관계이다.

(2) 상호 관련성

- 각 피고에 대한 청구는 동일한 법률관계나 사실관계에 기초하여야 한다.

III. 소송계속 중 피고 추가(주관적 추가적 병합)의 허용 여부

1. 원칙적 불허

- 민사소송법은 소송계속 중 제3자를 새로운 피고로 추가하는 주관적 추가적 병합을 원칙적으로 허용하지 않는다. 이는 피고의 교체나 추가가 무분별하게 이루어질 경우 소송 절차가 지연되고 새로운 피고의 심급의 이익을 해칠 우려가 있기 때문이다.

2. 예외적 허용(민사소송법 제70조 제1항 단서)

- 과거에는 소송 제기 시에만 예비적 공동소송이 가능했으나, 2002년 민사소송법 개정을 통해 소송계속 중에도 부진정연대채무나 양립 불가능한 관계에 있는 피고를 추가할 수 있는 근거가 마련되었다. 다만, 이는 제67조 내지 제69조의 규정을 준용하는 범위 내에서 엄격한 요건 하에 허용된다.

IV. 사안의 적용

1. 법률상 양립 가능성 검토

- 주채무자 乙에 대한 대여금 청구와 연대보증인 丙에 대한 보증채무 이행 청구는 법률상 양립 가능하다. 주채무가 인정된다고 하여 보증채무가 부정되는 것이 아니며, 오히려 보증채무는 주채무의 존재를 전제로 하는 부종성을 가진다. 따라서 乙과 丙에 대한 청구는 법률상 양립할 수 없는 관계가 아니다.

2. 피고 추가의 적법성 판단

- 사안의 경우 乙과 丙은 실질적으로 연대하여 채무를 부담하는 관계이거나 주채무-보증채무의 관계에 불과하므로, 민사소송법 제70조가 요구하는 양립 불가능 요건을 충족하지 못한다. 또한, 소송계속 중 예비적 피고를 추가하기 위해서는 제70조 제1항의 요건을 갖추어야 하는데, 본 사안은 이에 해당하지 않는다.

V. 결론

- 원고 甲이 丙을 예비적 피고로 추가하는 것은 민사소송법 제70조 제1항 소정의 예비적 공동소송 요건(법률상 양립 불가능성)을 갖추지 못하였으므로 부적법하다. 따라서 법원은 甲의 피고 추가 신청을 각하하거나 허가하지 않아야 한다.

《【문제1】 甲은 乙에 대해 1억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 이 사건 소송이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50점)

(물음2) 이 사건 소송에서 피고 乙은 1억 원 전액을 원고 甲에게 변제하였다는 항변을 하였다. 제1심 법원은 피고 乙이 3,000만 원만 변제한 사실을 인정하여 원고 甲의 청구금액 1억 원 중 7,000만 원만 인용하면서 나머지 3,000만 원의 청구에 대해서는 기각하는 판결(이하 제1심 판결이라 한다)을 하였다. 이러한 제1심 판결에 대하여 원고 甲만이 기각된 3,000만 원의 청구에 대해서도 인용해달라는 취지로 항소를 제기하였다. 항소심에서 피고 乙은 새롭게 1억 원의 상계의 항변을 주장하였다. 항소심 법원은 피고 乙의 변제항변은 전부 이유 없지만, 피고 乙의 상계항변은 전부 인정된다는 이유로 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구 전부를 기각하는 판결을 하였다. 이러한 항소심 판결이 적법한지 설명하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 원고만이 항소한 경우 항소심 법원이 상계항변을 받아들여 청구 전부를 기각한 판결의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제1심에서 일부 기각된 3,000만 원 부분에 대하여 항소한 후 항소심에서 乙이 새롭게 상계항변을 하였고, 항소심 법원이 이를 받아들여 甲의 청구 전부를 기각한 상황이다. 쟁점으로 <항소심에서 새로운 공격방어방법인 상계항변을 제출할 수 있는지>와 <항소심 법원이 제1심보다 불리한 판단을 할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항소심의 심판범위와 불이익변경금지 원칙에 따른 상계항변의 허용 여부 및 판결의 적법성을 검토한다.

II. 상소의 원칙

1. 상소의 불가분 원칙과 이심의 범위

(1) 상소의 불가분 원칙

- 상소의 제기는 판결의 확정을 차단하고 사건 전체를 상소심으로 이심시키는 효력이 있다. 이를 상소의 불가분 원칙이라 한다. 따라서 판결의 일부에 대해서만 상소를 하더라도 원칙적으로 당해 판결의 전체가 상소심으로 이심된다.

(2) 사안의 이심 범위

- 원고 甲은 기각된 3,000만 원 부분에 대해서만 항소를 제기하였으나, 상소의 불가분 원칙에 따라 제1심 판결의 전체인 1억 원 청구 부분이 항소심으로 이심된다. 다만, 이심된 부분 중 항소인이 불복하지 않은 부분은 항소심의 심판 대상에서는 제외되는 것이 원칙이다.

2. 불이익변경금지의 원칙

(1) 의의

- 항소심 법원은 항소인의 불복 신청 범위 내에서만 제1심 판결의 당부를 심판할 수 있으며, 항소인에게 제1심 판결보다 불리한 판결을 할 수 없다는 원칙이다.(민사소송법 제415조) 이는 당사자의 처분권주의가 상소심 절차에서도 관철된 결과이다.

(2) 적용 요건

- 상대방이 항소하거나 부대항소를 제기하지 않은 경우에 한하여 적용된다. 본 사안에서 피고 乙은 항소나 부대항소를 제기하지 않았으므로, 원고 甲만이 항소한 이 사건에서 불이익변경금지 원칙이 적용된다.

III. 항소심의 심판 범위와 상계항변

1. 심판 대상의 한정

- 원고 甲은 제1심에서 기각된 3,000만 원의 인용을 구하며 항소하였다. 따라서 항소심의 심판 대상은 원칙적으로 원고가 불복한 3,000만 원 부분에 한정된다. 제1심에서 원고가 승소한 7,000만 원 부분은 피고가 항소하지 않았으므로 원고에게 유리하게 확정될 대기 상태에 있는 부분이다.

2. 상계항변의 처리와 불이익변경 여부

- 항소심에서 피고가 상계항변을 제출한 경우, 법원은 이를 심리할 수 있다. 그러나 그 결과가 원고에게 제1심보다 불리한 결과를 초래해서는 안 된다.

(1) 항소 부분(3,000만 원)에 대한 판단

- 항소심 법원은 피고의 변제항변이 이유 없다고 판단했으므로, 일단 원고의 항소는 이유 있는 것이 된다. 그러나 피고의 상계항변이 1억 원 전액에 대해 인정되므로, 항소 대상인 3,000만 원 청구는 상계에 의해 소멸되어 기각하는 것이 타당하다. 이는 제1심 판결(기각)과 결과가 동일하므로 불이익변경에 해당하지 않는다.

(2) 제1심 인용 부분(7,000만 원)에 대한 판단

- 문제는 제1심에서 이미 원고가 승소한 7,000만 원 부분이다. 피고가 항소하지 않았으므로 항소심 법원은 이 부분을 원고에게 불리하게 변경할 수 없다. 그럼에도 불구하고 항소심 법원이 상계항변을 이유로 청구 전부(1억 원 전체)를 기각한 것은, 원고가 항소하지 않았더라면 얻었을 7,000만 원의 승소 확정 지위를 박탈한 것이 되어 불이익변경금지 원칙에 정면으로 위배된다.

IV. 사안의 적용

1. 항소심 판결의 내용 분석

- 항소심 법원은 원고의 청구 전부를 기각하였다. 이는 제1심에서 인용되었던 7,000만 원 부분까지 취소하고 원고 패소 판결을 내린 것과 같다.

2. 위법성 판단

- 피고의 부대항소가 없는 상황에서 원고의 항소만으로 제1심 승소 부분까지 반복하여 원고에게 더 불리한 판결을 내리는 것은 민사소송법 제415조에 위반된다. 항소심 법원은 원고의 항소 부분(3,000만 원)에 대해서만 상계항변을 적용하여 항소를 기각(제1심 결과 유지)했어야 하며, 제1심 인용 부분인 7,000만 원은 그대로 유지했어야 한다. 이하에서는 이와 같은 법리를 바탕으로 결론을 도출한다.

V. 결론

- 항소심 법원이 피고의 상계항변을 근거로 제1심에서 원고가 승소한 부분까지 포함하여 청구 전부를 기각한 판결은 불이익변경금지의 원칙을 위반한 것이므로 위법하다. 항소심 법원은 원고의 항소를 기각함으로써 제1심 판결의 결과를 유지하는 선에서 판결했어야 한다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제01절 소의 취하와 재소금지>

[기출][2024-2]당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우

《【문제2】 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 경우에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우

I. 문제의 제기

- 기일이란 법원, 당사자 또는 제3자가 소송절차를 진행하기 위하여 특정한 장소에 모여야 하는 시간적 구분을 의미한다. 변론기일의 지정은 원칙적으로 재판장의 직권사항에 해당하나(민사소송법 제165조 제1항), 예외적으로 당사자가 기일지정을 신청할 수 있는 권리가 인정되는 경우가 있다. 이는 절차의 정지 상태를 해소하거나, 소송 종료의 효력을 다투는 등 당사자의 절차적 이익을 보호하기 위함이다. 이하에서는 당사자가 변론기일 지정을 신청할 수 있는 주요 사유인 소송절차의 중단·중지 해소, 소송종료선언 신청, 기일지정신청권의 일반적 행사에 대하여 설명한다.

II. 소송절차의 중단·중지의 해소

1. 소송절차 중단 사유의 소멸과 수계신청

- 당사자의 사망, 법인의 합병, 당사자의 자격 상실 등으로 인하여 소송절차가 중단된 경우, 새로운 당사자(상속인, 합병 후의 법인 등)가 소송을 수계하거나 상대방이 수계신청을 할 수 있다. 수계신청이 있으면 법원은 기일을 지정하여 소송절차를 속행해야 하므로, 이는 실질적으로 기일지정신청의 성격을 갖는다.

2. 소송절차 중지의 해소

- 법원의 결정에 의해 소송절차가 중지된 경우, 중지 사유가 소멸되었음에도 법원이 기일을 지정하지 않는다면 당사자는 기일지정신청을 통해 절차의 속행을 요구할 수 있다.

III. 소송종료선언을 위한 기일지정신청

1. 의의

- 소취하, 재판상 화해, 청구의 포기·인낙 등 소송이 종료된 것으로 처리되었으나, 당사자가 그 종료 효력을 다투는 경우에 행하는 신청이다. 소송이 유효하게 종료되었는지 여부를 확정하기 위해 변론을 열어달라는 취지이다.

2. 주요 신청 사유

(1) 소취하의 무효·취소 주장

- 원고가 소를 취하하였으나 그것이 제3자의 형사상 처벌받을 행위로 강요된 것이거나, 착오에 의한 것이라는 이유로 취하의 효력을 다투고자 할 때 당사자는 기일지정신청을 한다.

(2) 화해·포기·인낙의 무효 주장

- 재판상 화해나 청구의 포기·인낙이 조서에 기재됨으로써 확정판결과 동일한 효력이 발생하였으나, 그 절차에 중대한 흠이 있거나 무효 사유가 있다고 주장하는 경우 당사자는 기일지정신청을 통해 법원의 판단을 구할 수 있다.

(3) 소취하 간주에 대한 이의

- 당사자 쌍방이 2회 불출석하고 1개월 이내에 기일지정신청을 하지 않아 소가 취하된 것으로 간주되는 경우(민사소송법 제268조), 당사자가 불출석에 정당한 사유가 있었음을 주장하며 기일지정을 신청할 수 있다.

IV. 무변론판결 취소와 기일지정

1. 무변론판결 예정 통지 후 답변서 제출

- 피고가 기한 내에 답변서를 제출하지 않아 법원이 무변론판결을 선고하려 할 때, 판결 선고 전까지 피고가 답변서를 제출하며 변론을 요구하는 경우 법원은 변론기일을 지정해야 한다.

2. 판결선고기일 지정의 변경 신청

- 재판장이 직권으로 지정한 판결선고기일 이전에 당사자가 새로운 증거를 발견하거나 보충할 변론이 있어 변론재개신청과 함께 기일지정을 신청하는 경우, 법원은 필요하다고 판단하면 변론기일을 다시 지정할 수 있다.

V. 기일지정신청에 대한 법원의 처리

1. 심리 및 결정

- 기일지정신청이 있으면 법원은 소송절차가 유효하게 중단·종료되었는지를 심리한다. 만약 소송이 이미 유효하게 종료된 것으로 판단되면 소송종료선언 판결을 내리고, 소송이 종료되지 않았다고 판단되면 변론기일을 지정하여 본안 심리를 계속한다.

2. 신청의 각하

- 기일지정신청이 명백히 부적법하거나 이유 없는 경우에는 결정으로 신청을 각하할 수 있다. 그러나 소송 종료 효력을 다투는 기일지정신청의 경우 원칙적으로 판결로써 응답하는 것이 판례의 태도이다.

VI. 결론

- 변론기일지정신청권은 법원의 직권에 의한 기일 운영 원칙에 대한 중요한 예외로서, 당사자의 재판받을 권리를 실질적으로 보장하는 수단이다. 특히 소송종료의 효력을 다투는 국면에서 기일지정신청은 소송계속을 부활시키고 법원의 공적 판단을 유도하는 필수적인 절차적 장치로 기능한다. 법원은 당사자의 신청 취지를 신중히 검토하여 부당하게 재판 절차가 지연되거나 조기에 종결되어 당사자의 권익이 침해되지 않도록 운영해야 한다.

《【문제3】 보충송달에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 보충송달의 의의, 요건, 제한과 예외, 효력 발생, 불능 시 조치

I. 문제의 제기

- 송달이란 재판 절차의 당사자나 그 밖의 이해관계인에게 소송서류의 내용을 알 수 있는 기회를 주기 위해 법정의 절차에 따라 서류를 교부하거나 그 내용을 고지하는 행위이다. 민사소송법은 송달받을 사람에게 직접 서류를 건네주는 교부송달을 원칙으로 하되, 송달받을 사람을 만나지 못한 경우를 대비하여 보충송달 제도를 두고 있다.(민사소송법 제186조 제1항) 이는 송달의 확실성과 절차의 신속성을 조화시키기 위한 장치이다. 이하에서는 보충송달의 성립 요건과 구체적 적용 범위, 그리고 그 효력에 관하여 설명한다.

II. 보충송달의 요건

1. 근무지 외의 송달장소에서 행하는 경우

(1) 수령인의 부재

- 송달기관이 주소·거소·영업소 또는 사무소 등 근무지 외의 송달장소에 갔으나, 송달받을 사람(본인)을 만나지 못하여야 한다.

(2) 수령대행인의 존재

- 그곳에서 사무를 맡아보는 피용자(직원), 동거인 또는 가족 등 본인을 대신하여 서류를 받을 수 있는 사람이 있어야 한다.

(3) 사리를 분별할 지능

- 수령대행인은 송달의 취지를 이해하고 수령한 서류를 본인에게 전달할 수 있는 최소한의 사리 분별 지능을 갖추어야 한다. 반드시 성년자일 필요는 없으나, 유아나 중증 치매 환자 등은 수령대행인이 될 수 없다.

2. 근무지에서 행하는 경우

(1) 본인의 부재 또는 수령 거부

- 근무지에서 송달받을 사람을 만나지 못하거나, 본인이 서류 수령을 거부하는 경우에 보충송달이 가능하다.

(2) 수령대행인의 범위

- 근무지의 경우에는 그곳에서 사무를 맡아보는 피용자나 조항에 규정된 동료 근무자가 수령대행인이 된다. 주소지 송달과 달리 가족이나 동거인은 근무지의 수령대행인에 해당하지 않는다.

III. 보충송달의 제한과 예외

1. 이해상반인에 대한 송달

- 동일한 소송에서 송달받을 사람과 이해관계가 대립하는 사람(예 : 공동피고인 배우자)에게는 보충송달을 할 수 없다. 이는 수령대행인이 서류를 본인에게 전달하지 않을 위험이 크기 때문이다.

2. 본인이 실제 거주하지 않는 장소에서의 송달

- 주민등록지라 하더라도 본인이 실제로 거주하지 않는 곳에서 가족이 서류를 받은 경우에는 보충송달의 효력이 발생하지 않는다. 보충송달은 본인이 그곳에 거주하거나 영업을 하고 있다는 사실을 전제로 하기 때문이다.

IV. 보충송달의 효력 발생

1. 효력 발생 시기

- 보충송달은 수령대행인에게 서류가 교부된 때에 즉시 효력이 발생한다. 따라서 수령대행인이 본인에게 실제로 서류를 전달했는지 여부나 본인이 내용을 언제 알게 되었는지는 효력 발생에 영향을 미치지 않는다.

2. 도달주의의 예외적 적용

- 보충송달은 법률이 정한 수령대행인에게 서류가 전달됨으로써 본인에게 도달한 것과 동일한 법률 효과를 부여하는 것이다. 만약 수령대행인이 서류를 받은 후 즉시 파기하거나 전달하지 않았더라도, 송달 자체는 적법한 것으로 간주된다.

V. 보충송달 불능 시의 조치

1. 유치송달

- 수령대행인이 정당한 사유 없이 서류 수령을 거부하는 경우에는 서류를 송달장소에 놓아두는 유치송달을 할 수 있다.(민사소송법 제186조 제3항)

2. 우편송달 및 공시송달

- 보충송달과 유치송달이 모두 불가능한 경우에는 등기우편으로 발송하는 우편송달(발송송달)이나, 최후의 수단으로서 공시송달 절차를 밟게 된다.

VI. 결론

- 보충송달은 교부송달의 원칙을 보완하여 소송 절차의 원활한 진행을 돕는 중요한 제도이다. 그러나 본인의 수령 의사와 무관하게 효력이 발생한다는 점에서 당사자의 방어권을 침해할 소지가 있으므로, 수령대행인의 자격이나 실제 거주 여부 등 그 요건을 엄격하게 해석하여야 한다. 특히 이해관계가 대립하는 자에 대한 송달 제한 등을 철저히 준수함으로써 절차적 정의를 확보하는 것이 타당하다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제01절 증거의 총설>

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제06절 증명책임>

[기출][2025-1-1]대여금 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

《[문제1] 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000만 원을 이자 없이 1년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15.이 되어서 乙은 2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 고려청자라 함)를 甲에게 양도한다.라는 각서(이하 각서라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50점)

(물음1) 증거방법으로 제출된 내용증명에는 모두 甲이 乙에게 대여금 8,000만 원의 상환을 촉구하는 내용이 들어 있다. 乙은 사실이 아니라고 하면서 실제로 차용한 돈은 5,000만 원뿐이라고 주장하였다. 그것도 도박장에서 빌린 것이라고 주장하며 상환의무가 없다고 하였다. 甲은 乙의 항변에 대해 어느 것도 인정하지 않았다. 법원이 차용증을 제출하라고 하였으나, 甲은 분실하였다고 진술하였고, 乙은 애초부터 작성한 바가 없다고 하였다. 乙은 대여금의 액수가 5,000만 원이라는 증거로 자신이 기명날인한 각서의 사본을 제출하였다. 이에 甲은 그 원본의 존재 자체를 부정하였다. 이밖에 더 제출된 증거 방법은 없다. 법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 대여금 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 상대로 8,000만 원의 대여금 반환청구를 하면서 내용증명만을 증거로 제출한 반면, 乙은 차용액은 5,000만 원에 불과하고 도박자금이어서 상환의무가 없다고 다투며 각서 사본을 제출하였으나 원본의 존재와 증거능력이 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <내용증명의 증명력과 각서 사본의 증거가치, 대여금 액수 및 도박자금 항변에 관한 증명책임과 증명 정도를 기초로 법원이 어떠한 사실인정을 하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 증거방법의 증명력과 증명책임의 분배를 전제로 법원이 어떠한 판결을 하여야 하는지를 논한다.

II. 대여금 청구 및 도박채무 항변과 서증의 법리

1. 대여금 청구의 입증책임과 재판상 자백

(1) 대여금 청구의 요건사실과 입증책임

- 대여금 청구 소송에서 원고는 대여금 청구권의 발생요건인 ① 소비대차계약의 체결, ② 목적물인 금원의 교부, ③ 변제기의 도래 사실을 주장·입증하여야 한다. 한편, 원고가 제출한 내용증명 우편은 대여금의 상환을 독촉하는 최고의 사실을 증명할 뿐이며, 소비대차계약의 체결이나 금원의 실제 교부 사실을 직접 증명하는 서증으로 인정되기 어렵다.

(2) 재판상 자백의 성립과 효력

- 재판상 자백은 소송계속 중 당사자가 변론이나 준비절차에서 행한 상대방의 주장과 일치하고 자신에게 법률상 불이익한 사실의 인정 진술이다. 재판상 자백이 성립하면 당사자는 이를 임의로 철회할 수 없고, 법원 역시 자백의 구속력을 받아 자백된 사실을 그대로 판결의 기초로 삼아야 하므로 그 사실에 대해서는 별도의 증명을 요하지 않는다.

2. 도박채무 항변과 서증 사본의 증거력

(1) 반사회적 법률행위 항변의 입증책임

- 민법 제103조에 의하여 도박자금으로 금전을 대여하는 행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효이다. 대여금 청구 소송에서 채무가 반사회질서 법률행위에 해당하여 무효라는 주장은 실체법상 일종의 권리소멸(무효) 항변에 해당하므로, 그 요건사실에 대한 입증책임은 무효를 주장하여 이익을 얻는 피고가 부담한다.

(2) 서증 사본의 증거력과 원본 불존재 다름

- 서증을 제출할 때는 원본을 제출하는 것이 원칙이다. 사본을 제출한 경우 상대방이 원본의 존재 자체를 부정하거나 진정성립을 다투면, 사본 제출자는 원본의 존재와 진정성립 또는 사본의 정확성을 증명하여야 한다. 이를 증명하지 못하는 한, 제출된 사본은 독자적인 증거력을 가질 수 없어 판결의 기초로 삼을 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 대여금 5,000만 원에 대한 판단

- 피고 乙은 실제로 차용한 돈이 5,000만 원이라고 진술하였는바, 이는 원고 甲의 8,000만 원 대여금 청구 주장 중 5,000만 원 범위 내에서 자신에게 불리한 사실을 인정한 것으로서 재판상 자백에 해당한다. 따라서 이 범위 내에서는 자백의 구속력에 의해 소비대차계약의 체결 및 금원 교부 사실이 증명 없이 인정된다. 한편, 乙은 이것이 도박채무이므로 무효라고 항변하였으나, 이에 대한 증거로 제출한 각서 사본은 甲이 원본의 존재를 부정함에도 乙이 원본의 실제 존재나 진정성립을 소명하지 못하였으므로 증거력이 없다. 결국 乙의 도박채무 무효 항변은 입증 부족으로 배척된다.

2. 대여금 나머지 3,000만 원에 대한 판단

- 원고 甲은 8,000만 원의 지급을 청구하나, 피고 乙은 5,000만 원을 초과하는 3,000만 원에 대해서는 대여 사실을 완전히 부인하고 있다. 甲은 대여금 청구의 입증책임자로서 3,000만 원의 교부 사실을 입증하여야 하나, 제출된 내용증명 3통은 단순 독촉 사실만 증명할 뿐 대여 사실을 직접 증명하지 못하며 차용증도 분실하여 더 이상 증거가 없다. 따라서 甲은 3,000만 원 부분에 대하여 입증책임을 다하지 못하였다.

IV. 결론

- 법원은 피고 乙의 재판상 자백으로 대여 사실이 인정되고 乙의 도박채무 항변이 배척된 5,000만 원 청구 부분에 대해서는 원고 甲의 청구를 인용하여야 한다. 반면, 甲이 대여 사실을 적법하게 입증하지 못한 나머지 3,000만 원 청구 부분에 대해서는 입증책임의 법리에 따라 청구를 기각하여야 한다. 결과적으로 법원은 '피고는 원고에게 금 5,000만 원을 지급하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.'라는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 한다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제01절 청구의 원시적 병합>

[기출][2025-1-2]대여금 및 예비적 청구 소송에서 사문서의 진정성립 추정 및 예비적 병합의 심판순위에 따른 판결의 타당성

《【문제1】 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000만 원을 이자 없이 1년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15.이 되어서 乙은 2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 고려청자라 함)를 甲에게 양도한다.라는 각서(이하 각서라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50점)

(물음2) 乙은 甲의 청구에 대하여 금전을 차용한 적이 없다고 하였다. 차용증이 없느냐는 재판장의 물음에 甲은 이사하던 중에 분실된 것 같다고 하면서 乙이 기명날인한 각서를 제출하였다. 이에 乙은 5,000만 원의 차용을 인정하였다. 다음 기일에 甲은 차용증을 찾았다며 증거로 제출하였고, 고려청자의 인도를 구하는 청구를 예비적으로 병합하였다. 乙은 뒤늦게 가져온 차용증은 위조일 수밖에 없다고 항변하였다. 재판장이 차용증에 있는 당사자들의 인영이 진정해 보인다고 하자, 乙은 자기의 기명날인이 맞긴 하지만 대여금은 여전히 5,000만 원이었다고 주장하였다. 이밖에 더 제출된 증거방법은 없었다. 마침내 법원은 乙은 甲에게 고려청자를 인도하라는 판결을 내렸다. 이 판결에 대하여 평가하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 대여금 및 예비적 청구 소송에서 사문서의 진정성립 추정 및 예비적 병합의 심판순위에 따른 판결의 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 지급을 구하는 소송에서 각서와 차용증이 제출되고, 乙이 대여금 액수에 관하여 다투는 가운데 법원이 예비적으로 병합된 고려청자 인도청구를 인용한 상황이다. 쟁점으로 <증거의 진정성립과 재판상 자백의 효력, 그리고 법원이 당사자의 주장 범위를 넘어 예비적 청구를 인용할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 증거법상 사실인정의 기준과 변론주의 원칙에 따른 법원의 판단 범위를 설명한다.

II. 사문서의 진정성립 및 예비적 병합의 법리

1. 사문서의 진정성립의 추정

(1) 2단계의 추정

- 사문서의 진정성립을 인정하기 위해서는 날인행위의 진정함이 증명되어야 한다. 민사소송법 제358조에 따라 문서에 있는 날인이 당사자의 인영과 일치함이 인정되면, 당사자 본인 또는 대리인의 의사에 기하여 날인된 것으로 사실상 추정된다. 이후 날인행위의 진정이 인정되면 당해 사문서 전체의 진정성립이 법률상 추정되는바, 이를 2단계의 추정이라고 한다.

(2) 추정의 반복 요건

- 일단 2단계의 추정이 형성되면 그 인용이 위조되었다거나 본인의 의사에 반하여 날인되었다는 사실, 또는 내용이 사후에 위조·변조되었다는 사실에 대한 주장·증명책임은 이를 다투는 자에게 전도된다. 단순한 부인이나 심증 제기만으로는 진정성립의 추정을 깨뜨릴 수 없으며, 제반 사정에 대한 엄격한 증명이 요구된다.

2. 예비적 병합의 심판순위와 처분권주의

(1) 주위적 청구 선험판단의 원칙

- 예비적 병합이란 원고가 양립할 수 없는 여러 청구를 제기하면서, 주위적 청구가 기각되거나 인용되지 않을 것에 대비하여 예비적 청구에 대한 심판을 구하는 소송 형태이다. 수소법원은 반드시 원고가 정한 심판 순위에 구속되므로, 주위적 청구에 대하여 먼저 심리·판단하여야 한다.

(2) 처분권주의와의 관계

- 민사소송법 제203조의 처분권주의에 따라 법원은 원고가 제기한 주위적 청구의 당부를 먼저 밝혀야 하며, 주위적 청구가 전부 인용되는 경우에는 예비적 청구에 대하여 심판할 수 없다. 만약 주위적 청구가 정당함에도 이를 배척하거나 판단하지 않고 예비적 청구만을 인용한 판결은 심판순위를 위배하여 처분권주의에 정면으로 저촉된다.

III. 사안의 적용

1. 차용증의 진정성립 여부 및 주위적 청구의 판단

(1) 2단계의 추정에 따른 진정성립 인정

- 피고 乙은 차용증 상의 기명날인이 자신의 것임을 직접 시인하였다. 이에 따라 2단계의 추정이 작용하므로, 해당 차용증은 성립의 진정이 적법하게 추정된다.

(2) 乙의 위조 항변의 배척 및 주위적 청구의 인용 범위

- 乙은 뒤늦게 차용증이 위조되었다고 항변하였을 뿐, 날인이 도용되었다거나 사후 변조되었다는 점에 대하여 아무런 증거도 제출하지 못하여 반복요건을 충족하지 못하였다. 따라서 차용증에 적힌 대여금 8,000만 원은 진실한 요건사실로 인정되므로, 주위적 청구인 대여금 청구는 전액 인용되어야 마땅하다.

2. 예비적 청구 판단에 따른 판결의 위법성

(1) 심판순위 및 처분권주의 위배

- 원고 甲이 청구한 주위적 청구가 전액 인용되어야 하므로, 법원은 예비적 청구인 고려청자 인도 청구에 대하여는 심판을 진행할 수 없다. 그럼에도 주위적 청구를 판단하지 않거나 배척한 채 곧바로 고려청자 인도를 명한 것은 심판순위를 완전히 일탈한 재판이다.

(2) 대물변제 예약의 성부 판단 전제 흠결

- 가사 주위적 청구가 일부 기각된다 하더라도, 법원은 8,000만 원 중 인정되는 금액의 범위 내에서 이행을 명하고 예비적 청구를 판단해야 한다. 어떠한 경우라도 주위적 채무가 증명된 상태에서 주된 급부 대신 고려청자 인도를 명하는 것은 처분권주의에 정면으로 위배되어 부적법하다.

IV. 결론

1. 주위적 청구의 인용 정당성

- 피고 乙이 기명날인의 진정을 인정하고 위조 사실을 증명하지 못하였으므로, 2단계의 추정에 따라 8,000만 원 대여금 차용증의 진정성립이 인정되어 주위적 청구는 적법하게 인용되어야 한다.

2. 법원 판결의 위법성 및 결어

- 따라서 법원이 주위적 청구를 인용하지 않은 채 예비적 청구인 고려청자의 인도를 명한 판결은 사문서의 진정성립에 관한 법리를 오해하고 예비적 병합의 심판 순위 및 처분권주의를 심각하게 위반한 판결로서 전적으로 타당하지 않아 취소되어야 한다.

《【문제2】 확인의 이익에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 확인의 이익의 의의, 일반 원칙, 요건, 구체적 양태

I. 문제의 제기

- 확인의 소는 원고의 법률적 지위의 불안을 제거하기 위하여 법원에 대하여 특정한 법률관계의 존부에 관한 판단을 구하는 소송이다. 확인의 소는 이행의 소나 형성의 소와 달리 대상에 제한이 없으므로, 소송제도의 남용을 방지하기 위해 확인의 이익이라는 특유의 소의 이익이 요구된다. 확인의 이익은 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이며, 이를 결여한 소는 부적법 각하된다. 이하에서는 확인의 이익의 일반 원칙과 구체적 요건에 대하여 설명한다.

II. 확인의 이익의 일반 원칙

1. 대상의 적절성

- 확인의 소는 원칙적으로 권리 또는 법률관계의 현존하는 존부에 관하여만 허용된다. 단순한 사실관계, 과거의 법률관계, 미래에 발생할 법률관계에 대해서는 확인의 이익이 인정되지 않는 것이 원칙이다.

2. 방법의 유효·적절성

- 확인판결을 받는 것이 원고의 권리나 법률적 지위의 불안을 제거하는 데 가장 유효하고 적절한 수단이어야 한다. 만약 이행의 소를 제기할 수 있음에도 확인의 소를 제기하는 것은 원칙적으로 확인의 이익이 없다.

III. 확인 대상에 관한 요건

1. 법률관계의 확인

- 확인의 대상은 현재의 특정한 법률관계여야 한다. 따라서 단순한 사실관계(예 : 인영의 진정성립)는 확인의 대상이 될 수 없으나, 예외적으로 민사소송법 제250조에 따라 서면의 진정 여부를 확인하는 소는 허용된다.

2. 현재의 법률관계

- 현존하는 법률관계에 한정되므로, 과거의 법률관계는 원칙적으로 확인의 이익이 없다. 다만, 과거의 법률관계 확인이 현재의 법률상 분쟁을 해결하는 가장 유효한 수단인 경우(예 : 해고무효확인)에는 예외적으로 인정된다.

IV. 확인의 필요성에 관한 요건

1. 원고의 법률적 지위의 불안

- 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험이 있어야 한다. 이는 피고가 원고의 권리를 부정하거나 원고의 지위와 양립할 수 없는 주장을 함으로써 발생한다.

2. 확인판결에 의한 불안 제거의 적절성

- 법원의 확인판결을 얻음으로써 원고가 처한 법률적 불안이 해소될 수 있어야 한다. 만약 확인판결을 받더라도 분쟁이 실질적으로 해결되지 않는다면 확인의 이익은 부정된다.

V. 확인의 이익의 구체적 양태

1. 이행의 소와의 관계

- 이행의 소를 제기할 수 있는 경우에는 직접 이행의 소를 제기하는 것이 분쟁의 종국적 해결 수단이 되므로 확인의 소는 부정된다. 이를 확인의 소의 보충성이라고 한다.

2. 국가를 상대로 하는 확인의 소

- 국가를 상대로 토지소유권 확인을 구하는 경우, 해당 토지가 미등기이거나 토지대장상 소유자 표시가 공란인 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에만 확인의 이익이 인정된다.

VI. 결론

- 확인의 이익은 확인의 소가 남용되는 것을 막기 위한 문지기 역할을 한다. 따라서 확인 대상의 적절성, 현재성, 보충성 등을 종합적으로 고려하여 판결의 실효성이 인정될 때에만 본안 판단으로 나아가야 한다. 확인의 이익이 없는 소는 소송경제 측면에서 부적법 각하하는 것이 타당하다.

《【문제3】 재소의 금지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제3> 재소의 금지의 의의, 요건, 예외, 효과, 특수한 경우의 재소금지

I. 문제의 제기

- 재소의 금지란 소송이 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 자는 동일한 소를 제기하지 못한다는 원칙을 말한다.(민사소송법 제267조 제2항) 이는 국가의 재판권 행사에 의하여 얻은 본안판결이 당사자의 무책임한 소취하로 인하여 농락당하는 것을 방지하고, 법원의 판결을 존중하며 소송경제의 효율성을 도모하기 위한 제도이다. 기판력과는 달리 판결의 확정 전이라도 중국판결 후 소를 취하하면 발생하며, 소송요건으로서 법원의 직권조사 사항에 해당한다. 이하에서는 재소금지의 성립 요건과 그 효과 및 적용 범위에 대하여 구체적으로 살펴본다.

II. 재소금지의 요건 ★

1. 본안에 대한 중국판결이 있을 것

- 재소금지가 적용되기 위해서는 적어도 제1심 또는 상소심에서 본안에 대한 중국판결이 선고된 이후여야 한다. 본안판결이란 청구의 당부에 관한 판결을 의미하며, 소각하 판결과 같은 소송판결은 포함되지 않는다.

2. 소의 취하가 있을 것

- 원고가 중국판결 선고 후 판결이 확정되기 전에 소를 취하하거나, 소취하 간주(민사소송법 제268조)가 성립해야 한다. 상소심에서 소를 취하한 경우 제1심 판결은 실효되나, 재소금지의 제재를 받게 된다.

3. 전소와 후소가 동일한 소일 것

- 재소금지의 효과를 받는 후소는 전소와 동일한 소여야 한다. 동일한 소인지 여부는 당사자, 소송물, 그리고 재소의 필요성이라는 관점에서 판단한다.

(1) 당사자의 동일

- 원칙적으로 전소의 원고가 후소의 원고인 경우를 의미한다. 다만, 전소 원고의 포괄승계인이나 소송담당에서의 채무자 등 실질적 이해관계가 동일한 자에게도 재소금지의 효력이 미친다.

(2) 소송물의 동일

- 전소와 후소의 소송물이 동일해야 한다. 다만, 청구취지가 다르더라도 소송물이 동일하거나, 전소의 기각을 면하기 위해 외형상 형태만 바꾼 경우 등은 동일한 소로 간주될 수 있다.

III. 재소금지의 예외 : 권리보호의 이익

1. 새로운 사정의 발생

- 중국판결 후 소를 취하했다라도 후소를 제기할 만한 정당한 사유가 있는 경우에는 재소금지에 저촉되지 않는다. 전소 취하 후에 발생한 새로운 사정으로 인하여 다시 소를 제기할 권리보호의 이익이 생긴 경우를 말한다.

2. 소권 행사의 오남용이 없는 경우

- 재소금지의 취지가 재판권의 오남용 방지에 있으므로, 당사자가 법원을 농락하려는 의사 없이 불가피한 사정으로 소를 취하했다가 다시 제기하는 경우에는 확인의 이익이나 재소의 필요성을 긍정하여 예외를 인정할 수 있다.

IV. 재소금지의 효과

1. 소송요건과 각하 판결

- 재소금지는 소송요건 중 하나이므로 법원은 이를 직권으로 조사하여야 한다. 재소금지에 위반된 소제기는 부적법하므로 법원은 본안에 대한 심리를 하지 않고 판결로써 소를 각하하여야 한다.

2. 기판력과의 구별

- 기판력은 판결의 확정을 요하나, 재소금지는 중국판결 후 소취하 사실만으로 발생한다. 또한 기판력은 본안판결의 내용을 존중하는 것이 목적이지만, 재소금지는 소취하에 의한 법원 농락 방지를 주된 목적으로 하는 제재적 규정이다.

V. 특수한 경우의 재소금지

1. 소의 변경과 재소금지

- 교환적 소변경의 경우 실질적으로 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 형태이므로, 중국판결 후 교환적으로 소를 변경한 경우 구소에 대해서는 재소금지의 원칙이 적용될 수 있다.

2. 독립당사자참가와 재소금지

- 독립당사자참가 소송에서 본안판결 후 원고가 소를 취하한 경우, 참가인의 청구와 관계없이 원고는 동일한 소를 제기할 수 없다. 이는 소송의 형태와 무관하게 제재적 성격이 유지되기 때문이다.

VI. 결론

- 재소금지 원칙은 당사자의 처분권주의를 존중하면서도 국가 재판권의 효율적 운영과 법적 안정성을 수호하기 위한 장치이다. 특히 중국판결이라는 국가적 노력이 투입된 이후의 소취하에 대해 엄격한 제재를 가함으로써 소송절차의 신의칙을 구현한다. 다만, 당사자의 정당한 권리 행사가 부당하게 위축되지 않도록 새로운 사정이나 재소의 필요성을 엄격히 해석하여 구체적 타당성을 확보하는 운용이 필요하다.